

فقه المعاملات

مقرر الفقه الشافعي للفرقة الثانية بكلية الشريعة والقانون

جامعة الأزهر الشريف

الأستاذ الدكتور

محمد محمد سيد أحمد عامر

كلية الشريعة والقانون بالقاهرة

بسم الله الرحمن الرحيم

المقدمة

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين ، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ، وبعد ... فهذا كتاب يحتوي على أهم مفردات مقرر الفقه الشافعي لطلاب وطالبات الفرقة الثانية بكليات الشريعة ، وكليات الدراسات الإسلامية والعربية شعبة الشريعة ، وهو يحتوي على قسمين هما الدراسة النصية من كتاب (كنز الراغبين شرح منهاج الطالبين لجلال الدين المحلي) ، والقسم الثاني : الدراسة الموضوعية للأستاذ الدكتور محمد عامر ، الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة ، مع خالص الدعاء بالتوفيق .

الدراسة النصية

الدراسة الموضوعية

الفصل الأول

الوكالة^(١)

المبحث الأول

حقيقة ومشروعية عقد الوكالة

حقيقة الوكالة .

الوكالة لغة: هي بفتح الواو وكسرهما ، والفتح أفصح مصدر وكل بالتخفيف ، واسم مصدر لو كل بالتشديد ، وهي تطلق لغة على عدة معان منها :^(٢)

أ - التفويض ، فيقال: وكل أمره إلى فلان ، بمعنى فوضه إليه واكتفى به ، ومن ذلك قولنا: توكلت على الله ، أي فوضت أمري إلى الله واكتفيت به .

ب - الحفظ ، وذلك لما على الوكيل من حفظ ما وكل فيه ، وقد وردت بمعنى الحفظ في قوله تعالى " أم من يكون عليهم وكيلاً " ^(٣) أي حفيظاً ، وكذلك قوله تعالى حكاية عن المؤمنين " حسبنا الله ونعم الوكيل " ^(٤) أي الحفيظ .

ج - الكفالة ، ففي أسماء الله تعالى «الوكيل» بمعنى المقيم الكفيل بأرزاق العباد ، وعلى هذا المعنى فإن قولهم: فلان متوكل على الله ، يعني يعلم أن الله كافل رزقه

^(١) كتبه : أ . د / محمد عامر .

^(٢) لسان العرب ج ٦ ص ٤٩٠٩ ، المصباح المنير ص ٦٧٠ مغني المحتاج ج ٢ ص

٢٩٤ ، حاشية البيجوري ج ٢ ص ٥٧١ ، الحاوي ج ٨ ص ١٨٤ .

^(٣) سورة النساء ، جزء من الآية ٣٩ .

^(٤) سورة آل عمران ، جزء من الآية ١٧٣ .

وأمره فيركن إليه وحده .

وشرعاً: هناك تعريفات متعددة للوكالة ، وهي وإن اختلفت في بعض ألفاظها ، إلا أنها تتقارب في معانيها . ويرجع هذا الاختلاف إلى محاولة البعض إبراز شرط من الشروط ، أو ذكر قيد من القيود . ومن أهم هذه التعريفات:

١- عرفها الماوردي بأنها " إقامة الوكيل مقام موكله في العمل المأذون فيه" (١) .

٢ - عرفها الخطيب الشربيني بأنها " تفويض شخص ماله فعله مما يقبل النيابة إلى غيره ليفعله في حياته" (٢) .

٣ - عرفها صاحب التحرير بأنها : " تفويض شخص أمره إلى آخر فيما يقبل النيابة لا ليفعله بعد موته " .

شرح المفردات:

قولهم «مما يقبل النيابة» إشارة إلى بعض الشروط الواجب توافرها في الوكالة ، وقد يعترض على التعريفات اشتغالها على لفظ «النيابة» لأنها تعني الوكالة ، وتم يصير المعنى «فيما يقبل الوكالة» ، ومن ثم يكون قد تم أخذ المعرف في التعريف ، وهو دور .

وقد أجاب فقهاء الشافعية على هذا الاعتراض بأن المقصود هو ما يقبل النيابة شرعاً ، ومن ثم فلا دور في التعريف .

وقولهم «ليفعله في حياته» قيد في التعريف خرج به الإيصاء ، كما لو جعله وصياً في بيع شيء أو قضاء ديونه بعد موته . ويلاحظ أن تعبير صاحب التحرير بقوله «لا ليفعله بعد موته» أولى من قولهم «ليفعله في حياته» لأنه يصدق ويشمل ما

(١) الحاوي ج ٨ ص ١٨٥ .

(٢) مغني المحتاج ج ٢ ص ٢٩٤ .

لو قال «لتفعله حال حياتي» ، أو يطلق العبارة دون هذا القول ^(١) .

حكم وأدلة مشروعية الوكالة .

ثمة حاجة لبيان الحكم التكليفي للوكالة ، وكذلك الأساس الشرعي الذي بني عليه هذا الحكم

الحكم التكليفي للوكالة .

والمقصود بالحكم هنا هو الحكم التكليفي الذي هو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين على جهة الاقتضاء أو التخيير . وفي بيان الحكم التكليفي للوكالة يمكن القول بأن الأصل فيها الإباحة ، كما أن قبولها مندوب إليه كما قال القاضي حسين وغيره ^(٢) ، استدلالاً بقوله تعالى «وتعاونوا على البر والتقوى» ^(٣) ، لقوله صلى الله عليه وسلم «والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه» ^(٤) . ويلاحظ أن عقد الوكالة تعتريه الأحكام التكليفية الخمسة فيكون حكمها كما يلي:

١ - الوجوب ، وذلك إن توقف عليها دفع ضرورة الموكل ، كتوكيل المضطر في شراء طعام ، وهو عاجز عن الشراء .

٢ - النذب ، وذلك إن كان فيها إعانة على مندوب ، كالتوكيل في إعطاء الهدية ، وصدقة التطوع .

٣ - الإباحة ، وذلك إذا كان الوكيل مستغنيا عن الوكالة ، وسأله الوكيل إياها من غير غرض .

(١) التحرير وعليه حاشية الشرقاوي ج ٢ ص ١٠٥ .

(٢) مغني المحتاج ج ٢ ص ٢٩٤ .

(٣) سورة المائدة: الآية ٢ .

(٤) مسلم، كتاب الذكر والدعاء .

٤ - الكراهة ، وذلك إن كان فيها إعانة على مكروه .

٥ -التحريم ،وذلك إن كان فيها إعانة على محرم كما لو وكله في شراء خمر ^(١) .

أدلة مشروعية الوكالة .

والأصل في مشروعية الوكالة الكتاب ، والسنة ، والإجماع ، والآثار:

أولاً: الكتاب .

١ - قوله تعالى «وابتلوا اليتامى إذا بلغوا النكاح فإن ءانستم منهم رشداً فادفعوا إليهم أموالهم» ^(٢) وقوله تعالى «فإن كان الذي عليه الحق سفيهاً أو ضعيفاً أو لا يستطيع أن يمل هو فليمل وليه بالعدل» ^(٣) . ووجه الدلالة على مشروعية الوكالة: أنه لما جاز نظر الأولياء ، وهذا النظر إنما يتحقق ويكون بتوصية الأب أو بتولية الحاكم ، وحيث أن الأب أو الحاكم لا يملك أحدهما المال ، ومع ذلك جاز نظرهم وتوكيلهم ، كان توكيل المالك الحقيقي في ملكه أجوز ^(٤) .

ويقول المزني عند قوله تعالى «فإن كان الذي عليه الحق سفيهاً أو ضعيفاً أو لا يستطيع أن يمل هو فليمل وليه بالعدل» . ووليّه عند الشافعي هو القيم بماله ، فإذا جاز أن يقوم بماله بتوصية أبيه بذلك إليه ، وأبوه غير مالك ، كان أن يقوم فيه بتوكيل ماله أجوز ^(٥) .

٢ - قوله تعالى «إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم

^(١) حاشية البيجوري على شرح بن القاسم ج ١ ص ٥٧٠ ، حاشية الشرقاوي ج ٢ ص ٨٤ ،

نهاية المحتاج ج ٥ ص ١٥ .

^(٢) سورة النساء: الآية ٦ .

^(٣) سورة البقرة: الآية ٢٨٢ .

^(٤) الحاوي الكبير ج ٨ ص ١٨٢ .

^(٥) مختصر المزني بهامش الأم ج ٣ ص ٢ .

وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليهم حكيم» (١) .

فالآية دليل على مشروعية الوكالة ، لأن جواز العمل على الصدقات يفيد حكم النيابة عن المستحقين في تحصيل حقوقهم (٢) . ، ولذا يقول القرطبي عند قوله تعالى «والعاملين عليها» يعني السعاة والجبابة الذين يبعثهم الإمام لتحصيل الزكاة بالتوكل على ذلك (٣) .

٣ - قوله تعالى «وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها» (٤) وهما وكيلان ، لا حاكمان على المعتمد (٥) . فدل ذلك على مشروعية الوكالة .

٤ - قوله تعالى حكاية عن قول يوسف عليه السلام للعزير «اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليهم» (٦) أي وكلني على خزائن الأرض ، وقوله تعالى حكاية حكاية عن أهل الكهف «فابعثوا أحكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أركى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف» (٧) فقد أضاف الورق والمال إلى جميعهم ، وجعل لهم الحق في استنابة أحدهم ، فدل ذلك على مشروعية الوكالة (٨) .

ويلاحظ أن ذكر الآيتين السابقتين يعد في حقيقته من قبيل الاستئناس ، دون الاستدلال ، لأن هذا شرع من قبلنا ، والصحيح عند الشافعية أن شرع من قبلنا

(١) سورة التوبة: الآية ٦٠ .

(٢) تكملة المجموع ج ١٤ ص ٩٢ .

(٣) الجامع لأحكام القرآن ، للإمام القرطبي ج ٥ ص ٣٠١٦ .

(٤) سورة النساء الآية ٣٥ .

(٥) حاشية البيجوري على شرح بن القاسم ج ١ ص ٥٧٠ .

(٦) سورة يوسف: الآية ٥٥ .

(٧) سورة الكهف: الآية ١٩ .

(٨) الحاوي ج ٨ ص ١٨٢ .

ليس شرعا لنا ، وإن ورد في شرعنا ما يقرره ^(١) . أما عند الأحناف وبعض الشافعية فإن ذكر الآيتين يكون للاستدلال لأنهم يرون أن شرع من قبلنا يعد شرعا لنا إن ورد في شرعنا ما يؤديه .

ثانياً: السنة:

١- ما أخرجه البخاري بسنده عن عروة البارقي قال: - «أعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ديناراً ليشتري به أضحية فاشتري شاتين وباع أحدهما بدينار وأتاه بشاة ودينار ، فدعا له بالبركة في بيعه ، فكان لو اشترى تراباً لربح فيه ^(٢)» .

٢- ما رواه أبو داود بسنده عن حكيم بن خزام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معه بدينار ليشتري له أضحية ، فاشترى بدينار وباعها بدينارين ، فرجع فاشتري أضحية بدينار ، وجاء بدينار إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فتصدق به ، ودعا له أن يبارك له في تجارته ^(٣) فهذا الحديث وما قبله يدلان دلالة واضحة على جواز التوكيل في البيع والشراء وباقي المعاملات التي تجرى فيها النيابة .

٣- ما ورد في الصحيحين من أنه صلى الله عليه وسلم «بعث الساعة لأخذ الزكاة والاستدلال بهذا الحديث مبني على أن بعث الساعة يعد من قبيل الوكالة ، ومن ثم يكون للساعي توكيل غيره فيما عجز عنه . وأما إن قيل إن بعث الساعة ولاية ، فلهم التوكيل مطلقاً» ^(٤) .

٤- وروى عن جابر رضي الله عنه أنه قال: أردت الخروج إلى خيبر فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم ، وقلت: إني أريد الخروج إلى خيبر ، فقال صلى الله عليه وسلم «إذا أتيت وكيلي فخذ منه خمسة عشر وسقاً ، فإن ابتغى منك آية

(١) مغني المحتاج ج ٢ ص ٢٩٤ ، حاشية الشرقاوي على التحرير ج ٢ ص ١٠٥ .

(٢) البخاري - المناقب رقم ٣٦٤٢ ، أبو داود كتاب البيوع ، باب في المضارب يخالف رقم ٣٣٨٤ .

(٣) أبو داود - كتاب البيوع ، باب في المضارب يخالف رقم ٣٣٨٦ .

(٤) حاشية الشرقاوي على التحرير ج ٢ ص ١٠٥ .

فضع يدك على ترقوته»^(١) .

٥- روى الترمذي بسنده عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «إذا نكح الوليان فالأول أحق ، وإذا باع المجيزان فالأول أحق»^(٢) ، وقد نقل الماوردي عن الإمام الشافعي القول بأن الحديث فيه دلالة على أن الوكالة في النكاح والبيع جائزة^(٣) .

٦- وروى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل عمرو بن أمية الضمري في نكاح أم حبيبة بنت أبي سفيان» .

٧- كما روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل أبا رافع في قبول نكاح ميمونة^(٤) . فهذا الحديث وما قبله يدل على مشروعية الوكالة في النكاح .

ثالثاً: الإجماع:

فقد انعقد الإجماع على مشروعيتها وجوازها ، ونقل الإجماع على مشروعيتها كثير من الفقهاء ، كما أن الحاجة داعية إليها ، إذ يصعب على الإنسان أن يتولى أمور نفسه كلها ، فيحتاج إلى معونة من يقوم بها . كما أن الإنسان قد يحتاج أحياناً إلى أن يصون نفسه عن البذلة^(٥) وحضور الخصومات بنفسه ، فيوكل عنه غيره .

رابعاً: الآثار:

أما الآثار فقد ورد ما يدل على قيام الصحابة رضوان الله عليهم بتوكيل بعضهم البعض في بعض شئونهم ، ومن أهم هذه الآثار ما يلي:

(١) أبو داود في الأقضية باب في الوكالة رقم ٣٦٣٢ ، السنن الصغير ج ٢ ص ٣٠٨ . رقم ٢١٠٧ .

(٢) الترمذي في النكاح رقم ١١١٠ ، ومعناه في أبو داود رقم ٢٠٨٨ .

(٣) الحاوي ج ٨ ص ١٨٣ .

(٤) الترمذي في الحج - باب ما جاء في كراهية تزويج المحرم ، رقم ٨٤١ .

(٥) مغني المحتاج ج ٢ ص ٢٩٤ ، إعانة الطالبين ج ٣ ص ٨٤ ، الحاوي ج ٨ ص ١٨٤ .

١- ما روى أن الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه وكل أخاه عقيلاً ، وقال: إن للخصومات قحماً ، وإنها لتخلف ، وإن الشيطان يحضرها ، وإني إن حضرت خفت أن أغضب ، وإن غضبت خفت ألا أقول حقا ، وقد وكلت أخي عقيلاً ، فما قضى عليه فعلى ، وما قضى له فلي (١) .

٢- كما أن الإمام علي كرم الله وجهه وكل عبد الله بن جعفر في الخصومات والنزاعات التي ترفع عليه أمام عثمان رضي الله عنه ، وقد أخبر بذلك عبد الله بن جعفر ، فقال: كان على بن أبي طالب يكره الخصومة ، فكان إذا كانت له خصومة وكل فيها عقيل بن أبي طالب ، فلما كبر عقيل وكلني (٢) . وكان من جملة هذه النزاعات نزاع بينه وبين طلحة بن عبيد الله بسبب شرب وقع النزاع فيه بينهما ، فذهب عثمان بن عفان رضي الله عنه في جمع من الصحابة لمعاينة موقع النزاع ، ثم أصلح بينهما ، فكان هذا الصنيع من قبيل الإجماع على مشروعية الوكالة (٣) .

المبحث الثاني

(١) الأم ج ٣ ص ٢٠٧ ، السنن للبيهقي ج ٦ ص ٨١ والسنن الصغير رقم ٢١١٠ .

(٢) السنن الصغير ، رقم ٢١٠٨ ج ٢ ص ٣٠٨ .

(٣) الحاوي ج ٨ ص ١٨٤ .

أركان وشروط عقد الوكالة

وأركان الوكالة أربعة: - موكل ، ووكيل ، وموكل فيه ، وصيغة . وهذه الأركان الأربعة يمكن استخلاصها من تعريف عقد الوكالة ، لأن قولهم «تفويض» أي بصيغة ، وقولهم «شخص» أي الموكل ، وقولهم «ماله فعله» أي الموكل فيه ، وقولهم «إلى غيره» أي الوكيل . فالأركان الأربعة يتضمنها تعريف عقد الوكالة ^(١) . ونتكلم عنها بالتفصيل: -

الركن الأول

الصيغة

إن عقد الوكالة كسائر العقود لابد فيه من لفظ ينعقد به ، وأن يكون هذا اللفظ مقارنا لذكر ما وكل فيه ، وأن يوجد القبول للوكالة . وتفصيلاً فإنه يشترط في الصيغة كركن من أركان الوكالة جملة من الشروط أهمها ما يلي ^(٢):

الشرط الأول: وجود لفظ العقد من الموكل .

فيشترط في عقد الوكالة وجود لفظ - ولو كناية - من الموكل يقتضي ويشعر برضاه ، كقوله وكلتك في كذا ، أو فوضته إليك ... إلخ ، ومثل اللفظ كتابة أو إشارة أحرص مفهمة ، وإنما اشترط الإيجاب من الموكل لأن الوكالة عقد كسائر العقود التي يلزمها الإيجاب ، كما أن الشخص لا يجوز له التصرف في مال غيره إلا بإذنه . وينقسم اللفظ الصادر من الموكل إلى ثلاثة أقسام:

١ - صريح العقد ، كأن يقول: وكلتك أو أنت وكيلي ، فيصح عقد الوكالة في هذه الحالة .

(١) حاشية البيجوري ج ١ ص ٥٧١ ، حاشية الشرقاوي ج ٢ ص ١٠٥ .

(٢) روضة الطالبين ج ٣ ص وبعدا ، مغني المحتاج ج ٢ ص ٣٠١ وبعدها ، الحاوي ج ٨ ص ١٨٦ وبعدها .

٢ - مقصود العقد ، كأن يقول: قد أقمتك مقامي ، أو جعلتك نائباً عني ، فتصح الوكالة في هذه الصورة لأن اللفظ هنا يتضمن مقصود عقد الوكالة .

٣ - لفظ محتمل ، وهو ما كان خارجاً عن صريح العقد ومقصوده ، كقوله: قد عولت عليك ، أو اعتمدت عليك ، فلا يصح العقد في هذه الحالة لأن اللفظ هنا محتمل ، ومن ثم لا يصح إلا إذا انضم إليه من الألفاظ ما يدل على الرضا بالوكالة من الموكل .

الشرط الثاني: أن تتضمن الصيغة ذكر ما وكل فيه .

فيشترط في الصيغة كركن من أركان عقد الوكالة أن تتضمن ذكر ما وكل فيه بصورة تجعله محدداً ، وعلى ذلك فإذا تم ذكر ما وكل فيه بلفظ يكون عاماً في الأحوال كلها ، كقوله وكلتك في كل شيء ، أو في فعل ما تراه صالحاً لي ، فهذه وكالة باطلة للجهل بها . وأما إذا تم ذكر ما وكل فيه بلفظ يجعله خاصاً في حال بعينها ، كقوله قد وكلتك في شراء هذه الدار ، فتصح الوكالة في هذه الحالة .

وأما إذا كان اللفظ عاماً من وجه ، وخاصاً من وجه آخر ، فتصح الوكالة بشرط أن يؤدي خصوص اللفظ إلى جعل العموم فيه معلوماً ، كقوله: وكلتك في بيع كل قليل وكثير في مالي ، لأن تخصيص التصرفات بالبيع قد جعلت من العموم الوارد على كل المال أمراً معلوماً ، ومن ثم فإن الوكالة تنصرف إلى البيع ، دون باقي التصرفات من هبة ورهن . . إلخ .

الشرط الثالث: قبول الوكيل .

بوجه عام يطلق القبول ويراد به أحد معنيين ، أحدهما: القبول الحكمي ، ويقصد به : الرضى والرغبة فيما فوض إليه ، ونقيض هذا المعنى من معاني القبول هو الرد والرفض . والمعنى الثاني للقبول: هو القبول اللفظي ، ويعني ضرورة وجود اللفظ الدال على القبول على النحو الموجود في العقود .

١ - **القبول الحكمي**: وهو المعتبر في عقد الوكالة عند الشافعية ، والذي يعني

رضاء الوكيل بما فوض إليه وعدم رفضه أو رده ، أما إذا رفض أو رد ، فقال لا أقبل ثم ندم وأراد القبول بعد الرفض لم يجز ، بل لابد من إذن جديد ، لأن الوكالة عقد جائز ينتهي دوامها بالفسخ ، فلا تتعقد في الابتداء بالرد والرفض من باب أولى^(١) .

والدليل على اشتراط القبول وعدم الرد أو الرفض من الوكيل في عقد الوكالة ما رواه البخاري بسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه كان يقول «كان أبو طلحة أكثر أنصاري بالمدينة مالاً ، وكان أحب أمواله إليه بيرحاء وكانت مستقبلة المسجد ، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب . فلما نزلت «لن تتاولا البر حتى تنفقوا مما تحبون» ، قام أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال: يا رسول الله إن الله تعالى يقول في كتابه «لن تتاول البر حتى تنفقوا مما تحبون» ، وأن أحب أموالي إلى بيرحاء ، وإنها صدقة لله أرجو برها وذخرها عند الله ، فضعها يا رسول الله حيث شئت فقال صلى الله عليه وسلم «بخ ، ذلك مال رائج ، ذلك مال رائج . قد سمعت ما قلت فيها ، وارى أن تجعلها في الأقربين» . قال: أفعل يا رسول الله: فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه^(٢) .

فالحديث يدل على أن الوكالة لا تتم إلا بالقبول ، لأن أبا طلحة قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ضعها حيث شئت . فلم يقبل النبي صلى الله عليه وسلم ، بل رد عليه قوله: ومن ثم رفض الوكالة فلم تتعقد^(٣) .

ويلاحظ أنه: إذا كان الأصل عند الشافعية هو اعتبار القبول الحكمي الذي يعني الرضا وعدم الرفض ، إلا أنهم يشترطون القبول اللفظي من الوكيل على سبيل

(١) روضة الطالبين ج ٣ ص ٥٣٤ .

(٢) صحيح البخاري - كتاب الوكالة - باب إذا قاله رجل لوكيله ضعه حيث أراك الله ، رقم

٢٣١٨ .

(٣) فتح الباري شرح صحيح البخاري ج ٥ ص ٢٦٤ .

الاستثناء في صورتين:

الصورة الأولى: الوكالة بجعل ، فإذا كان الوكيل يعمل بجعل فيلزم منه القبول اللفظي ، وينبغي تصوير هذا بما إذا كان العمل الموكل فيه مضبوطا لتكون الوكالة حينئذ إجارة .

الصورة الثانية: إذا كان للموكل عين مؤجرة أو معارة أو مغصوبة ثم وهبها الموكل لشخص آخر وأذن له في قبضها من المستأجر أو المستعير أو الغاصب فوكل الموهوب أو الغاصب في قبضها له ، فلا بد من قبوله لفظاً ، وذلك حتى تزول يد المستأجر أو المستعير أو الغاصب عن العين الموهوبة بهذا القبول اللفظي . ولا يكفي هنا بالفعل وهو الإمساك ، لأنه استدامة لما سبق فلا دلالة فيه على الرضا بقبضه عن المؤجر أو المعير ^(١) .

٢ - القبول اللفظي . ويعني ضرورة وجود القبول باللفظ في عقد الوكالة على النحو الموجود في العقود ، ففيه عند الشافعية ففيه أوجه:

الوجه الأول: وهو الأصح أنه لا يشترط القبول اللفظي ، لأن الوكالة إباحة ورفع حجر كإباحة الطعام ، فلا يشترط فيها القبول لفظاً .

الوجه الثاني: اشتراط القبول اللفظي مطلقاً ، لأنه تملك للتصرف .

الوجه الثالث: يشترط القبول اللفظي إن كان الإيجاب بصيغة عقد كوكلتك ، وذلك إلحاقاً لصيغ العقود بالعقود . أما إذا كان الإيجاب بصيغة الأمر ، مثل بع ، واشتر ، فلا يشترط القبول ، وذلك إلحاقاً لصيغ الأمر بالإباحة ^(٢) .

ويلاحظ أن أثر الخلاف عند الشافعية من حيث اعتبار القبول بالمعنى الأول ، والذي يعني الرضا وعدم الرفض ، وبين اعتبار القبول بالمعنى الثاني وهو القبول

(١) حاشية الشرقاوي ج ٢ ص ١٠٥ ، إعانة الطالبين ج ٣ ص ٨٧ .

(٢) مغني المحتاج ج ٢ ص ٣٠١ ، نهاية المحتاج ج ٥ ص ٢٨ .

اللفظي يظهر فيما يلي:

١ - **تعجيل القبول:** فمن اعتبر القبول بالمعنى الأول ، والذي يعني الرضا وعدم الرفض ، يرى أنه لا يشترط في هذا القبول التعجيل بحال من الأحوال بلا خلاف . وأما من اعتبروا القبول اللفظي ، فقد اختلفوا في اشتراط تعجيله على أوجه^(١) ، أهمها:

الوجه الأول: ذهب الماوردي والرويانى إلى أن الأصل في القبول من الوكيل على التراخي إلا في ثلاث حالات :

الأولى: إذا وكله في إبراء نفسه اعتبر القبول بالامتثال فوراً .

الثانية: إذا عرض الحاكم الوكالة على الوكيل عند ثبوتها عند الحاكم ، ففي هذه الحالة يكون القبول على الفور .

الثالثة: أن يتعين زمان العمل الذي وكل فيه ، فإن تعيين زمان العمل ، وخيف عليه من الفوات بسبب التراخي كان القبول على الفور .

وقد عارض أبو الضياء الشبراملسي في اعتبار الحالتين الأولى والثانية من المستثنيات الحقيقية ، لأن اشتراط فورية القبول في الإبراء مبنية على أنه تملكي ، لا توكيل . كما اعتبرت الفورية في الحالة الثانية لإلزام الحاكم إبقاء حق الغريم ، لا للوكالة .

الوجه الثاني: ذهب أبو حامد المروزي إلى أن قبول الوكالة على الفور لأنها عقد ، فينطبق عليها ما ينطبق على سائر العقود من اشتراط الفورية في القبول . بيد أن هذا الوجه محل اعتراض من بعض الشافعية كالماوردي ، وذلك لما يلي:

١ - إن الوكالة إذن للوكيل بالتصرف ، فلم يحتج إلى تعجيل القبول ، وذلك

(١) الحاوي ج ٨ ص ١٨٩ ، روضة الطالبين ج ٣ ص ٥٣٤ ، حاشية قليوبي ج ٢ ص

٣٤٠ ، حاشية الشبراملسي مع نهاية المحتاج ج ٥ ص ٢٨ .

قياساً على ما لو أذن له في بيع أو شراء .

٢ - أن الوكالة نيابة كالوصية ، ولما كان القبول في الوصية على التراخي ، فإنه يكون كذلك في الوكالة .

٢ - التوكيل دون علم الوكيل . فمن لم يشترط القبول اللفظي ، يرى أن الموكل لو وكل شخصاً ، والوكيل لا يعلم بهذا التوكيل ، ثبت وكالته على الأصح ، لأنه لا يشترط في صحة الوكالة علم الوكيل بها . وعلى هذا لو تصرف الوكيل قبل العلم بالوكالة ، ثم بان وكيلاً ، ففي صحة تصرفه خلاف عند الشافعية ، الأصح أن تصرفه صحيح ، وذلك استدلالاً بما يلي :

١ - القياس : حيث يقاس تصرف الوكيل قبل العلم بالوكالة ثم بان وكيلاً ، على من باع مال أبيه ظاناً حياته فبان ميتاً أنه يجوز لمملكه إياه في الحقيقة .

٢ - أن العبرة في العقود . بما هو في نفس الأمر وحقيقته ، ولما كانت الحقيقة أنه قد سبق توكيل من الموكل للوكيل ، فإن تصرفه يكون صحيحاً ، حتى وإن كان لا يعلم بالتوكيل ، لأن التصرف أتى مطابقاً للواقع والحقيقة (١) .

الشرط الرابع : ألا تكون الصيغة معلقة .

فيشترط في الصيغة أن تكون منجزة غير معلقة على شرط من صفة أو وقت ، ومن ثم إذا علق الوكالة على شرط ، كقوله إذا قدم زيد أو جاء رأس الشهر ، فأنت وكيلي ، فالأصح عند الشافعية عدم صحة العقد ، قياساً على سائر العقود . كما أنه لا يجوز قياس الوكالة على الوصية والإمارة في جواز التعليق ، لأن الوصية تقبل الجهالة ومن ثم تقبل التعليق ، كما أن التعليق في الإمارة يرجع إلى الحاجة ، وهذا مالا يوجد في الوكالة ، فلا تقبل التعليق .

فإذا كانت الصيغة في الوكالة معلقة على شرط ، وقلنا بفسادها ، ومع ذلك

(١) إعانة الطالبين ج ٣ ص ٨٧ .

تصرف الوكيل بعد حصول الشرط ، فإن الأصح صحة تصرفه لحصول الإذن الصحيح ، ويظهر أثر فساد عقد الوكالة المعلق على شرط في سقوط الجعل المسمى للوكيل إن كان شرط له الجعل ، ويتم الرجوع إلى أجرة المثل .

ويرى الشافعية أنه لو نجز الوكالة وشرط للتصرف شرطاً فإنه يجوز كما لو قال وكلتك الآن ببيع هذا الثوب ، ولكن لاتبعه إلا بعد شهر ، صح التوكيل بلا خلاف . كما يرى الشافعية صحة الوكالة المؤقتة ، كوكتك شهراً ، فإذا مضى الشهر امتنع على الوكيل التصرف ^(١) .

(١) روضة الطالبين ج ٣ ص ٥٣٥ ، نهاية المحتاج ج ٥ ص ٢٨ ، ٢٩ .

الركن الثاني

الموكل

يشترط في الموكل صحة مباشرته ما وكل فيه بملك أو ولاية . أما صحة المباشرة بالملك ، فكتوكيل المكلف الرشيد مطلق التصرف في ماله . وأما صحة المباشرة بالولاية ، فمثل توكيل الأب والجد في النكاح والمال . ومرجع اشتراط هذا الشرط هو أن الأصل إن لم يقدر على التصرف في الشيء بنفسه ، فلا يقدر عليه من خلال نائبه من باب أولى .

ويخرج بلفظ «ملك أو ولاية» الوكيل ، فإنه لا يجوز له في الأصل التوكيل ، لانتفاء كونه مالكاً أو ولياً .

ووفقاً لهذا الشرط فإنه لا يصح التوكيل الصادر من الفئات التالية:

١- الصبي والمجنون والمغمى عليه والنائم . فأما العاقل إذا وكل عن نفسه ثم أصابه الجنون بعد صدور التوكيل ، فله حالتان:

الحالة الأولى: أن يلزمه الجنون زمناً طويلاً حتى يصبح في حاجة إلى من يولي عليه ، فالوكالة باطلة عند الشافعية ، لأن من أصابه الجنون لما أصبح بالجنون باطل التصرف ، كان تصرف من توكل من جهته أبطل .

الحالة الثانية: ألا يطول به الجنون ، بل يفيق منه سريعاً بحيث لا يحتاج إلى من يولي عليه ، فالظاهر عند الشافعية بطلان الوكالة أيضاً لذات الحجة السابقة ، وسواء صار الجنون مألوفاً أو غير مألوف .

وقال أبو العباس بن سريج: الوكالة صحيحة ، لأن قصر مدة الجنون وسرعة الإفاقة ، تجعل الجنون عفواً كأوقات النوم .

٢- توكيل المحرم حلالاً في عقد النكاح ، للنهي عن ذلك ، فقد روى الشافعي عن مالك عن نافع عن نبيه بن وهب ، أن عمر بن عبد الله أراد تزويج ابنه طلحة بنت جبير ، فبعث إلى أبان بن عثمان ، وكان أمير الخناج ، وكانا محرمين ، فأنكر ذلك عليه أبان ، وقال: سمعت عثمان بن عفان يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول « لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب » (١) .

ولا يعترض على ذلك بضعف نبيه بن وهب ، فقد روى عنه مالك بن أنس ، وأيوب السختياني ، وكفى بهما ، ثم روى عنه أحمد بن حنبل ، ويحيى بن معين ، كما أن القصة مشهورة ، وقد حكاها عن أبان سعيد بن المسيب وغيره (٢) .

وعلى ذلك فإذا وكل المحرم شخصاً ليعقد له أو لموليه حال الإحرام فلا يصح التوكيل . أما إذا وكله ليعقد له بعد التحلل صح .

٣- التوكيل الصادر من المرأة لأجنبي في عقد النكاح لأنها لا تزوج نفسها فلا توكل في عقد الزواج من باب أولى .

٤- السفية والمفلس ، لا يجوز توكيلهم في التصرفات التي لا يستقلون بها إلا بعد إذن الولي والغريم ، بينما يصح توكيلهم فيما يستقلون به من التصرفان .

وعلى ذلك يجوز للسفيه أن يوكل في الطلاق والخلع والرجعة وقبول الوصية والهبة ، كما يجوز للمفلس أن يوكل عنه في غير المال الذي في يده .

ويلاحظ أنه إذا كان الضابط عند الشافعية هو أنه يشترط في الموكل

(١) مسند الشافعي ص ٢٥٣ ، مسلم في النكاح مع شارحه النووي ج ٩ ص ١٩٣ ، أبو داود

كتاب المناسك باب المحرم يتزوج رقم ١٨٤١ .

(٢) الحاوي ج ٥ ص ١٦٠ ، ١٦١ .

«صحة مباشرته ما وكل فيه بملك أو ولاية» إلا أنه يستثنى من هذا الشرط أو الضابط مسائل متعددة ، بعضها من طرده ، وبعضها من عكسه .

أ - المستثنى من طرده:

فأما طرده ، وهو «أن كل من صحت مباشرته بملك أو ولاية ، صح توكيله» فيستثنى منه مسائل أهمها:

- ١- حق الظفر ، فإذا جوزنا لصاحب الدين أن يكسر الباب أو ينقب الجدار ، ويأخذ ما يجده بالظفر ، فإنه وإن جازت له المباشرة عند القائلين بها ، فإنه مع ذلك لا يجوز له أن يوكل في ذلك غيره .
- ٢- في ولاية الإيجاب إذا أذنت المرأة للولي في التزويج ونهته عن التوكيل ، فإنه تصح منه مباشرة العقد بالتزويج ، ولكن لا يصح منه التوكيل .
- ٣- إذا طلق إحدى زوجتيه ، أو أسلم على أكثر من أربع نسوة ، فإنه لا يصح له التوكيل في التعيين ولا في الاختيار إلا إذا عين للوكيل المرأة المعينة أو المختارة ، ففي تلك الصورة يحق للموكل المباشرة بالتعيين أو الاختيار دون أن يوكل غيره في ذلك .
- ٤- السفية المأذون له في النكاح له أن يباشر العقد بنفسه ، دون أن يوكل فيه غيره ، لأن الحجر على السفية لا يرتفع إلا عن مباشرة العقد فقط ، دون التوكيل فيه .
- ٥- التوكيل في الإقرار ممتنع على الصحيح .
- ٦- توكيل المسلم الكافر في نكاح مسلمة .
- ٧- التوكيل في رد المغصوب والمسروق مع القدرة على الرد بنفسه ، فإنه وإن صحت منه المباشرة ، لا يجوز له التوكيل في الرد كما قال الشيخ العز بن عبد السلام .

ب - المستثنى من عكسه:

ويقصد بالعكس هو «أن من لا تصح منه المباشرة بالملك والولاية ، لا

تصح منه الوكالة» ، فيستثنى منه مسائل أهمها:

- ١- توكيل الأعمى في البيع والشراء ونحوهما مما يتوقف على الرؤية كالإجارة والأخذ بالشفعة ، فإن هذا التوكيل يصح . مع أن الأعمى لا يقدر على المباشرة بنفسه .
- ٢- توكيل مستحق القصاص في قطع طرف أو حد قذف ، فإنه يصح منه التوكيل في استيفائه مع أنه لا يصح منه المباشرة أو الاستيفاء بنفسه .
- ٣- توكيل المشتري البائع في أن يوكل البائع من يقبض المبيع عن المشتري ، فإن البائع لا تصح منه مباشرة القبض من نفسه ، مع أنه يجوز له التوكيل عن المشتري .
- ٤- توكيل المحرم حلالاً ليعقد له بعد تحلله أو أطلق ، صح التوكيل مع أن المحرم لا تصح منه المباشرة بنفسه .
- ٥- إذا وكل حلال محرماً ليوكل حلالاً آخر في التزويج ، فإن المحرم لا تصح منه المباشرة ، ومع ذلك يصح منه التوكيل ^(١) .

الركن الثالث

الوكيل

إن الوكيل هو الركن الثالث من أركان عقد الوكالة ، وهذا الوكيل هو الذي سيتولى مباشرة التصرف نيابة عن الموكل ، ومن ثم فإنه يشترط فيه ما يلي:

الشرط الأول: أن يكون معيناً:

فيشترط في الوكيل أن يكون معيناً ، بحيث لو قال الموكل لاثنتين: وكلت أحكما في بيع أرضي ، أو قال: أذنت لكل من أراد بيع سيارتي ، لم يصح ، لعدم تعيين الوكيل . ويستثنى من شرط تعيين الوكيل ما يلي:

(١) مغني المحتاج ج ٢ ص ٢٩٥ ، نهاية المحتاج ج ٥ ص ١٥ ، ١٦ ، الحاوي ج ٨ ص

- ١- التوكيل في الحج ، كأن يقول: من حج عني فله كذا ، فتصح الوكالة هنا .
- ٢- إن وقع الوكيل غير المعين تبعاً لمعين ، كقوله وكلتك في كذا وكل مسلم أيضاً (١) .

الشرط الثاني: صحة المباشرة لنفسه:

فيشترط في الوكيل صحة مباشرة التصرف المأذون فيه لنفسه . ومرد هذا الشرط هو أن تصرف الشخص لنفسه أقوى من تصرفه لغيره ، لأنه يتصرف لنفسه بطريق الأمانة ، أما تصرفه لغيره فبطريق النيابة ، فإذا لم يقدر على الأقوى لنفسه ، فلا يقدر على الأضعف لغيره من باب أولى .

ووفقاً لهذا الشرط فإنه لا يصح توكيل مغمى عليه ولا مجنون ولا معتوه ولا نائم ولا صبي ، لأن ولايتهم مسلوقة . ويلاحظ أن عدم صحة توكيل الصبي محلها فيما لا تصح منه مباشرته ، ومن ثم فإن ما يصح له مباشرته ، يصح توكيله فيه ، وذلك مثل حج التطوع وذبح الأضحية وتفريق الزكاة ، وكذلك لا يصح توكيل المرأة والمحرم في عقد النكاح ، كذلك لا يصح توكيل الفاسق فيما فيه ولاية ، غدت تشترط العدالة في وكيل القاضي ، وفي وكيل الولي في بيع مال المولى .

ويلاحظ أنه إذا كان الضابط الذي وضعه الشافعية هو «صحة مباشرة الوكيل التصرف المأذون فيه لنفسه» ، فإن هذا الضابط يعني عكساً أن «من لا تصح مباشرته لنفسه لا يصح توكيله من قبل غيره» ، إلا أنه يستثنى من عكس هذا الضابط مسائل يصح فيها للشخص أن يكون وكيلاً عن غيره مع أنه لا يصح أن يباشر هذا التصرف لنفسه ، ومن أهم هذه المسائل: -

- ١- اعتماد قول الصبي المميز المأمون في الإذن في دخول الدار وإيصال الهدية ، لأن السلف كانوا يتسامحون في ذلك ، وهذا توكيل من قبل الآذن

(١) نهاية المحتاج ج ٥ ص ١٨ .

والمهدي .

- ٢- توكيل الشخص في نكاح أخت زوجته ، إذ يحرم عليه أن يباشر هذا العقد لنفسه حتى لا يجمع بين أختين ، ولكن يجوز أن يكون وكيلاً عن غيره .
- ٣- توكيل من تحته أربع نسوة في نكاح امرأة لآخر . فيحرم عليه أن يعقد عليها لنفسه حتى لا يكون تحته أكثر من أربع نسوة ، بينما يجوز أن يباشر هذا التصرف للغير غير المتزوج بأربع .
- ٤- توكيله في نكاح محرمه كأخته ، فالشخص يحرم عليه مباشرة هذا التصرف بأن يعقد على محارمه كالأم والأخت ، ولكن يجوز أن يكون وكيلاً في العقد من أجل غيره ممن لا يحرم عليه .
- ٥- توكيل السفية في قبول النكاح بغير إذن وليه ، فإنه يجوز رغم أن السفية لا يقبل لنفسه ولا يجوز له أن يباشر التصرف لنفسه دون إذن وليه لما في ذلك من تبعات مالية تقع عليه بسبب النكاح ، ولكن عندما يباشر لغيره فإنه يجوز ، لأن الأثر المالي يكون على الغير .
- ٦- توكيل المرأة في طلاق غيرها ، ففي وجه عند الشافعية أن الوكالة صحيحة ، لأنها لو ملكت طلاق نفسها صح ، فجاز أن تتوكل في طلاق غيرها ^(١) .

الركن الرابع

الموكل فيه

يمثل الموكل فيه الركن الرابع من أركان الوكالة ، وقد اشترط الشافعية في الموكل فيه شروطاً ، أهمها ، أن يملكه الموكل حال التوكيل ، وأن يكون معلوماً ولو بوجه من الوجوه ، وأن يكون قابلاً للنيابة ، وتفصيل ذلك كما يلي:

الشرط الأول: أن يملكه الموكل حال التوكيل

(١) مغني المحتاج ج ٢ ص ٢٩٦ ، الحاوي ج ٨ ص ١٩٥ وبعدها .

فيشترط في الموكل فيه أن يملكه الموكل حال التوكيل ، لأنه إذا لم يكن يملك الشراء محل التوكيل ، فكيف يأذن لغيره أن يتصرف فيه .

وقد اعترض الإمام الأذرعي من الشافعية على صياغة هذا الشرط واعتبرها قاصرة ، لأنها لا تنطبق إلا على من يوكل في مال نفسه ، بينما لا تنطبق على من جوزنا له التوكيل في مال الغير مثل الولي والحاكم ، فلا يملك أحدهما الموكل فيه ، ولذا فقد اقترح الخطيب الشربيني أن تكون الصياغة للشرط هي "أن يملكه الموكل أو الموكل عنه حال التوكيل «بينما صاغ بعض الشافعية الشرط بقوله» أن يكون للموكل ولاية عليه «أي سلطنة بسبب ملكه التصرف فيه ، سواء كان مالكاً للعيين أو لا ، كالولي والحاكم^(١) ، والغرض من هذه الصياغة أن تكون العبارة أعم حتى تشمل توكيل الولي والحاكم باعتبار أنهما لا يملكان الموكل فيه ، ومع ذلك جاز لهما التوكيل .

ووفقاً لهذا الشرط فإن الأصح عند الشافعية أنه لا يجوز للوكيل أن يوكل فيما سيملكه بمقتضى العقود المستقبلية ، فلا يجوز له أن يوكل في بيع منزل سيملكه بعقد مستقبلي ، أو طلاق امرأة سيتزوجها ، ... إلخ ، وذلك لأنه لا يملك أن يباشر هذا بنفسه حال التوكيل ، فكيف يحق له أن يستنيب غيره فيما لا يملكه ولا يقدر عليه .

والثاني: يصح اكتفاء بحصول الملك عند التصرف .

ويلاحظ أنه إذا كان الأصل عند الشافعية هو اشتراط ملكية الموكل للموكل فيه عند التوكيل ، إلا أنه يستثنى من هذا الشرط الصور التالية:

١- أن يوكله ببيع عين يملكها . ثم يشتري له بثمنها شيئاً ، فالمشهور عند الشافعية صحة التوكيل في هذه الصورة ، مع أن الموكل لم يملك الثمن بعد .

(١) مغني المحتاج ج ٢ ص ٢٩٧ ، إعانة طالبين ج ٣ ص ٨٥ .

- ٢- إذن المقارض للعامل في بيع ما سيملكه ، ويلحق به الشريك كما قال الإمام الأذرعي ، مع أن المقارض لم يملك المبيع قبل شراء العامل .
- ٣- أن يكون الموكل فيه المعدوم تبعاً لحاضر ، كما لو وكله ببيع الثياب التي يملكها وما سيملكه منها ، فالمنقول عن الشيخ أبي حامد الصحة ، وذلك قياساً على ماله وقف على ولده الموجود ، وما سيولد له من أولاد . وإن كان الإمام الرافعي يرى أن هذه الصورة تحتل الصحة وعدمها .
- ٤- أن يوكله ببيع ثمار الأشجار قبل اطلاعها ، لأن الموكل في هذه الصورة يملك الأصل .
- ٥- أن يوكله في المطالبة بحقوق أو ديون موجودة ، فيدخل في هذا التوكيل ما يتجدد من ديون وحقوق مستقبلية ، وهذا ما أفتى به ابن الصلاح ^(١) .

الشرط الثاني: أن يكون الموكل فيه معلوماً:

ومرد اشتراط هذا الشرط هو ألا يعظم الغرر المبطل للعقد ، لكن يلاحظ أن الشافعية لا يشترطون أن يكون الموكل فيه معلوماً من كل وجه ، كما لا يشترطون أن يذكر في الموكل فيه أوصاف السلم ، وذلك لأن الوكالة جوزت للحاجة ، وهذا يقتضي المسامحة فيها ، ولذا فإنهم يكتفون بأن يكون الموكل فيه معلوماً من بعض الوجوه دون جميعها . ويترتب على ذلك:

١ - أن الوكالة العامة التي تتضمن التفويض في كل الأمور كقوله «فوضتك في كل قليل وكثير ، أو وكلتك في كل أموري ، أو فوضتك في كل شيء» هذه الوكالة العامة لا تصح عند الشافعية ، وذلك لما تتطوي عليه من عظيم الغرر ، واشتمالها على ما لا يسمح به الموكل لو عرض عليه كطلاق الزوجة ، والتصدق بالأموال .

ويستثنى من بطلان الوكالة العامة عند الشافعية طريقة ذكرها إمام

(١) نهاية المحتاج ومعه حاشية الشبراملسي ج ٥ ص ٢١ ، ٢٢ ، حاشية الشرقاوي على التحرير

الحرمين والغزالي وبعض الأصحاب ، وهي أن يذكر الموكل مفردات الأمور المتعلقة به مفصلة وأن يفصل أجناس التصرفات في هذه الأمور ، فيقول: وكلتك في بيع أملاكي ، وتطبيق زوجاتي ، ... إلخ .

٢ - أن الوكالة الخاصة: والتي تتضمن التفويض في مباشرة تصرف بذاته تعد صحيحة ، كقوله: وكلتك في بيع أموالني . أو يقول: وكلتك في قبض ديوني ، ففي هذه الحالة نجد أن الوكالة اقتضت في الصورة الأولى على بيع الأموال ، وفي الصورة الثانية اقتضت على قبض الديون ، وهنا نجد أن الشافعية يرون صحة مثل هذه الصور قطعا ، ولا يشترطون - خلافاً للبغوي - ضروري كون الأموال معلومة على الصحيح من كل وجه لقلة الغرر ، كما يرون أن تخصيص التصرف بالبيع فقط في الصورة الأولى ، وبالقبض فقط في الصورة الثانية ، قد جعل من العموم الوارد على كل الأموال في الصورة الأولى ، وعلى كل الديون في الصورة الثانية أمراً معلوماً ، وكأن الشرط هو أن يكون الموكل فيه معلوماً أو يسهل علمه .

وتطبيقاً لما سبق ، فإن التوكيل بالشراء ، فيجب أن نفرق بين ما إذا كان غرض الموكل القنية ، وبين ما إذا كان غرضه التجارة . فإن كان الغرض من التوكيل بالشراء القنية كشراء سيارة للاستعمال الخاص ، فيجب أن يبين في التوكيل الجنس والنوع ، ولا يشترط استقصاء أوصاف السلم ولا ما يقرب منها ، كما لا يجب ذكر الصنف والصفة إلا إذا اختلفت أصناف نوع اختلافاً ظاهراً أو اختلف غرض الموكل بالصفة .

وبالمثل فإذا وكله في شراء دارا ، وجب بيان البلد ، والحي والشارع ، والحارة ، وغير ذلك مما يتعلق به غرض الموكل .

أما إذا كان الغرض من التوكيل بالشراء التجارة ، فلا يشترط ذكر النوع ولا يغره ، بل يكفي قوله: اشتر ما شئت من العروض ، أو ما ترى أن فيه حظاً ومكسباً ، وهذا ما ذهب إليه المتولي والماوردي .

ويلاحظ أنه فيما يتعلق بذكر الثمن فقد وجد خلاف عند الشافعية على

وجهين:

الوجه الأول : وهو الأصح عند الشافعية أنه لا يجب بيان قدر الثمن ، لأن غرض الموكل قد يتعلق بأحد أفراد النوع من غير نظر لخسة ونفاسة ، بل يراعي فقط حال الموكل وما يليق به ، ويرى صاحب التهذيب أن عدم ذكر الثمن يكون إذناً في أعلى ما يكون منه .

الوجه الثاني: يجب بيان قدر الثمن كمائة ، أو غايته ، كأن يقول له «اشتر من مائة إلى ألف» وذلك لظهور التفاوت في أثمان الجنس الواحد ، وذلك لأن المحلة تجمع دار الغني ودار الفقير ^(١) ففي واقعنا يختلف ثمن السيارة المستعملة عن ثمن السيارة التي لم تستعمل ، رغم وحدة النوع ، كما يختلف ثمن الشقق السكنية عن العمارات عن الفيلات رغم وجودها في مدينة أو حي واحد .

الشرط الثالث: أن يكون الموكل فيه قابلاً للنياية .

فيشترط في الموكل فيه أن يكون قابلاً للنياية ، لأن الوكالة في جوهرها استنابة ، ومن ثم فإن مالا يقبلها كاستيفاء حق القسم بين الزوجات ، لا يصح التوكيل فيه . وترتبط قابلية الموكل فيه للنياية في كثير من الحالات بمدى قدرة الموكل أو عجزه ، ومدى كون الموكل فيه من حقوق الله تعالى أو من حقوق الآدميين . ويمكن القول أن الأعمال التي يفترض فيها النياية تنقسم إلى أربعة أقسام^(٢):

القسم الأول: ما لا يجوز التوكيل فيه مع القدرة والعجز:

هناك أعمال لا يجوز التوكيل فيها بحال من الأحوال ، دون نظر إلى قدرة

(١) روضة الطالبين ج ٣ ص ٥٢٧ ، يراجع الحاوي بتصرف ج ٨ ص ١٨٨ ، نهاية المحتاج

ج ٥ ص ٢٦ ، ٢٧ .

(٢) الحاوي ج ٨ ص ١٨٥ ، ١٨٦ .

الموكل أو عجزه ، لأن هذه الأعمال تطلب من الشخص ذاته ، وغالب هذه الأعمال يدور حول العبادات في الأصل ، أو ما يلحق بها ، ومن ثم لا يصح التوكيل عند الشافعية فيما يلي:

أ - العبادات:

فالأصل في العبادات عدم صحة التوكيل فيها ، وإن لم تتوقف على نية ، لأن مباشرها مقصود بعينه وذاته ، ولا فرق بين أن تكون العبادة فرضاً أو نفلاً ، فلا يصح التوكيل في الصلاة أو الاعتكاف ... إلخ .

وحجة الشافعية في عدم صحة التوكيل في العبادات هو أن العبادات فرضت على جهة الابتلاء ، وهو لا يوجد في العبادات البدنية إلا بإتباع النفس والبدن ، وبهذا الاتعاب يظهر الانقياد أو النفور ، ومن ثم فقد نقل الطبري وغيره الإجماع على أن النيابة لا تدخل في الصلاة بخلاف الزكاة ، فإن الإبتلاء فيها يكون بنقص المال ، وهو حاصل بالنفس وبالغير .

وحاصل الأمر أن العبادة على ثلاثة أقسام:

- ١- بدنية محضة ، كالصلاة ، فيمتنع التوكيل فيها ، إلا ركعتي الطواف .
- ٢- مالية محضة ، فيجوز التوكيل فيها مطلقاً كإخراج الصدقة .
- ٣- مالية غير محضة كالحج ، فيجوز التوكيل فيها بشرط أن يكون المؤدى عنه ميتاً أو معضوباً ^(١) كما سنرى .

ب - ما ألحق بالعبادات:

فلا تصح الوكالة في كل ما يلحق بالعبادات ، كالشهادات ، والأيمان ، ومن الأيمان: الإيلاء ، واللعان ، والقسامة ، فلا يصح التوكيل في شيء منها

(١) فتح الباري شرح صحيح البخاري ج ٤ ص ٥٤٩ ، إعانة الطالبين ج ٣ ص ٨٧ ، حاشية

الشرقاوي على التحرير ج ٢ ص ١٠٨ .

قطعاً ، وفي معنى الإيمان النذور ، وتعليق الطلاق فلا يصح التوكيل في ذلك ، كما لا يصح التوكيل في الظهار في الأصح ^(١) . وكذلك الإقرار لا يصح فيه التوكيل في الأصح ^(٢) .

وقد استدلت الشافعية على عدم صحة الوكالة فيما سبق بما يلي:

- ١- قياس الشهادات وإلحاقها بالعبادات في عدم قابليتها للتوكيل ، ووجه الإلحاق ، إننا احتطنا في الشهادات ، ولم نقم غير لفظها مقامها ، فألحقت بالعبادات .
- ٢- أن الحكم في الشهادات منوط بعلم الشاهد ، وهذا غير حاصل للوكيل .
- ٣- أن الشهادات تبني على التعبد واليقين الذي لا تمكن فيه النيابة .
- ٤- إن القول بصحة التوكيل في الشهادة قياساً على صحة الشهادة على الشهادة باسترعاء ، وذلك بأن يقول الأصل للنائب أنا شاهد على أحمد بكذا ، واشهدك على شهادتي ، ثم يتعذر حضور الأصل بموت أو مرض أو حبس ، فيذهب النائب إلى القاضي ويقول: أشهد أن فلاناً أشهدهني على شهادته بكذا . . هذا القياس غير مسلم لوجود الفارق ، لأن الشهادة على الشهادة ليست من قبيل التوكيل ، بل هي استرعاء ، أي طلب الأصل من النائب أن يرعى شهادته ويحفظها ، فالحاجة هنا هي التي جعلت الشاهد المحتمل عنه بمنزلة الحاكم المؤدى عنه عند حاكم آخر .
- ٥- أن الأيمان لا يجوز فيها التوكيل قياساً على العبادات بجامع أن القصد منهما تعظيم الله تعالى ، ولأن الإيلاء حلف بالله تعالى فهو من الأيمان التي لا تقبل النيابة . أما اللعان فهو إما يمين ، وإما شهادة ، وكلاهما لا يقبل النيابة . وأما النذر والطلاق المعلق فلا تصح الوكالة فيهما إلحاقاً لهما باليمين ، كما أن

(١) والثاني: يجوز التوكيل في الظهار إلحاقاً له بالطلاق . وصورة التوكيل في الظهار أن يقول: أنت على موكلي كظهر أمه ، أو جعلت موكلي مظاهراً منك .

(٢) والثاني: أن التوكيل في الإقرار صحيح ، لأن الإقرار قول يثبت به الحق ، فأشبهه الشراء الذي يثبت به الحق ، ولما كان الشراء يجوز فيه التوكيل ، فكذلك الإقرار . وصورة التوكيل بالإقرار أن يقول: وكلتك لتقر عني لفلان بكذا ، فيقول الوكيل: أقررت عنه بكذا . .

المغلب في الظهار معنى اليمين ، وأن الظهار من المعاص ، فلا يجوز فيه التوكيل .

٦- أن الإقرار إخبار عن حق ، فلا يقبل التوكيل قياساً على الشهادة ^(١) .

ج - التوكيل في المعاصي:

فلا يصح التوكيل في المعاصي كالقذف والسرقة . . إلخ ، فالجرائم كلها لا مدخل للتوكيل فيها ، لأن المعاصي حكمها يختص بمرتكبها ، كما أن كل شخص بعينه مطالب بالامتناع عن الوقوع فيها .

والضابط الذي وضعه الشافعية في هذا الصدد هو «أن ما كان محرماً بأصل الشرع كالزنا والقذف والسرقة ، لا يقبل التوكيل . أما ما كان مباحاً بأصل الشرع ، وحرم لعارض ، كالبيع وقت النداء يوم الجمعة ، أو بيع حاضر لباد ، فإنه يقبل التوكيل» ^(٢) .

القسم الثاني: ما يجوز التوكيل فيه مع القدرة والعجز:

فيصح التوكيل مطلقاً دون نظر إلى قدرة الموكل أو عجزه عن مباشرة الموكل فيه في كثير من حقوق الأموال ، أو ما يجري مجرى الأموال ، وسواء أكانت هذه الحقوق من حقوق الله تعالى أم من حقوق الآدميين ، فيصح التوكيل عند الشافعية فيما يلي:

أ - إتمام العبادات المالية المحضة والمعاونة عليها .

فيصح التوكيل في المعاونة على بعض العبادات المالية المحضة ، وذلك مثل إخراج وتفريق الزكاة والكفارات ، وكذا تفريق النذر والصدقة ، كما يجوز

(١) روضة الطالبين ج ٣ ص ٥٢٣ ، ٥٢٥ ، مغني المحتاج ج ٢ ص ٢٩٨ ، ٢٩٩ ، حاشية

الشرقاوي على التحرير ج ٢ ص ١٠٧ ، نهاية المحتاج ج ٥ ص ٢٢ .

(٢) المراجع السابقة .

التوكيل في ذبح الأضاحي والعقيقة والهدى والبدن وشاة الوليمة . وقد استدل الشافعية على صحة التوكيل فيما سبق بما يلي:

- ١- ما روى أنه صلى الله عليه وسلم «بعث السعاة لأخذ الزكاة» .
- ٢- ما روى عن جابر رضي الله عنه أنه قال: أردت الخروج إلى خيبر فأُتيت النبي صلى الله عليه وسلم ، وقلت: إني أريد الخروج إلى خيبر فقال صلى الله عليه وسلم «إذا أُتيت وكلني فخذ منه خمسة عشر وثقاً ، فإن ابتغى منك آية ، فضع يدك على ترقوته» (١) .
- ٣- ما رواه البخاري بسنده عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها أخبرت أن عائشة رضي الله عنها قالت: أنا فتلت قلائد هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي ، ثم قلدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيديه ، ثم بعث بها مع أبي ، فلم يحرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء أحله الله له حتى نحر الهدى (٢) .
- فالحديث ظاهر الدلالة على جواز الوكالة في البدن .
- ٤- ما روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ساق في حجة مائة بدنه فكان سهيل بن عمرو يقدم البدن بين يده ، حتى نحر منها بيده صلى الله عليه وسلم ستة وستين بدنه ، وأمر علياً رضي الله عنه فنحر الباقي (٣) .

فقد دل الحديث على جواز النيابة في ذبح الهدى والأضحية لأن النبي صلى الله عليه وسلم استناب علياً في نحر ما بقي من هدية صلى الله عليه وسلم .

ب - التوكيل في المعاملات:

فيصح التوكيل في طرفي البيع بأنواعه ، كالسلم والصرف والتولية

(١) سبق تخريجه .

(٢) صحيح البخاري - كتاب الوكالة - باب الوكالة في البدن وتعاهدتها رقم ٢٣١٧ .

(٣) أبو داود ، كتاب المناسك ، باب صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم رقم ١٩٠٥ ، صحيح

البخاري - كتاب الحج - باب يتصدق بجلال البدن ، رقم ١٧١٨ .

وغيرها ، كما يصح التوكيل في الرهن ، والهبة ، والصلح ، والإبراء ، والحوالة ، والضمان ، والكفالة ، والشركة ، والمضاربة ، والإجارة ، والجعالة ، والمساقاة والإعارة ، والأخذ بالشفعة ، والوقف ، والفسوخ المتراخية ، كما يصح التوكيل في قبض الديون وإقباضها ، وقد استدلت الشافعية على صحة التوكيل فيما سبق بما يلي:

١- ما أخرجه أبو داود بسنده عن حكيم بن خزان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معه بدينار ليشتري له أضحية ، فاشترها بدينار وباعها بدينارين ، فرجع فاشتري أضحية بدينار ، وجاء بدينار إلى النبي صلى الله عليه وسلم فتصدق به ، ودعا له أن يبارك له في تجارته ^(١) .

٢- ما رواه البخاري بسنده عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلاً على خيبر ، فجاءهم بتمر جنيب ، فقال صلى الله عليه وسلم «أكل تمر خيبر هكذا؟» قال الرجل: إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة . فقال صلى الله عليه وسلم «لا تفعل ، بع الجمع بالدرهم ، ثم ابتع بالدرهم جنيباً» ^(٢) . وقد ذكر البخاري هذا الحديث في باب الوكالة في الصرف والميزان . وذكر ابن المنذر الإجماع على أن الوكالة في الصرف جائزة . ووجه القول بصحة الوكالة في هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم لعامله على خيبر «بع الجمع بالدرهم» .

٣- ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وسلم يتقاضاه فأغلظ ، فهم به الصحابة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «دعوه ، فإن لصاحب الحق مقالاً» ، ثم قال صلى الله عليه وسلم «أعطوه سناً مثل سنه» ، قالوا: يا رسول الله إلا أمثل من سنه . فقال صلى الله عليه

^(١) سبق تخريجه .

^(٢) صحيح البخاري ، كتاب الوكالة ، باب الوكالة في الصرف والميزان رقم ٢٣٠٢ .

وسلم «أعطوه ، فإن من خيركم أحسنكم قضاء» ^(١) .

فهذا الحديث يدل على مشروعية الوكالة في أداء الديون وإقباضها ، بل ينقل ابن حجر قول ابن المنير: أنه ربما توهم متوهم أن قضاء الدين لما كان واجباً على الفور امتنعت الوكالة فيه ، لأنها تأخير من الموكل إلى الوكيل ، فبين أن ذلك جائز ، ولا يعد ذلك مطلاً ^(٢) .

وبالجملة ، فإن الأحاديث السابقة أوضحت بالنص صحة الوكالة في البيع والشراء ، وفي الصرف والميزان ، وفي قضاء الديون وإقباضها ، كما أنها أوضحت صحة الوكالة في غيرها من باقي المعاملات المذكورة بالقياس عليها لأنها في معناها .

ج - التوكيل في النكاح وما يلحق به:

فيصح التوكيل في عقد النكاح ، والخلع ، وتنجيز طلاق امرأة معينة ، والرجعة في الأصح ، فهذه الحقوق تجري مجرى الأموال ويجوز التوكيل فيها عند الشافعية استدلالاً بما يلي:

- ١- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «وكل عمرو بن أمية الضمري في نكاح أم حبيبة بنت أبي سفيان» ^(٣) .
- ٢- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «وكل أبا رافع في قبول نكاح ميمونة» ^(٤) .
- ٣- أن التوكيل في الخلع جائز ، لقوله تعالى «فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها» ^(٥) ومن المعلوم أن للحكمين أن يخالعا ، فدل ذلك على جواز

(١) صحيح البخاري - كتاب الوكالة - باب الوكالة في قضاء الديون ، رقم ٢٣٠٦ .

(٢) فتح الباري ج ٥ ص ٢٥٢ .

(٣) سبق التخريج .

(٤) سبق التخريج .

(٥) سورة النساء: جزء من الآية ٣٥ .

التوكيل في الخلع ، ولأن الخلع جامع بين الطلاق والبيع ، والتوكيل جائز في كل واحد منهما ، فجاز فيما جمعهما ^(١) .

٤- أن فاطمة بنت قيس طلقها وكيل زوجها بمشهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأمضاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، دون انكار ^(٢) فقد روى مسلم ^(٣) بسنده عن فاطمة بنت قيس أنها قالت: إن زوجها أبو عمرو بن حفص بن المغيرة أرسل عياش بن أبي ربيعة لطلاقها وأرسل معه بخمسة أصع تمر وخمسة أصع شعير ، ... إلخ .

د - التوكيل في الدعوى والخصومات:

فيصح التوكيل في الدعوى والجواب ، وإن لم يرض الخصم ، لأنه خالص حق الموكل ، وسواء أكان ذلك في مال أم في غيره كعقوبة ، بشرط أن يكون بعيداً عن حدود الله تعالى . كذلك يصح التوكيل في استيفاء عقوبة آدمي كقصاص وحد قذف ، كما يصح التوكيل من قبل الإمام في استيفاء الحدود وعقوبات الله تعالى ، دون إثباتها ، لأنها مبنية على الدرع ، ومن ثم لا يصح التوكيل في إثباتها إلا في حالة واحدة ، وهي أن يقع إثباتها بالوكالة تبعاً ، كأن يوكل القاذف شخصاً في ثبوت زنا المقدوف ليسقط الحد عن نفسه ، فتسمع دعواه عليه أنه زنا ^(٤) . وقد استدل الشافعية على صحة التوكيل في كل ما سبق بماي لي:

(١) الحاوي ج ١٢ ص ٣٥٦ .

(٢) الحاوي ج ١٣ ص ٣٧ .

(٣) صحيح مسلم ، باب المطلقة البائن لا نفقة لها ج ١٠ ص ١٠٥ .

(٤) نهاية المحتاج ج ٥ ص ٢٤ ، ٢٥ . وجاء فيه بتصريف: وقيل أنه لا يجوز التوكيل في استيفاء عقوبة آدمي إلا بحضور الموكل ، لاحتمال أن يعفو في الغيبة ، فلا يمكن تداركه لأن الوكيل يكون قد نفذ العقوبة .

وقد أجب عن هذا بأن احتمال العفو مثل احتمال رجوع الشهود فيما لو ثبتت العقوبة ببينة ، ولما كان احتمال رجوع الشهود في غيبتهم لا يمنع من استيفاء العقوبة ، فكذا احتمال عفو الموكل لا يمنع قياساً عليه .

١- ما رواه زيد بن خالد وأبو هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال «واغد يا أنيس إلى امرأة هذا ، فإن اعترفت فارجمها» (١) .

٢- عن عقبة بن الحارث رضي الله عنه قال «جاء بالنعيمان - أو ابن النعيمان - شارباً ، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان في البيت أن يضربوه قال ، فكنت أنا فيمن ضربه ، فضربناه بالنعال والجريد (٢) .

فهذا الحديث وما قبله يدل على جواز التوكيل من قبل الإمام في إقامة الحدود واستيفاء العقوبة ، ذلك أن الإمام لما لم يتول إقامة الحد بنفسه ، وولاه غيره ، كان ذلك بمنزلة توكيله لهم في إقامته .

٣- أن الإمام على كرم الله وجهه وكل أخاه عقيلاً ، وقال: إن للخصومات قحماً ، وأنها لتخلف ، وإن الشيطان يحضرها ، وإني إن حضرت خفت أن أغضب ، وإن غضبت خفت ألا أقول حقاً ، وقد وكلت أخي عقيلاً ، فما قضى عليه فعلى ، وما قضى له فلى (٣) .

فهذا الأثر يدل على جواز التوكيل في الخصومات .

القسم الثالث: ما يجوز التوكيل فيه مع العجز ، ولا يجوز مع القدرة .

في هذا القسم ، فإن صحة التوكيل مرهونه بعجز الموكل ، ومن ثم فلا تصح الوكالة إن كان الموكل قادراً على الإتيان بالفعل الموكل فيه . ولقد مثل الشافعية لهذا القسم بالحج والعمرة . فيجوز للإنسان أن يوكل غيره في الأداء عند العجز . دون القدرة وقد استدلل الشافعية على ذلك بما يلي:

١- ما روى عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلاً يقول: لبيك عن شبرمة ، فقال صلى الله عليه وسلم: من شبرمة؟

(١) صحيح البخاري - كتاب الوكالة - باب الوكالة في الحدود ، رقم ٢٣١٥ .

(٢) صحيح البخاري - كتاب الوكالة - باب الوكالة في الحدود ، رقم ٢٣١٦ .

(٣) السنن الصغير ، رقم ٢١١٠ .

فقال الرجل أخ لي ، أو قريب لي ، فقال صلى الله عليه وسلم «حجبت عن نفسك؟» قال: لا . قال صلى الله عليه وسلم «حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة» ^(١) فقد اذن له النبي صلى الله عليه وسلم في الحج عن شبرمة ، وهذا يدل على وقوع الحج عنه وسقوط الفرض لهذا الأداء .

٢- ما رواه أبو داود بسنده عن أبي رزين أنه قال: يا رسول الله: إني أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن ، قال صلى الله عليه وسلم: «احج عن أبيك واعتمر» ^(٢) .

٣- ما روى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال «جاءت امرأة من خثعم عام حجة الوداع ، قالت: يا رسول الله: إن فريضة الله على عبادة الحج ، أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يستطيع أن يستوي على الرحلة ، فهل يقضي عنه أن أحج عنه؟ قال صلى الله عليه وسلم «نعم» ^(٣) .

ففي هذا الحديث دلالة على جواز الحج عن الغير ، وقال ابن العربي: حديث الخثعمية أصل متفق على صحته في الحج ، خارج عن القاعدة المستقرة في الشريعة من أن ليس للإنسان إلا ما سعى ، وفقاً من الله في استدراك ما فرط فيه المرء بولده وماله ، وأن عموم السعي في الآية مخصوص اتفاقاً . وقد اتفق من أجاز النيابة في الحج على أنها لا تجزئ في الفرض إلا عن موت أو غضب ، ومن ثم فلا يدخل المريض لأنه يرجى برؤه ، ولا المجنون لأنه يرجى إفاقته ، ولا المحبوس لأنه يرجى خلاصه ، ولا الفقير لأنه يرجى استغناؤه ^(٤) .

القسم الرابع: ما لا يجوز التوكيل فيه مع القدرة ، مع الخلاف في جوازه عند العجز .

(١) أبو داود ، كتاب المناسك ، باب الرجل يحج عن غيره ، رقم ١٨١١ .

(٢) أبو داود ، كتاب المناسك ، باب الرجل يحج عن غيره ، رقم ١٨١٠ .

(٣) صحيح البخاري - كتاب جزاء الصيد - باب الحج عمن لا يستطيع الثبوت على الرحلة ،

رقم ١٨٥٤ ، باب حج المرأة عن الرجل رقم ١٨٥٥ مسند الشافعي ص ١٠٨ .

(٤) فتح الباري لابن حجر ج ٤ ص ٥٤٩ ، ٥٥٠ .

والمثال الواضح في ذلك عند الشافعية هو الصوم ، فإن من وجب عليه الصيام ، وهو ما زال حياً ، فلا يجوز الصيام عنه سواء كان عاجزاً أو مطيقاً . أما إن كان ميتاً ، فالمذهب القديم عند الشافعي هو جواز الصوم عنه ، لما روى عن عائشة رضي الله عنها ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «من مات وعليه صيام صام عنه وليه» ^(١) ، وما روى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال «جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله: إن أُمِّي ماتت وعليها صوم شهر ، أفأقضيه عنها؟ قال صلى الله عليه وسلم «نعم» قال «فدين الله أحق أن يقضي» ^(٢) .

فوفقاً لهذا الحديث ذهب الشافعي في القديم إلى القول بجواز النيابة في الصوم ، وعلق الجواز على صحة هذه الأحاديث ، بينما ذهب في الجديد إلى منع ذلك ^(٣) ثم تأول الشافعية الأحاديث السابقة .

(١) صحيح البخاري - كتاب الصوم - باب من مات وعليه صوم ، رقم ١٩٥٢ .

(٢) صحيح البخاري - كتاب الصوم - باب من مات وعليه صوم ، رقم ١٩٥٣ .

(٣) فتح الباري ج ٤ ص ٧٠٦ .

المبحث الثالث

أحكام عقد الوكالة

الوكالة من عقود الأمانة

إن الوكيل في عقد الوكالة بمثابة الأمين ، ومن ثم فإن يده يد أمانة . ومقتضى هذا أنه لا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط . يستوي في هذا أن تكون الوكالة بجعل ، أو بغير جعل .

كما أن الوكيل يصدق بيمينه في دعوى التلف والرد على الموكل ، أما دعوى الرد على غير الموكل كرسوله ووارثه ، فلا يصدق إلا ببينة ، وذلك عملاً بالقاعدة المشهورة وهي «أن كل أمين ادعى الرد على من ائتمنه صدق بيمينه ، إلا المرتهن والمستأجر» .

وذهب أبو على الطبري من الشافعية إلى خلاف هذا ، حيث يرى أن الوكالة إن كانت بجعل أو بعوض ، فإنها تأخذ حكم الأجير المشترك من حيث الضمان ، ويرى فيها اعتبار القولين ، قول بالضمان ، وآخر بعدم الضمان .

ويلاحظ أن ما ذهب إليه أبو على الطبري ليس صحيحاً ، لوجود الفارق بين الوكالة والإجارة ، فالوكالة عقد جائز ، أما الإجارة فعقد لازم ، فإذا خرجت الوكالة عن حكم الإجارة في اللزوم ، فإنها تخرج عنها في حكم الضمان .

ويرجع سبب اعتبار يد الوكيل يد أمانة إلى ما يلي:

١- إن الوكيل بمثابة الموكل ، فقد أقامه الموكل مقام نفسه في اليد والتصرف ، ولما كان الموكل لا يضمن ما هلك بيده من مال نفسه ، فكذلك الوكيل ، لأن يده كيد موكله .

٢- أن الوكالة عقد إرفاق ومعونة وإحسان ، لأنها من باب التعاون على البر

والتقوى ، فلو قلنا بأنها من عقود الضمان ، لأدى ذلك إلى إحجام الناس عن قبولها ، فتخرج الوكالة عن حقيقة المعونة والإرفاق .

ووفقاً لما سبق ، فإن الوكيل لا يضمن إلا بالتعدي أو بالتفريط ، مثله في ذلك مثل سائر الأمناء ، فإن تعدى أو فرط ، فإنه يضمن ، غير أنه لا ينعزل في الأصح ، لأن الوكالة إذن في التصرف ، وأما الأمانة فإنها حكم يترتب على الوكالة ، ولا يلزم من ارتفاع هذا الحكم بطلان الإذن ، كما أنه لا يصح القول بالعزل قياساً على الوديعة لأن الوديعة ائتمان محض . أما الوكالة فهي إذن في التصرف تضمن الأمانة ، فإذا انتفت الأمانة بالتعدي بقى الإذن بحاله . وفي ذلك يقول الإمام الشيرازي «لأن العقد - أي الوكالة - يتضمن أمانة وتصرفاً ، فإذا تعدى فيه بطلت الأمانة وبقي التصرف ، كالرهن يتضمن أمانة ووثيقة ، فإذا تعدى فيه بطلت الأمانة وبقيت الوثيقة»^(١) .

عوارض التضمن في الوكالة:

إذا كان الأصل عند الشافعية هو أن عقد الوكالة من عقود الأمانة وليس من عقود الضمان ، فإن الشافعية يرون أن التعدي أو التفريط يعتبر من العوارض التي تطرأ على هذا الأصل ويترتب عليها ضمان الوكيل . ولقد ذكر الشافعية العديد من الأمثلة التي يعتبرونها صوراً للتعدي والتفريط ومن هذه الصور ما يلي:

- ١- أن يضيع المال ولا يدري كيف ضاع منه ، أو يتركه في مكان وينساه .
- ٢- تأخير التصرف الموكل فيه دون عذر ، مع علمه بوقوع ضرر ، كأن يتأخر في بيع طعام يسرع فساده .
- ٣- تسليم المبيع قبل قبض الثمن ، دون إذن من الموكل ، أو أمر من الحاكم .
- ٤- تلف الموكل فيه بالاستعمال ، دون وجود إذن حقيقي بالاستعمال من الموكل ، أو إذن حكومي كوجود عرف يسمح بالاستعمال . فلو وكله في بيع

(١) المهذب مع تكملة المجموع ج ١٤ ص ١٥٥ .

سيارة ، فلا يجوز له أن يستعملها دون إذن حقيقي من الموكل ، أو ما يسمح له العرف بذلك كإدخالها وإخراجها إلى مكان المعرض ، أو تجريبها لمن يرغب في شرائها .

٥- جحود الوكيل للوكالة وإنكاره قبض المال ، ثم يثبت بعد ذلك بالبينة أو بالإقرار وجود الوكالة وقبضه المال ، فيصبح عندئذ ضامناً ، حتى ولو ادعى بعد البينة أو الإقرار رد المال أو تلفه ، لأنه خرج بالجحود عن الأمانة ، فصار كجاحد الوديعة .

٦- استهلاك الوكيل المال الذي دفعه الموكل لإنجاز الموكل فيه ، كأن يعطي الموكل الوكيل مالا ليشتري له شيئاً ، فيأخذ الوكيل المال قرضاً لنفسه أو يتصرف فيه تصرفاً آخر يهلكه أو يتلفه ، ثم يشتري له بمال آخر مثله ، فالشراء هنا غير لازم للموكل ، لأن الوكالة تبطل باستهلاك المال وتلفه ، ومن ثم يعزل الوكيل ويضمن ، ويصبح عقده لازماً لنفسه دون الموكل . وقد صور هذا المزمى في مختصره بقوله «ولو دفع إليه مالا يشتري له به طعاماً ، فلسفه ، ثم اشترى له بمثله طعاماً ، فهو ضامن للمال ، والطعام له ، لأنه خرج من وكالته بالتعدي ، واشترى بغير ما أمره به»^(١) .

٧- تسليم المبيع رغم مخالفة الوكيل لمقتضى الإذن الصادر من الموكل في الوكالة المطلقة ، كأن يبيع بغير نقد البلد ، أو يبيع بنسيئة ، أو أن يبيع بغير فاحش . ففي هذه الصور . إن سلم الوكيل المبيع ، فإنه يضمن لتعديه بتسليم المبيع ببيع فاسد ، ويلزمه استرجاع المبيع إن كان باقياً . أما إن هلك فإن الموكل يرجع على من شاء من الوكيل أو المشتري .

٨- امتناع الوكيل من التخلية بين الموكل وبين ماله دون عذر . فإذا امتنع الوكيل عن دفع ثمن ما باع إلى الموكل مثلاً ، فإن كان من غير عذر فإنه يضمن . أما إن كان بعذر كمرض ، أو حضور فرض كصلاة الجمعة ، أو ضياع مفتاح ، فهذه أعذار مقبولة من الوكيل في تأخير الدفع ، فإن ضاع أو تلف المال ، فلا ضمان عليه لوجود العذر .

(١) مختصر المزمى وشارحه الحاوي ج ٨ ص ٢٢٦ ، وبعدها .

ويجري الخلاف بين الشافعية في اعتبار منع الوكيل الموكل من أخذ المال ، حتى يشهد على نفسه ، وهل يعد هذا من قبيل الأعذار أو لا؟ ، وذلك على أوجه:

الوجه الأول: أن التأخير رغبة في الإشهاد لا يعتبر عذراً ، لأن الموكل غير ملزم بالإشهاد على نفسه ، إذ لا حاجة للوكيل في هذا ، لأن قوله في الرد والدفع مقبول ، فلماذا يتمسك بالإشهاد؟ وعلى ذلك يصير الوكيل بالمنع ضامناً وعليه الغرم إن تلف المال . وهذا الوجه هو الصحيح عند الماوردي .

الوجه الثاني: أن التأخير رغبة في الإشهاد يعد عذراً ، ومن ثم للوكيل التأخير والامتناع من الدفع حتى يتم الإشهاد ، ووجهة هذا الوجه أن الوكيل يستفيد من الإشهاد ، فيسلم من اليمين مع الإكذاب عند الخلاف بينه وبين الموكل . وعلى هذا الوجه ، لا يصير الوكيل بالمنع ضامناً ولا غرم عليه إن تلف المال .

الوجه الثالث: أن الوكيل إن قبض المال في حضرة الشهود ، فيجوز له أن يمتنع عن الرد إلا في وجود الشهود . أما إن أخذ المال دون وجود شهود ، فيجب عليه الدفع دون التمسك بوجود شهود ، وهذا الوجه ذهب إليه بعض الشافعية ، وهو مذهب الإمام مالك رضي الله عنه .

ويلاحظ أنه إذا حدث خلاف بين الموكل والوكيل في وجود العذر من عدمه ، فقال الموكل: منعتني غير معذور ، وقال الوكيل: منعتك معذوراً ، فالقول قول الوكيل مع يمينه ، وذلك بشرط أن يكون ما قاله أمراً ممكناً^(١) . وبمعنى آخر ، فإن دعوى الإثبات هنا تقع على الموكل ، لأن الأصل في الوكيل الأمانة ، ومن يطالب بغير ذلك يقع عليه عبء الإثبات .

(١) مختصر المزني بهامش الأم ج ٣ ص ٥ ، حاشية البيجوري على شرح بن القاسم الغزي ج

١ ص ٥٧٣ ، البيجرمي على الخطيب ج ٣ ص ١٧٠٣ ، الحاوي ج ٨ ص ١٩١ ،

٢١٦ وبعدها .

٩- التفريط بترك الإشهاد عند دفع المال إلى غير الموكل . وقد ذكر المزنى هذه الصورة بقوله «ولو أمر الموكل الوكيل بدفع مال إلى رجل ، فادعى أنه دفعه إليه ، لم يقبل منه إلا ببينه» ^(١) وعلى ذلك إذا أمر الموكل الوكيل بدفع مال ، وكان هذا المال ديناً في ذمة الموكل ، أو كان عينا مضمونة ، ثم ادعى الوكيل الدفع ، بينما أنكر المدفوع إليه القبض ، لم يقبل قول الوكيل ، لأن الموكل نفسه لو ادعى دفعا لم تقبل دعواه ، فإدعاء الوكيل أولى بعدم القبول .

أما حكم قبول قول الوكيل في الدفع وسريانه على الموكل ، فإنه يجب التفرقة بين حالتين ^(٢):

الحالة الأولى: أن يكذب الموكل الوكيل في الدفع . ففي هذه الحالة لا يقبل قول الوكيل على الموكل ، ويكون الوكيل ضامناً له . وحجة الشافعية في ذلك: أن الوكيل وإن كان أميناً للموكل ، إلا أن قوله غير مقبول في الدفع إلى غيره ، قياساً على الوصي ، فهو أمين للموصي ، ولا يقبل قوله في الدفع إلى اليتيم ، لأنه يدعي دفعاً إلى غير من أئتمنه ، ولذلك أمره الله تعالى بالإشهاد على اليتيم بقوله «فإذا دفعتم إليهم أموالهم فاشهدوا عليهم» ^(٣) .

الحالة الثانية: - أن يصدق الموكل الوكيل في الدفع . فإن كان الموكل غائباً عنه وقت الدفع ، فالوكيل يكون ضامناً ، بالرغم من تصديق الموكل له ، لأن الوكيل قد فرط بترك الإشهاد ، لأن الأمر بالدفع يقتضي منه أن يحيط هذا الدفع بالضمانات التي تبرأ الموكل من المطالبة مرة أخرى ، وهذا يقتضي منه الإشهاد .

وأما إذا كان الموكل حاضراً مع الوكيل وقت الدفع ، فقد اختلف الشافعية

(١) مختصر المزنى مع الأم ج ٣ ص ٦ .

(٢) الحاوي ج ٨ ص ٢٢٠ وبعدها .

(٣) سورة النساء جزء من الآية رقم ٦ .

في وجوب الضمان على وجهين: أحدهما: أن الوكيل لا يضمن لأن حضور الموكل يتطلب منه الاستيثاق لنفسه بالإشهاد ، فلم يقع تفريط من الوكيل . والوجه الثاني: أن الوكيل يضمن ، لأنه مفطر بترك الإشهاد ، حيث أن ما يلزمه مع غيبة الموكل ، يلزمه في حضوره .

ووفقاً لما سبق ، فإذا لم تقبل دعوى الوكيل في الدفع إلى الغير ، فإن من حق الغير أن يرجع على الموكل دون الوكيل ، إن كان المال ديناً في ذمة الموكل ، أما إن كان المال عيناً مضمونة في يد الموكل كالعقار والمال المغصوب ، فإن لصاحب العارية أو المال المغصوب أن يرجع على من شاء من الموكل أو الوكيل ، لأن الوكيل ثبتت له يد على المال المغصوب ومال العارية ، فصارت يده كيد الموكل في وجوب الضمان .

تعلق أحكام العقد بالوكيل

إن غالب أحكام العقد محل الوكالة تتعلق بالوكيل ، لأنه المباشر للعقد والعائد الحقيقي له ، ولذا فإن الوكيل يضيف العقد إلى نفسه ، ولا يجب عليه تسمية الموكل في العقد ، إلا في حالات استثنائية ، منها ^(١):

- ١- إذا اشترى الوكيل بمال نفسه للموكل بإذنه ، فيجب تسمية الموكل في العقد حتى يقع الشراء للموكل ، فإن لم يسمه فإن الشراء يقع للوكيل ، وتلغو نيته في الشراء للموكل إن وجدت .
- ٢- النكاح . فيجب على الولي أو وكيل الزوج تسمية الزوج باسمه في عقد النكاح حتى يقع النكاح له ، لأن الوكيل في عقد النكاح سفير محض ، فيقول: زوج موكلي فلان .
- ٣- العقود التي لا عوض فيها ، مثل الهبة والوقف والوصية والإعارة والرهن والوديعة ، فيجب على الوكيل تسمية الموكل في قبول الهبة ، فيقول: أقبل لموكلي فلان . فإذا لم يعينه باسمه ، فإن العقد يقع

(١) حاشية قليوبي ج ٢ ص ٣٤٦ ، مغني المحتاج ج ٢ ص ٣١١ ، وبعدها .

للوكيل لجريان الخطاب معه بغير ذكر الموكل . وتلغو نية الوكيل إن قصد الموكل ، لأن الواهب قد يقصد بتبرعه المخاطب دون غيره . وفي هذا يفارق عقد الهبة عقد البيع ، لأن الواهب يقصد شخصا معينا بهبته ، فوجب تسمية المقصود . أما البيع فالبائع يقصد حصول العوض ، فلم يجب تسمية المشتري .

ووفقاً لما سبق: فإذا أخذنا عقد البيع على سبيل المثال ، فإننا نجد أن غالب أحكامه تناط وتتعلق بالوكيل ، ومن أهم هذه الأحكام ما يلي ^(١) :

- ١- رؤية المبيع . فحيث تلزم رؤية المبيع ، فالعبرة برؤية الوكيل .
- ٢- لزوم العقد بمفارقة المجلس . فعقد البيع لا يلزم إلا بمفارقة المجلس من أحد المتعاقدين ، ومن ثم فإن مفارقة الوكيل لمجلس العقد يترتب عليها لزوم العقد .
- ٣- التقابض في المجلس عند اشتراطه يعول فيه على الوكيل . فمن المعلوم أن التقابض في المجلس شرط لصحة بعض البيوع كبيع الأموال الربوية ، وكذلك الحال اشتراط قبض رأس مال السلم في مجلس العقد ، ففي مثل هذه الحالات يجب التقابض في المجلس عن طريق الوكيل ما دام هو الذي يباشر العقد ، فإن تفرق الوكيل عن المجلس قبل القبض ، كان العقد فاسداً .
- ٤- الفسخ بخيار المجلس والشرط . فللوكيل حق فسخ العقد بخيار المجلس وخيار الشرط - وأن أجاز الموكل العقد - بينما لا يفسخ بخيار العيب إن رضى الموكل بالعيب . والفرق هو أن خيار العيب شرع لدفع الضرر عن المالك وهو الموكل ، فإن رضى بالعيب لم يجز للوكيل الفسخ . أما الفسخ في خيار المجلس ، فهو منوط بالعاقدين ، لقوله صلى الله عليه وسلم

(١) شرح منهاج الطالبين لجلال الدين المحلي ج ٢ ص ٣٤٦ وبعدها ، نهاية المحتاج ج ٥ ص

٥٠ ، منهاج الطالبين ، السراج الوهاج ص ١٩١ ، فتح الوهاب شرح منهج الطلاب ج ١

«البيعان بالخيار ما لم يتفرقا»^(١) ، كما أن خيار الشرط يقاس على خيار المجلس ، والعاقده هو الوكيل ، فله الفسخ .

٥- مطالبة البائع للوكيل بالثمن ، فإذا اشترى الوكيل شيئاً لصالح موكله ، كأن وكله في شراء سيارة فاشترها ، فيجوز للبائع مطالبة الوكيل بالثمن ، وذلك في حالتين:

الأولى: إذا كان الموكل قد دفع الثمن للوكيل ، فهنا يجوز للبائع مطالبة الوكيل بالثمن ، سواء اشترى الوكيل بعين الثمن أم في الذمة ، لأن العرف يقتضي بذلك ، كما أن الوكيل هو المباشر للعقد وتتعلق أحكامه به .

الثانية: إذا كان الثمن في الذمة ولم يدفعه الموكل ، فيحق للبائع مطالبة الوكيل بالثمن أيضاً ، وذلك بشرط أن ينكر البائع هذه الوكالة أو يدعي عدم العلم بها ، لأننا في هذه الحالة نحكم بالظاهر الذي يفهم من خلاله أن من يباشر العقد يشتري لنفسه . أما إذا اعترف البائع بالوكالة ، فإن الأصح عند الشافعية أن له أيضاً مطالبة الوكيل بالثمن^(٢) ، لأنه مباشر للعقد وينوب عن موكله ، كما أن له مطالبة الموكل لأن الملك وقع له ، وفي هذه الحالة يكون الوكيل كضامن والموكل كأصيل . فإذا غرم الوكيل الثمن ، رجع على الموكل .

ووفقاً لما سبق ، فإذا كان الثمن معيناً ، ولم يدفعه الموكل إلى الوكيل ، فإن البائع لا يجوز له مطالبة الوكيل ، لأن حق البائع مقصور على الثمن المعين ، وهو ليس في يد الوكيل .

(١) صحيح البخاري ، كتاب البيوع ، رقم ٢٠٧٩ ، ٢٠٨٢ .

(٢) الوجه الثاني: مطالبة الموكل فقط ، لأن العقد والملك وقع له ، والوكيل مجرد سفير محض

الوجه الثالث: مطالبة الوكيل فقط ، لأن الالتزام وقع معه .

القيود الواردة على تصرف الوكيل

إن الوكيل وإن كان نائباً عن الموكل ، يتصرف لمصلحته في الأعمال التي تقبل النيابة ، إلا أن هذا التصرف مقيد بعدد من القيود التي ينبغي على الوكيل مراعاتها ، فيجب عليه موافقة مقتضيات الوكالة ، وأن يمثل تقيدات الموكل ، وألا يتصرف لنفسه أو لمن هم في كنفه ، وألا يوكل الوكيل غيره ، وذلك على النحو التالي:

القيد الأول: ضرورة موافقة مقتضيات الوكالة:

إن صحة تصرف الوكيل تقتضي أن يكون هذا التصرف موافقاً لمقتضيات الوكالة ، ولمقتضى اللفظ الصادر من الموكل أو القرينة . والموافقة والمخالفة يمكن معرفتها من خلال النظر إلى اللفظ تارة ، وبالقرائن تارة أخرى ، فقد تقوى القرينة أحياناً ، بحيث يترك لها إطلاق اللفظ ^(١) . كما لا يمكن إغفال أثر العرف في تحديد مقتضيات الإذن في الوكالة .

كما أن الوكيل مطالب في تصرفه - وفق مقتضيات الوكالة - بمراعاة الأحظ والأأنفع للموكل ، فيرى الشيرازي: أنه إذا تناول الإذن بالوكالة تصرفين ، وفي أحدهما أضرار بالموكل ، لم يجز ، لقوله صلى الله عليه وسلم «لا ضرر ولا ضرار» ^(٢) فإن تناول تصرفين ، وفي أحدهما نظر للموكل ، لزمه ما فيه النظر للموكل ، لما روى ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «رأس الدين النصيحة» قلنا يا رسول الله لمن؟ قال صلى الله عليه وسلم «لله ولرسوله ولكتابة ولأئمة المسلمين وللمسلمين عامة» ^(٣) ، وليس من

(١) روضة الطالبين ج ٣ ص ٥٣٦ .

(٢) الموطأ ، كتاب الأفضية ، باب القضاء في المرفق ، سنن الدارقطني ج ٣ ص ٧٧ .

(٣) مسلم في الإيمان ، أبو داود - كتاب الأدب ، باب في النصيحة رقم ٤٩٤٤ .

النصح أن يترك ما فيه الحظ والنظر للموكل ^(١) .

وتطبيقاً لما سبق ، وعلى سبيل المثال فإن مقتضيات الوكالة المطلقة في البيع والشراء تكون كما يلي:

أ - الوكالة المطلقة بالبيع:

إن الوكيل بالبيع مطلقاً ، أي توكيلاً لم يقيد بشيء ، يكون تصرفه موافقاً لمقتضى الإطلاق المفهوم من الوكالة ، بالشروط التالية ^(٢):

١ - أن يبيع بنقد البلد:

فيجب على الوكيل بمطلق البيع ، أن يبيع بنقد البلد ، فإذا كان في البلد نقدان ، لزم البيع بأغلبهما ، فإن استوى النقدان ، وجب على الوكيل البيع بأغلبهما للموكل ، فإن استوى النقدان في النفع ، تخير الوكيل بينهما . ويلاحظ أن المقصود بالبلد هنا ، هو بلد البيع ، لا بلد التوكيل ، ومن ثم فإذا سافر الوكيل بما وكل فيه وباعه في بلد آخر بغير إذن ، فإن المعول عليه نقد البلد الذي كان ينبغي عليه أن يبيعه فيها . ويمتنع على الوكيل أن يبيع ما وكل فيه بالعرض إلا إذا كان البيع بقصد التجارة ، فيجوز عندئذ البيع بالعروض .

وحجة الشافعية هو: أن البيع معاوضة بوكالة مطلقة ، فوجب ألا يصح بغير نقد البلد ، قياساً على الشراء ، فكما أن الوكيل في الشراء لا يصح له أن يشتري بغير نقد البلد ، فكذلك الوكيل في البيع لا يجوز له ذلك . كما أن البيع بنقد البلد هو ما تدل عليه القرينة العرفية .

٢ - أن يبيع بثمن حال:

فيجب على الوكيل بمطلق البيع أن يبيع بثمن حال غير مؤجل ، ومن ثم

^(١)المهذب مع تكملة المجموع ج ٣ ص ١٠٩ ، وبعدها .

^(٢)الحاوي ج ٨ ص ٢٣٥ ، وبعدها ، تكملة المجموع ج ١٤ ص ١٣٦ ، وبعدها .

فلا يجوز له البيع بنسيئة ، ولو كان أكثر من ثمن المثل ، لأن البيع بالنسيئة يكتفه الخطر . ويستثنى من هذا ما لو وكله بالبيع وقت نهب ، فيجوز له البيع نسيئة حفظاً من النهب ، أو لو وكله بالبيع في بلد معين أو سوق معين ، ويعلم الموكل أن أهل هذا البلد أو السوق لا يشترون إلا نسيئة ، فللوكيل أن يبيع بالنسيئة ^(١) ، لأن المصلحة تقتضي هذا .

وحجة الشافعية على اشتراط البيع بالثمن الحال ، وأن البيع بالثمن المؤجل لا يجوز هو: أن إطلاق الإذن يقتضي عدم صحة تأجيل الثمن من الوكيل قياساً على عدم صحة تأجيل المثل ، وذلك لأن الأجل في البيع يدخل تارة في المثل فيصبح سلماً ، وتارة يدخل الأجل في المثل فيصبح ديناً ، فإذا امتنع على الوكيل أن يدخل الأجل في المثل فيجعله سلماً ، امتنع عليه أيضاً أن يدخل الأجل في المثل فيجعله ديناً . كما أن مقتضى الإطلاق هو أن يكون الثمن حالاً وفقاً للغالب المعتاد .

(١) حاشية الشبراملسي مع نهاية المحتاج ج ٥ ص ٣١ .

٣ - ألا يبيع بغبن فاحش

فيجب على الوكيل في الوكالة المطلقة عن التقييد أن يبيع بضمن المثل ، ولا يجوز له أن يبيع بغبن فاحش . ويقصد بالغبن الفاحش: هو ما لا يحتمل غالباً ، بخلاف الغبن اليسير ، فإنه يغتفر في البيع ، حيث لا يخلو منه البيع .

ويعد العرف هو المرجع لمعرفة وجود الغبن من عدمه . وهذا عند الناس يختلف باختلاف الأزمان والأجناس ، فما يعد غبناً في جنس لا يعد كذلك في جنس آخر ، ولا يمكن تقدير ذلك بنسبة مئوية في كل أنواع البيع وأجناسه ، لأن العشرة إن تسومح بها في المائة ، فلا يتسامح بالمائة في الألف ، ولا بالألف في العشرة آلاف ، بل الصحيح الرجوع إلى العرف والعادة .

وحجة الشافعية على ما سبق هو: أن البيع عقد معاوضة بوكالة مطلقة ، فوجب ألا يصح بأقل من ثمن المثل ، قياساً على الشراء . كما أن الوكيل لا يملك البيع بالغبن الفاحش قياساً على كونه لا يملك الهبة ، لأنه عندئذ يكون قد استهلك شيئاً من مال موكله بغير إذنه ، فوجب أن يكون باطلاً كالهبة .

ب - الوكالة المطلقة بالشراء

إن الوكيل بالشراء مطلقاً ، أي توكيلاً لم يقيد بشيء ، يكون تصرفه موافقاً لمقتضى الإطلاق المفهوم من الوكالة بمراعاة الشروط السابقة - بتفصيلها - في الوكالة المطلقة بالبيع . بالإضافة إلى اشتراط ألا يشتري معيباً ، ومن ثم فيجب عليه في الشراء بالوكالة المطلقة أن يراعي الشروط التالية (١):

١- أن يشتري بضمن المثل ، أو أقل .

(١) حاشية البيجوري على شرح بن القاسم الغزي على متن أبي شجاع ج ١ ص ٥٧٤ ،

الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ج ٣ ص ١٧١ ، حاشية قليوبي ج ٢ ص ٣٤١ .

- ٢- أن يشتري بالثمن الحال .
- ٣- أن يشتري بنقد بلد الشراء .
- ٤- ألا يشتري معيباً .

فلا يجوز للوكيل في الوكالة المطلقة أن يشتري معيباً لأن الإطلاق الوارد في الوكالة يقتضي أن يكون المبيع سليماً من العيوب . وفي هذا يختلف الوكيل عن عامل القراض ، لأن شراء عامل القراض يهدف إلى الربح ، وقد يكون الربح في المعيب . أما شراء الوكيل فالأصل فيه أن يكون للقنية ، ومن ثم فشراء المعيب لا يحقق النفع والصالح للموكل . فإذا اشترى الوكيل المبيع المعيب ، فإن الشراء يصبح لازماً للموكل ويقع له الشراء إذا توافرت الشروط التالية:

- ١- أن يساوي المبيع مع العيب ما اشتراه به الوكيل .
- ٢- أن يجهل الوكيل العيب ، لأن جهله ينفي المخالف والتقصير . كما أن الموكل لا يتضرر بهذا العقد ، لأنه يحق له الرد بالعيب .
- ٣- ألا ينص الموكل على ضرورة شراء السليم ، وقد قال بهذا الشرط الأسنوي ، محتجاً لذلك بأن شراء المعيب غير مأذون فيه .

ووفقاً لهذه الشروط ، فإذا علم الوكيل بالعيب ، فالأصح عند الشافعية أن الشراء لا يقع للموكل ، لأنه غير مأذون في شراء المعيب وفقاً للعرف^(١) . كما أن الوكيل إذا علم أنه اشترى معيباً لا يساوي مع العيب ما شاتراهبه ، فإن الشراء لا يقع عن الموكل ، لأن الوكيل يعد مقصراً ، أما إن جهله ، فالأصح أنه يقع عن الموكل ، قياساً على ما لو اشتراه الموكل بنفسه جاهلاً .

وحيث قلنا بوقوع الشراء عن الموكل ، فإن لكل من الموكل والوكيل الرد بالعيب ، لأن الموكل هو المالك المضرور ، أما الوكيل فلأنه نائب عنه ، كما أن

(١) الوجه الثاني: إن الشراء يقع للموكل ، لأن الصيغة مطلقة ، ولا يوجد نقص في المالية بالنسبة للموكل ، حيث اشترى ما يساوي ذلك مع العيب .

منع الوكيل من الرد بالعيب يلحق به الضرر ، لأن رفض الموكل للمبيع عند تعذر الرد يترتب عليه أن يبقى المبيع المعيب للوكيل ، فيضرر به ، ولذا جاز له الرد .
ويلاحظ أن حق الموكل والوكيل في الرد بالعيب ، إنما يكون عند الشراء في الذمة ، أما إذا كان الشراء بعين مال الموكل ، فإن الشراء يقع للموكل أيضا بذات الشروط السابقة ، غير أن الوكيل في هذه الصورة لا يجوز له الرد بالعيب في الأصح ، حيث لا ضرر عليه ، إذ لا يمكن أن ينقلب العقد له (١) .

القيد الثاني - امتثال تقييدات الموكل .

يجب على الوكيل مراعاة تقييدات الموكل ، طالما كانت هذه التقييدات والشروط التي شرطتها الموكل لا تبطل العقد . أما إذا كانت هذه الشروط مبطلّة للعقد ، كالأجل المجهول ، أو الخيار أكثر من ثلاث ، أو الثمن المحرم ، فإن العقد يكون باطلاً ، لأن الإذن يكون بمباشرة العقد الفاسد ، والعقد الفاسد لا يصح وإن رضي المالك بفساده .

أما إذا كان القيد أو الشرط الذي شرطه الموكل في العقد يصح معه العقد ، فيجب على الوكيل مراعاة هذا الشرط ، ولا يجوز له مجاوزة هذا القيد أو العدول عنه ، إلا إذا كان في المجاوزة زيادة خير ونفع ، فيصح العقد ، ولا تكون الزيادة والمجاوزة في هذه الحالة مانعة من صحة العقد .

وتطبيقاً لما سبق ، فإن الشروط والقيود الصحيحة غير المبطلّة للعقد والتي يطلبها الموكل في عقد البيع على سبيل المثال ، يجب مراعاتها . وأن هذه القيود والشروط على ضربين (٢):

الضرب الأول: شروط وقيود تتعلق بأحوال العقد:

(١) روضة الطالبين ج ٣ ص ٥٤٢ ، وبعدها ، المهذب ج ١٤ ص ١٢٦ ، نهاية المحتاج ج

٥ ص ٣٧ ، مغني المحتاج ج ٢ ص ٣٠٥ .

(٢) الحاوي ج ٨ ص ٢٣٨ وبعدها ، روضة الطالبين ج ٣ ص ٥٤٦ وبعدها .

وذلك بأن يعين الموكل «شخصاً معيناً» أو «زماً معيناً» أو «مكاناً معيناً» ، فيقول: بع لزيد ، أو يوم الجمعة ، أو في سوق كذا ، ففي هذه الحالة يجب على الوكيل امتثال تقيد الموكل ، وتعين عليه البيع وفقاً لإذن الموكل .

ومرجع ذلك عند الشافعية ، أن الموكل قد يقصد شخصاً معيناً ويرغب في تخصيصه بتلك السلعة دون غيره ، فلا يصح عدول الوكيل عنه كالهبة ، كما أنه ربما يقصد البيع له ، لما يعلم عنه من الكسب الحلال ، وبعد أمواله عن الشبهات .

وعلى هذا لو مات الشخص المقصود لم يجز للوكيل البيع لورثته ولا لغيرهم . أما التقيد بزمن معين ، فقد يرى أنه في حاجة إلى البيع في هذا الزمن خاصة ، ومن ثم لا يجوز البيع قبله ولا بعده . أما التقيد بالمكان فقد يكون له غرض فيه ككون الراغبين في الشراء في هذا المكان أكثر ، أو يكون النقد فيه أجود .

وهناك وجه آخر للشافعية في تعيين المكان ، ذهب إليه القاضي أبو حامد وقطع به الغزالي حيث قالوا: إذا لم يتعلق بالمكان غرض صحيح ، فإنه لا يتعين . كما لا يتعين المكان إن قدر له الثمن ، إلا إذا نهاه الموكل صراحة عن البيع في غيره .

الضرب الثاني: قيود وشروط تتعلق بصفات العقد

وهذه القيود تتعلق «بجنس الثمن» «أو بقدره» ، أو «بزمانه من حلول وأجل» . فإن كان القيد مرتبطاً بجنس الثمن ، كأن يقول: بع سيارتي بالجنيه المصري ، فلا يجوز للوكيل أن يبيع بغيرها من ريالات أو دولارات أو عروض ، لأنه لم يأذن في ذلك .

وإذا كان القيد مرتبطاً بقدر الثمن كأن يقول: بع سيارتي بألف ، فلا يجوز للوكيل أن يبيع بأقل من الألف ولو بقدر يسير ، وإلا كأن البيع باطلاً ، لأن الأقل

من الألف لا يطلق عليها وصف الألف ، وهذا بخلاف النقص عن ثمن المثل فيما يتعابن به الناس عند الإطلاق ، لأن البيع مع الغبن المسموح به ، يطلق عليه ثمن المثل . ويجوز للوكيل في هذه الصورة أن يزيد في الثمن عن الألف المحددة ، لأن الزيادة أكثر نفعاً وحظاً للموكل . ومع ذلك لا تجوز الزيادة في حالتين:

- ١- أن يصدر نهي من الموكل عن الزيادة ، فتمتنع لأن اللفظ والنطق قد أبطل المفهوم من العرف .
- ٢- أن يأمره بالبيع بالثمن المحدد لشخص معين ، فلا يجوز أن يزيد عليه في الثمن عن الألف المحدد ، لأن الموكل لما نص على القدر ، صار مسامحاً له بالزيادة عليه ، وأنه قصد الرفق بالمشتري .

وأما التقييد المختص بزمان الثمن من حلول وتأجيل «فقد يأذن له بالبيع نقداً» ، و «وقد يأذن له في البيع بالنسيئة» ، «وقد يطلق الإذن» . فإن أذن له في البيع نقداً ، فلا يجوز للوكيل أن يبيعه مؤجلاً ولو كان الأجل قليلاً ، أو نافعاً للموكل . وأما إن أذن له في البيع بالنسيئة ، فلا يجوز له أن يتجاوز الأجل المحدد له ، فإن لم يحدد له الأجل ، فإن العرف هو المعتبر في تحديد هذا الأجل عند جمهور الأصحاب من الشافعية ويجوز أن يبيعه نقداً بما يساوي ثمنه نسيئة عند الشافعي ، لأن ذلك أنفع له ، بشرط ألا يكون ذلك وقت نهب أو سرقة ، أو يكلفه مؤنة لحفظه في الحال . وأما إذا أطلق الإذن ، فلم يطلب البيع نقداً ، أو نسيئة فيلزم الوكيل أن يبيع نقداً ، يقول الشيرازي «ولا يجوز للوكيل في البيع أن يبيع بثمن مؤجل من غير إذن ، لأن الأصل في البيع النقد ، وإنما يدخل التأجيل لكساد أو فساد ، فإذا أطلق حمل على الأصل» (١) .

القيد الثالث: عدم جواز التصرف لنفسه وموليه أو لمن في كنفه

(١) المهذب مع تكملة المجموع ج ١٤ ص ١٣٦ .

فلا يجوز للوكيل أن يتصرف لنفسه أو لمن في كنفه وموليه كولده الصغير ومحاجيره ، بالبيع أو الشراء مثلاً ، حتى وإن اذن الموكل له في ذلك .

وحجة الشافعية في هذا هو: - أن الأصل عدم جواز اتحاد الموجب والقابل (١) ، حتى وإن انتقت التهمة ، بذليل أنه لو وكله ليهب من نفسه لم يصح لاتحاد الموجب والقابل . كما أن الإنسان مجبول على تغليب حظ نفسه وحظ من هم في كنفه على حظ غيره ، وفي هذا تناقض وتضاد بين غرض الاسترخاص لنفسه ولولده الصغير ، وبين غرض الاستقصاء وطلب الأحظ لموكله .

وقال ابن سريج من الشافعية : - يجوز للوكيل أن يتصرف لنفسه بالبيع والشراء إذا أذن له الموكل في هذا البيع أو الشراء ، وذلك قياساً على الرجل الذي يجعل لزوجته طلاقاً نفسها ، أو يجعل إلى أمته عتق نفسها .

وقد اعترض الماوردي على ما ذهب إليه ابن سريج ، لوجود العديد من الفوارق بين البيع ، وبين الطلاق والعتق ، وأهم هذه الفروق ما يلي:

١- أن البيع يشتمل على ثمن قد يزيد وينقص ، ومن ثم فإن ميل الوكيل إلى نفسه وموليه ، يجعله متهوماً في نقصان الثمن ، أما في الطلاق والعتق فلا يوجد ثمن حتى تصبح المرأة متهومة بالميل إلى نفسها .

٢- أن البيع أضيق حكماً من الطلاق والعتق ، لأن الطلاق يقع بالصفات على الغرر والجهالات .

٣- أن القبول غير معتبر في الطلاق والعتق ، حيث لا يلزم مثلاً قبول المرأة في الطلاق . أما البيع فإن القبول معتبر ، ومن ثم فلا يجوز أن يكون البازل الموجب ، قابلاً في ذات الوقت والعقد .

(١) وقد خرج الأب من هذا الأصل على سبيل الاستثناء ، فيجوز له مبايعة نفسه ، لأن الأب مجبول بحنوة الأبوة على طلب الأحظ لولده ، والشح على نفسه ، ولذا قال صلى الله عليه وسلم "الولد مبخله مخزنة مجبنة" فاننتقت التهمة عنه في البيع لنفسه .

التصرف لأصوله وفروعه المستقلين:

يجوز تصرف الوكيل لأصوله كالأب وإن علا ، وفروعه المستقلين كالإبن البالغ الرشيد ، وذلك بشرط أن ينص على ذلك الموكل أو يأذن فيه . أما إذا كان التوكيل بالبيع مطلقاً ، دون نص أو إذن في التصرف لأصوله وفروعه المستقلين ، فقد اختلف الشافعية في ذلك على وجهين (١):

الوجه الأول: وهو الأصح ، أنه يجوز للوكيل البيع المطلق أن يبيع لأبيه وسائر أصوله ، وأبنه البالغ الراشد وسائر فروعه المستقلين ، وذلك استدلالاً بما يلي:

- ١- عدم اتحاد الموجب والقابل ، لأن الموجب هنا يختلف عن القابل ، وذلك على عكس صورة بيع الوكيل لنفسه حيث اتحد الموجب والقابل .
- ٢- أن البيع بثمن المثل ينفي التهمة ، كما لو باع لأجنبي أو لصديق .

الوجه الثاني: أنه لا يجوز للوكيل بالبيع المطلق أن يبيع لأصوله وسائر فروعه المستقلين لأنه متهم بالميل إليهم ، كما أن القياس يمنع من هذا التصرف ، حيث قاسوا تصرف الوكيل لأصول وفروعه المستقلين على ما لو فوض إليه الإمام أن يولي القضاء من شاء ، فإنه لا يجوز له أن يختار أصوله وفروعه ، فكذا هنا لا يتصرف إليهم .

ويجاب عن هذا الوجه: بوجود فارق بين تصرف الوكيل بالبيع والشراء من الأصول والفروع المستقلين ، وبين اختيارهم للقضاء ، لأن التهمة في الوكيل تنتفي بوجود ثمن المثل ، كما أن الاختيار للقضاء يتضمن تزكية لأصوله وفروعه ، وهذا بخلاف الوكالة .

(١) الحاوي ج ٨ ص ٢٣٣ وبعدها ، إعانة الطالبين ج ٣ ص ٩٠ ، مغني المحتاج ج ٢ ص

ويلاحظ أن ما يجري في وكيل البيع يجري في وكيل الشراء (١) .

القيد الرابع: منع توكيل الوكيل غيره:

الأصل عند الشافعية هو أن يتولى الوكيل بنفسه مباشرة العمل الموكل فيه ، دون أن يوكل في ذلك غيره . وحجة الشافعية في ذلك هو أن الموكل لم يرض بتصرف غير الوكيل ، كما أن الإذن لا يتناول تصرف غيره من جهة النطق ، ولا من جهة العرف ، فضلا عن ذلك فإنه لا توجد ضرورة تدعو الوكيل إلى التوكيل ، وبجانب ذلك فإن قياس الوكيل على المودع يمنع من توكيله غيره ، فكما أن المودع لا يودع عند غيره ، فكذلك الوكيل لا يوكل غيره . ويستثنى من الأصل السابق حالات يجوز فيها للوكيل أن يوكل غيره ، ومن أهم هذه الحالات ما يلي (٢):

الحالة الأولى: إذا كان الوكيل لا يتأتى منه الإتيان بالموكل فيه .

وتتحقق هذه الحالة إذا كان الوكيل لا يحسن العمل الموكل فيه ولا يعرف صنعته ، أو إذا كان العمل الموكل فيه لا يليق بأمثاله حتى وإن كان يحسنه . ومن أمثلة ذلك الوكيل في بناء منزل ، وهو لا يحسن فنون العمارة والتشييد ، فإنه يحتاج إلى التوكيل فيها . وكذلك الوكيل في غسل الثياب والنداء على ضالة ، إن كان لا يليق بمثله عرفا عمل ذلك ، فله أن يوكل غيره . وحجة الشافعية في ذلك هو أن تفويض الوكيل مع العلم بكونه لا يتأتى منه الإتيان بالموكل فيه ، يقصد منه أن يستتبع غيره .

الحالة الثانية: عدم قدرة الوكيل على التفرد بالعمل الموكل فيه .

(١) حاشية عميرة ج ٢ ص ٣٤٢ ، نهاية المحتاج ج ٥ ص ٣٦ .

(٢) المهذب مع شارحه تكملة المجموع ج ١٤ ص ١١٠ وبعدها ، الحاوي ج ٨ ص ٢١١ ،

روضة الطالبين ج ٣ ص ٥٤٤ .

وتتحقق هذه الحالة عندما تكثر الأعمال الموكلة فيها ، وتتعدد التصرفات المطلوبة من الوكيل بحيث يعجز عن القيام بها منفرداً ، كما لو كان التوكيل بعمارة ضيعة كبيرة أو بناء عمارة سكنية ، فالمذهب عند الشافعية أن للوكيل أن يوكل فيما يزيد على قدرته الممكنة ، ولا يجوز له أن يوكل في الممكن المقدور عليه لأن الضرورة التي دعت إلى جواز التوكيل في غير الممكن ، فينبغي أن تقدر الضرورة بقدرها وتقف عند حدود جواز التوكيل في العمل غير المقدور على الإتيان به . وهناك وجه آخر عند الشافعية أنه يجوز للوكيل أن يوكل في الجميع على اعتبار أن من ملك التوكيل في البعض ، يملك التوكيل في الكل .

الحالة الثالثة: أن يأذن الموكل للوكيل بالتوكيل

وتتعدد صور هذا الإذن ، فقد يكون الإذن للوكيل بالتوكيل عن نفسه ، فيصبح الوكيل الثاني وكيلاً للوكيل الأول ، فإذا عزل الموكل الوكيل الأول ، انعزل الوكيل الثاني أيضاً ، كما ينعزل بانعزاله بالموت أو الجنون على الأصح . وقد يكون الإذن للوكيل بالتوكيل عن الموكل ، كقوله «وكل عني» ، ففي هذه الصورة يكون الوكيل الأول والثاني وكيلين للموكل ، ومن ثم لا يجوز للوكيل الأول أن يعزل الوكيل الثاني كما أن الوكيل الثاني لا ينعزل بعزل الوكيل الأول ولا بانعزاله . ومثل هذه الصورة في الأصح مألوفة أطلق الموكل الإذن ، فقال «وكل» دون أن يقول: عني أو عنك .

وتبقى ملاحظة ، وهي أنه في الحالات التي يجوز للوكيل فيها أن يوكل غيره ، فإنه يجب على الوكيل أن يختار ثقة أميناً رعاية لمصلحة الموكل ، فإن وكل خائناً أو فاسقاً لم يجز . ويستثنى من هذا مألوفة عين الموكل للوكيل رجلاً بعينه فليس للوكيل توكيل غيره ، ولو لم يكن ثقة أميناً ، لأن التحديد من قبل الموكل قطع نظر واجتهاد الوكيل في الاختبار . فإذا وكل الوكيل شخصاً ثقة أميناً دون تعيين من الموكل ، ثم أصبح خائناً ، فإن مقدرة الوكيل الأول في عزله على وجهين:

الوجه الأول : وهو الأصح ليس للوكيل الأول عزل الوكيل الثاني ، لأنه إذن في التوكيل ، دون العزل .

الوجه الثاني: أن للوكيل الأول عزل الوكيل الثاني دون استئذان الموكل ، لأن تركه يتصرف مع الخيانة والفسق تضييع وتقريط ، والوكالة تتطلب استئذان أمين ، وهذا ليس بأمين فوجب عزله ، ولأن الإذن المطلق يقتضي توكيل ثقة عدل .

الاختلاف في الوكالة

هناك العديد من الخلافات والمنازعات قد تنثور في عقد الوكالة ، فقد يقع النزاع في أصل الوكالة أو في صفتها ، أو في الرد ، أو في الإتيان بالتصرف المأذون فيه . . إلخ ، فإذا ما حدث الخلاف ، فإن الموكل يصدق في بعض الحالات ، بينما يصدق الوكيل في حالات أخرى ، كما يلي:

أولاً: حالات تصديق الموكل:

إذا ما حدث نزاع أو ثار خلاف بين الموكل والوكيل ، فإن الموكل يقبل قوله ويصدق في دعواه ، وذلك في الحالات الآتية:

أ - الاختلاف في أصل الوكالة:

قد يختلف الموكل والوكيل في أصل الوكالة ، وصورة هذا أن يقول الوكيل: وكلتني في كذا ، فينكر الموكل الوكالة . ففي هذه الحالة إذا كان الاختلاف قد نشأ قبل وقوع التصرف من الوكيل ، فإن هذا الاختلاف يكون بمثابة عزل له ، لأن تعمد إنكار الوكالة وجدها من قبل الموكل يعتبر من قبيل العزل ، ومن ثم فلا حاجة للمخاصمة .

أما إذا كان الاختلاف في أصل الوكالة قد نشأ بعد حصول التصرف من الوكيل ، فإن المعول عليه هو قول الموكل ويصدق بيمينه ، لأن الأصل عدم

الوكالة ، فعلى من يدعي وجودها أن يقيم البينة على ذلك . فإذا لم يحلف الموكل ، أو أقام الوكيل بينه بما قاله ، ثبت الشراء للموكل (١) .

ب - الاختلاف في صفة الوكالة

وصورة هذا أن يقول الوكيل: وكلتني في البيع نسيئة أو في الشراء بعشرين ، فيقول الموكل: بل نقداً أو بعشرة ، أو يقول الوكيل: أمرتني بإعطاء زيد ألفاً ، فيقول الموكل: بل أمرتك بإعطائه ثوباً ، ففي هذه الحالة يصدق الموكل بيمينه ، ولا تقبل دعوى الوكيل إلا ببينة يقيمها على إدعائه ، لأن الموكل ينكر إذن الأصل عدمه ، كما أن الموكل أعرف بحال الإذن الصادر منه ، وهذا معنى قولهم «من كان القول قوله في شيء ، كان القول قوله في صفة ذلك الشيء» (٢) ، كالزوج في الطلاق (٣) .

وتبقى ملاحظة ، وهي أنه في صورة ما إذا باع الوكيل مؤجلاً ، وادعى الإذن من الموكل في البيع نسيئة ، بينما أنكر الموكل الإذن بالأجل ، وقال: ما أذنت إلا بالبيع في الحال ، فإن السؤال الذي يفرض نفسه هو: طالما قلنا إن القول قول الموكل ، فهل يسترد المبيع ، أو أن المشتري يأخذه؟ للإجابة على هذا السؤال بفرق الشافعية بين حالتين:

الحالة الأولى: أن ينكر المشتري علمه بالوكالة ، ففي هذه الحالة يجب على الموكل إقامة البنية على علم المشتري بالوكالة ، فإن عجز الموكل عن إقامته البينة ، فالقول قول المشتري مع يمينه على نفي العلم بالوكالة ، فإن حلف المشتري بقى المبيع في يده ، ورجع الموكل على الوكيل بقيمة المبيع أو مثله إن كان مثلياً . ثم يرجع الوكيل على المشتري عند حلول الأجل مؤاخذه له بمقتضى

(١) حاشية قليوبي علي شرح منهاج الطالبين ج ٢ ص ٣٤٨ .

(٢) حاشية عميرة ج ٢ ص ٣٤٨ .

(٣) المهذب مع تكملة المجموع ج ١٤ ص ١٥٩ .

تصرفه . وإن نكل المشتري فترد العين على الموكل .

الحالة الثانية: أن يعترف المشتري بالوكالة ويصدق الموكل في دعواه بأنه ما أذن في البيع نسيئة أو مؤجلاً ، ففي هذه الحالة يكون البيع باطلاً ، وعلى المشتري رد المبيع إلى الموكل ، فإن تلف ، رجع الموكل على الوكيل أو المشتري .

أما إذا اعترف المشتري بالوكالة ، وصدق الوكيل في دعوى الإذن بالبيع مؤجلاً ، فالقول قول الموكل بيمينه ، فإن حلف أخذ العين ، وإن نكل ، حلف المشتري وبقيت له العين المباعة (١) .

ج - الاختلاف في الإتيان بالتصرف:

قد يختلف الموكل والوكيل في الإتيان بالتصرف المأذون فيه ، ويحدث هذا إذا وكله في عمل ، فيدعي الوكيل الإتيان به على الوجه المأذون فيه ، وينكر الموكل ذلك . ومن أمثلة هذا أن يوكله في بيع أو نكاح أو طلاق فيدعي الإتيان به ، وينكر الموكل هذا ، ففي هذه الحالة إذا وقع الخلاف بعد عزل الوكيل ، فالمصدق هو الموكل لأن الوكيل لا يملك إنشاء التصرف حينئذ . أما إذا وقع الخلاف قبل العزل ، فقد حكى قولان في ذلك عن الإمام الشافعي رحمه الله ، ووجهان ذكرهما ابن سريج ، كما يلي (٢):

القول الأول: يصدق الموكل في جميع ذلك ، وأن القول قوله ، إلا أن يقيم الوكيل البينة على ما يدعيه ، مع ملاحظة أن البينة المعتبر ينظر فيها إلى المشهود فيه من كونه مالاً أو لا ، وإنما يصدق الموكل ، لأن الأصل عدم التصرف ، وبقاء ملك الموكل ، كما أن العقوة لا تلزم بمجرد الدعوى ، بل هي في

(١) روضة الطالبين ج ٣ ص ٥٦٧ وبعدها .

(٢) الحاوي ج ٨ ص ٢١٥ ، المهذب مع تكملة المجموع ج ١٤ ص ١٥٩ ، مغني المحتاج ج

٢ ص ٣١٧ وبعدها .

حاجة إلى البينة لإثباتها .

القول الثاني: إن القول في جميع ذلك قول الوكيل ، لأن الموكل أقامة مقام نفسه وجعله أمينه ، فينفذ قوله عليه ، ولأن الوكيل يملك العقد والقبض ، ومن يملك التصرف والإنشاء ، يملك الإقرار به ، كالأب في تزويج البكر .

والوجه الأول ، حكاه ابن سريج وهو: إن كان التصرف الذي أقر الوكيل بالإتيان به ، يتم به وحده كالطلاق والإبراء ، فإن قوله يكون مقبولا ، لأنه يستطيع ويصح الإتيان به في الحال من الوكيل دون حاجة إلى موافقة المرأة أو المدين ، ولذا يصح إقراره به . أما إذا كان لا يصح منه الإتيان وحده بالتصرف كالبيع والشراء ، فإن إقراره به لا يكون مقبولا .

الوجه الثاني: وهو ما اعتمده ابن سريج ، وهو تصديق الوكيل في التصرفات التي يعتبر الإقرار بها كإيقاعها ، مثلا الطلاق ، لأن الإقرار به يعد إيقاعا له ولو لم يسبق حدوثه . أما التصرفات التي لا يعتبر الإقرار بها كإيقاعها ، فلا يقبل قول الوكيل في الإتيان بها ، إلا بالبينة .

ثانياً: حالات تصديق الوكيل:

يرى الشافعية أن الوكيل يكون مقبول القول ويصدق فيما يدعي عند الاختلاف في عقد الوكالة ، وذلك في الحالات الآتية:

أ - الاختلاف في التلف:

إن الوكالة من عقود الأمانة ، ومن ثم فإن يد الوكيل يد أمانة ، لا يضمن إلا بالتعدي أو بالتفريط .

فإذا ادعى تلف المال في يده ، ولم يذكر سببا ، أو ذكر سببا خفيا كالسرقة ، فإنه يصدق في دعواه التلف بيمينه ، لأنه أمين كالمودع ويجري فيه

التفصيل المذكور في الوديعة ^(١) . ولا يكلف الوكيل بإقامة البينة على التلف لتعذر هذا .

أما إذا ادعى للتلف سبباً ظاهراً كحريق عرف بعمومه لا يحتمل معه سلامة المال ، فإن الوكيل يصدق في دعواه التلف بلا يمين ، لأن ظاهر الحال يغنيه عن اليمين .

ب - الاختلاف في الرد:

قد يقع الخلاف بين الموكل والوكيل في رد المال ، فيدعي الوكيل رد المال إلى الموكل ، بينما ينكر الموكل هذا الرد . ففي هذه الحالة يصدق الوكيل بيمينه في دعواه إن لم تبطل أمانته ^(٢) ، ويقبل قوله في الرد قطعاً إن كانت الوكالة بغير جعل ، لأنه أخذ العين لنفع الموكل ، فكان القول في الرد قوله ، قياساً على المودع . وأما إن كانت الوكالة بجعل وأجر ، ففي قبول قول الوكيل بالرد وجهان عند الشافعية:

الوجه الأول: لا يقبل قوله ، لأنه قبض العين لمصلحة نفسه ومن أجل نفعه ، فلا يقبل قوله في الرد قياساً على المستأجر والمرتهن .

الوجه الثاني: يقبل قوله في الرد ، لأن أخذه العين لنفع المالك ، أما انتقاعه هو ، إنما هو بالعمل في العين ، لا بالعين نفسها .

ويلحظ أن دعوى الوكيل الرد تكون مقبولة على الموكل فقط ، ومن ثم لا يقبل قوله بالرد على رسول الموكل بلا خلاف عند الشافعية ، لأنه لم يأت منه ، بل المصدق هنا رسول الموكل بيمينه . ولا يلزم الموكل على الصحيح تصديق الوكيل

(١) مغني المحتاج ج ٣ ص ١١٦ .

(٢) أما إذا بطلت أمانته بالجحد والإنكار ، فأقام عليه الموكل البينة ، فأدعى الرد ، فلا يقبل قوله ، لأنه بالإنكار والجحد قد يطلب أمانته ، فلا يقبل قوله .

إلا بالبينة . وقيل يلزمه لأنه معترف بالرسالة ، ويد رسوله يده ، فكأنه أدعى الرد عليه^(١) .

ج - الاختلاف في التعدي والتفريط:

قد يختلف الموكل والوكيل في تعدي الوكيل أو تفريطه في الحفظ ، أو مخالفته تقيدات موكله ، فيدعي الموكل أن الوكيل استعمل المال لنفسه ، وأنه فرط في الحفظ ... إلخ ... ، فالقول في هذه الحالة قول الوكيل مع يمينه ، لأنه أمين ، كما أنه ينكر دعوى التفريط ، والقول قول المنكر بيمينه^(٢) ، بجانب هذا فإن الموكل يحاول أن يقلب يد الوكيل من الأمانة إلى الضمان ، فيقع عليه عبء الإثبات .

جواز الوكالة وأسباب ارتفاعها

جواز الوكالة:

إن عقد الوكالة من العقود الجائزة غير اللازمة ، بمعنى أنه يجوز لكل من المتعاقدين فسخ العقد بإرادته المنفردة ، دون أن يتوقف هذا الفسخ على إرادة الطرف الآخر . ومرجع اعتبار عقد الوكالة من العقود الجائزة غير اللازمة ، هو مراعاة مصلحة الموكل والوكيل ، لأن الموكل قد تظهر مصلحته في ترك الوكالة في ما وكل فيه ، أو استبدال الوكيل بشخص آخر أكفاً منه ، كما أن الوكيل قد يرى أن من مصلحته فسخ الوكالة نظراً لعوارض تمنعه من العمل ، أو مراعاة لفرغه ووقته ، ومن ثم فإن القول بلزوم عقد الوكالة يكون أمراً مضراً بالموكل والوكيل . ومع القول بجواز عقد الوكالة ، فإن الشافعية يقولون بلزومها فيما يلي:

(١) المهذب مع تكملة المجموع ج ١٤ ص ١٦٥ ، مغني المحتاج ج ٢ ص ٣١٨ ، روضة

الطالبين ج ٣ ص ٥٦٨ .

(٢) تكملة المجموع ج ١٤ ص ١٦٦ .

- ١- إذا عقدت بلفظ الإيجارة ، فإنها تصبح من العقود اللازمة .
- ٢- إذا كانت الوكالة بجعل معلوم . فمن يرى أن العبرة في العقود بمعانيها ، يرى أنها تصبح عقداً لازماً ، لأنها تعتبر من قبيل الإجارة ، ومن يرى أن العبرة بصيغ العقود وألفاظها ، يرى أنها تعتبر وكالة جائزة غير لازمة ، وهذا ما رجحه الروياني والجويني من الشافعية .

ارتفاع وانتهاء الوكالة:

هناك أسباب لارتفاع وانتهاء عقد الوكالة ، أهمها (١):

١ - عزل الموكل للوكيل:

الأصل أن الموكل يملك سلطة عزل الوكيل . ويستثنى من هذا ما لو علم الموكل بأن العزل يترتب عليه مفسدة كبيرة ، كما لو وكل في مال المولى عليه ، وعلم أن عزل الوكيل سوف يفضي إلى أن يستولي ظالم على مال المولى عليه . أو كما لو وكل في شراء ماء ليتطهر به أو ثوب ليستر به عورته ، فلا يجوز له عزل الوكيل إن علم أن العزل لا يتيسر من خلاله الحصول على الماء أو الثوب (٢) .

ويقع عزل الموكل للوكيل بلفظ يدل على ذلك ، كقوله عزله ، أو رفعت الوكالة ، أو فسختها ، أو أبطلتها . ولا خلاف بين الشافعية في أن الموكل إذا عزل الوكيل في حضوره ، انعزل منها في الحال ، وأما إذا عزله وهو غائب ، فقد وقع الخلاف بين الشافعية على قولين:

(١) روضة الطالبين ج ٣ ص ٥٨٨ : ٥٦٠ ، شرح منهاج الطالبين لجلال الدين المحلي ج ٢

ص ٣٤٧ ، ٣٤٨ ، مغني المحتاج ج ٢ ص ٣١٣ : ٣١٥ .

(٢) حاشية الشبراملسي ج ٥ ص ٥٢ .

القول الأول: وهو الأظهر أن الوكيل ينعزل في الحال ولو لم يبلغه الخبر ، وقد استدلت الشافعية على صحة هذا القول بالقياس ، فقد قاسوا عقد الوكالة على الطلاق ، لأن الموكل لما كان لا يحتاج إلى رضا الوكيل في عزه ، مثل الرجل لا يحتاج إلى رضا المرأة في الطلاق ، فلم يحتج لعلم الوكيل بالنعزل حتى تنتهي الوكالة ، كما لم يحتج لعلم المرأة بالطلاق حتى يقع .

ووفقاً لهذا القول ، فإنه ينبغي للموكل أن يشهد على العزل ، لأن قول الموكل بعد تصرف الوكيل: كنت عزلته ، لا يقبل .

القول الثاني: أن الوكيل لا ينعزل حتى يبلغه الخبر ، ممن تقبل روايته وخبره ، دون الصبي والفاسق ، وقد استدلت أنصار هذا القول بقياس الوكيل على القاضي ، فكما أن القاضي لا ينعزل حتى يبلغه الخبر ، فكذلك الوكيل .

ويجاب عن هذا بما قاله أنصار القول الأول من أن قياس الوكيل على القاضي غير مسلم لوجود الفارق بينهما ، لأن المصالح الكلية تتعلق بالقاضي ، فيؤدي نقض الأحكام وفساد الأنكحة التي يعقدها إلى ضرر عظيم لا يمكن احتماله ، وهذا بخلاف الوكيل .

٢ - عزل الوكيل نفسه:

فالأصل أن الوكيل يملك سلطة عزل نفسه ، وذلك بقوله عزلت نفسي ، أو رددت الوكالة ، أو فسختها ، أو أبطلتها ، حتى ولو كان عقد الوكالة قد تم بصيغة الأمر ^(١) ، ودون نظر إلى كون الموكل غائباً أو حاضراً ، لأن الموكل لا يعتبر رضاه ، فلا يعتبر حضوره كالمرأة في الطلاق . ويلاحظ أن الوكيل وإن كان يملك

(١) ذهب بعض المتأخرين من الشافعية إلى القول بأن عقد الوكالة إذا تم بصيغة الأمر مثل بيع ، واشتر ، فإن الوكيل لا ينعزل برد الوكالة ، لأن صيغة الأمر في الوكالة إذن وإباحة ، فأشبه ما لو أباح الطعام لغيره ، فإنه لا يرتد برد المباح له ، يراجع: روضة الطالبين ج ٣ ص ٥٥٨ .

عزل نفسه ، إلا أنه يحرم عليه ذلك في غيبة الموكل إن علم أن العزل سيؤدي إلى أن يستولي على المال شخص جائر أو ظالم .

٢ - الخروج عن أهلية التصرف:

فينعزل الوكيل بخروجه أو خروج الموكل عن أهلية التصرف ، بموت أو جنون ، حتى وإن كان الجنون مؤقتاً غير ممتد ، لأن الجنون لو قارن صيغة انعقاد الوكالة لأبطلها ، فإذا طرأ على العقد أبطله وقطعه من باب أولى .

كما ينعزل الوكيل بإغماء الموكل في الأصح إلحاقاً للإغماء بالجنون ، عدا الوكيل في رمي الجمار ، فلا ينعزل بإغماء الموكل ، لأن الإغماء هنا زيادة في عجزه ، والعجز هو المشترك لصحة الإنابة هنا . ومقابل الأصح الذي اختاره الرافعي والسبكي والغزالي أن الإغماء لا يؤدي إلى العزل لأن المغمى عليه لم يلتحق بمن يولى عليه .

كذلك فإن الحجر بفلس أو سفه يرفع الوكالة في التصرف التي لا تنفذ فيها تصرفات المحجور عليه ، وقد صور ذلك البجرمي بقوله «بأن وكله إنسان ليشتري له شيئاً بعين ماله - أي مال الوكيل - ثم حجر على الوكيل قبل الشراء ، فينعزل لأن شراؤه بماله للموكل أما قرض أو هبة ، وهو ممنوع منهما^(١) . وكذلك فإن الفسق فيما يشترط فيه العدالة كالنكاح يترتب عليه رفع الوكالة وعزل الموكل والوكيل .

٤ - خروج محل التصرف عند ملك الموكل:

فينعزل الوكيل بخروج محل التصرف عن ملك الموكل ، فلو أن الموكل باع أو وقف محل التصرف ، فإن الوكالة ترفع ، وكذلك الأمر لو أجر محل التصرف الذي وكل في بيعه ، لأن الإجارة علامة ندم وتراجع من الموكل في

(١) بجرمي علي الخطيب ج ٣ ص ١٧٠ .

البيع ، باعتبار أن من يريد البيع لا يؤجر ، لقلة الراغبين في شراء العين المؤجرة .

٥ - تعمد جحد الوكالة .

فإذا حدث جحد وإنكار للوكالة ، فيجب أن نفرق بين ما إذا كان الإنكار والجحد من الموكل أو الوكيل قد صدر عن قصد وعمد ، أو أن هذا الإنكار يرجع إلى النسيان أو إلى غرض مشروع في الإخفاء . فيرى الشافعية أن الوكالة ترفع إذا تعمد الوكيل أو الموكل إنكار الوكالة وجحودها دون غرض في الإخفاء لأن هذا الجحد بمثابة رد لهذه الوكالة . أما إذا كان الجحد نسيانا ، أو كان الإنكار يرجع إلى غرض مشروع كإخفاء الموكل فيه من ظالم يريد أخذه ، فإن هذا لا يعد من قبيل العزل .

الفصل الثاني

المساقاة^(١)

المبحث الأول

حقيقة ومشروعية عقد المساقاة

حقيقة المساقاة .

المساقاة لغة: مأخوذة من "السَّقَى" بفتح السين، سكون القاف، والاسم: السُّقْيَا بالضم، والجمع: الأسقية. ويقال: ساقى فلان فلانًا نخله، أو كرمه: إذا دفعه إليه، واستعمله فيه على أن يعمره، ويسقيه، ويقوم بمصلحته من الإبار وغيره. وأهل العراق يسمونها المعاملة^(٢)، وسميت مساقاة؛ لأن غالب العمل المقصود فيها هو السقي، فاشتق اسمها منه.

وشرعًا: عرفها الإمام النووي بقوله: "هي أن يعامل إنسانًا على شجرة؛ لتعهددها بالسقي والتربية، على أن ما رزق الله تعالى من الثمرة يكون بينهما". وعرفها صاحب مغني المحتاج بأنها: "أن يعامل غيره على نخل، أو شجر عنب؛ ليتعهدده بالسقي، والتربية، على أن الثمر لهما^(٣)".

والفارق بين التعريفين: هو أن مورد المساقاة في التعريف الأول قد جاء عامًا. بينما في التعريف الثاني، جاء مقيدًا مبيّنًا للشجر بأنه عنب، أو نخل. ويمكن

^(١) كتبه: أ. د/ محمد عامر.

^(٢) لسان العرب، مادة (سقى) ٣/٢٠٤٢، ٥/٢٠٤٥.

^(٣) روضة الطالبين ٤/٢٢٦؛ مغني المحتاج ٢/٣٢٢.

القول: إن التعريف الأول قد جاء متفقاً مع المذهب القديم للشافعي؛ حيث كان يجيز المساقاة على كل الشجر، بينما يتفق التعريف الثاني مع المذهب الجديد للشافعي؛ حيث قصر المساقاة على النخل، والعنب، كما سنرى.

حكم ودليل مشروعية المساقاة

الحكم التكليفي للمساقاة .

ثمة رأيان في حكم المساقاة كما يلي :

الرأي الأول: جواز المساقاة .

ذهب الشافعية إلى أن المساقاة جائزة ومشروعة، وهذا هو رأي جمهور الفقهاء من الحنفية - عدا أبو حنيفة - والمالكية، والحنابلة. ولا يعرف خلاف بين الصحابة، والتابعين في جوازها.

وقد استدلت الشافعية ومن وافقهم من جمهور الفقهاء على جواز المساقاة ومشروعيتها بالسنة، والإجماع، والقياس، والمعقول.

أولاً: من السنة:

١ - خبر الصحيحين أنه p "عامل أهل خيبر"، وفي رواية "دفع إلى يهود خيبر نخلها، وأرضها، بشرط ما يخرج من زرع، أو ثمر^(١)".

٢ - روى الشافعي τ - عن مسلم بن خالد، عن عبد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أن رسول الله - p - حين افتتح خيبر قالت

(١) الأموال ، لأبي عبيد ، ص : ٨٢ ، ٨٣ ، الخراج ص ٥٥،٥٤ .

اليهود: نحن نقوم لكم بالعمل في النخل، قال: فدفع رسول الله -ﷺ- إليهم يعملونها، ويقومون بها، على أن لرسول الله -ﷺ- شطر الثمر، ولهم الشطر، فكان رسول الله -ﷺ- يبعث من يخرصها عليهم، فيأخذونها، ويؤدون الشطر^(١)، فهذه الأحاديث واضحة الدلالة على جواز المساقاة.

ثانيًا : الإجماع .

ومما يدل على جواز المساقاة إجماع الصحابة. وهذا الإجماع منعقد عن سيرة أبي بكر الصديق -رضي الله عنه- وسيرة عمر -رضي الله عنه- في مساقاة أهل خيبر بعد رسول الله -ﷺ- اتباعًا لرسول الله -ﷺ- إلى أن حدث من إجلائهم ما حدث في زمن عمر -رضي الله عنه-.

ثالثًا : القياس .

فيستدل الفقهاء على مشروعية المساقاة بقياسها على القراض من وجهين:

١- إن الأمة مجمعة على جواز القراض، وهذا الإجماع إما أن يكون حكمه مأخوذًا من نص، أو اجتهاد يرد إلى أصل، وليس في المضاربة توقيف نص، فلم يبق إلا اجتهاد أدى إلى إلحاقه بأصل، وليس في المضاربة أصل ترد إليه إلا المساقاة، فإذا كانت المساقاة أصلًا لفرع مجمع عليه، وهو المضاربة، كانت المساقاة أحق بالإجماع عليها.

٢- إنه لما جازت المضاربة إجماعًا، وكانت عملاً على عوض مظنون من ربح مظنون، فإن المساقاة تكون أولى بالجواز؛ لأنها عمل على عوض معتاد، من ثمرة غالبية^(٢).

(١) أخرجه أبو داود، ١٥٧/٣، ومعناه في صحيح البخاري، باب المزارعة مع اليهود، ٢٨١/٥.

(٢) الحاوي الكبير، ١٦٣/٩.

رابعًا : المعقول .

إن المعقول يؤكد مشروعية المساقاة؛ لأن الحاجة داعية إلى المساقاة، فقد يكون مالك الأشجار قليل الخبرة، لا يحسن تعهدها، أو يكون ضيق الوقت لا يتفرغ له، كما أنه قد لا يملك مالا حالا ليكتري عليها. وفي المقابل قد يكون من يملك الخبرة والوقت غير مالك للأشجار، فيحتاج كل منهما إلى الآخر^(١).

الرأي الثاني: عدم جواز المساقاة .

ذهب أبو حنيفة رحمه الله تعالى - إلى القول بإبطال المساقاة، وحكي عن النخعي القول بکراهتها.

وقد استدل أبو حنيفة على بطلانها بما روي أن الرسول p "نهى عن الغرر" ،والثمرة في عقد المساقاة مترددة بين القلة والكثرة ، وبين ظهور الثمرة وعدمها، وهذا غرر عظيم. كما أن الاستئجار ببعض الخارج من النصف والربع ونحوه، استئجار ببذل مجهول، وأنه لا يجوز^(٢).

مناقشة أدلة أبي حنيفة:

ويمكن مناقشة دعوى أبي حنيفة بالقول: إن عقد المساقاة بعيد عن الغرر؛ لأن الغرر هو ما تردد بين جائزين على سواء، أو أن يترجح الأخوف من الاحتمالين، وهذا لا يكون في عقد المساقاة؛ لأن الغالب حدوث الثمرة في وقتها، طبقاً لما جرى به العرف، كما أنه لو سلمنا جدلاً بوجود غرر في المساقاة، فقد صارت مستثناة

(١) مغني المحتاج ٣٢٢/٢.

(٢) بدائع الصنائع ١٧٥/٦ ، الحاوي الكبير ٩ / ١٦٣.

بالنص الوارد في إباحتها^(١). ونظير ذلك النهي عن بيع المعدوم، ومع ذلك أبيح السلم ، للنص على جاوزة.

وأرى أنه بعد مناقشة ما استدل به أبو حنيفة -ع- يتضح لنا: ترجيح رأي جمهور الفقهاء، والذين قالوا بصحة عقد المساقاة؛ وذلك لقوة أدلتهم، كما أن العقد مما يحتاجه الناس في حياتهم، ومنعه يعد تضييقاً عليهم في معاشهم.

المبحث الثاني

أركان وشروط المساقاة

تتحقق المساقاة بأركان خمسة، وهي: العاقدان، ومورد العمل، والثمار، والعمل، والصيغة، كما يلي :

الركن الأول: العاقدان:

ويقصد بهما رب المال، والعامل، ويشترط أن تكون من جائز التصرف لنفسه، أو ولياً عن غيره، كصبي، ومجنون، وسفيه. مع ملاحظة أنه في حكم ولي ناظر الوقف، وكذا الإمام في بساتين بيت المال، وما لا يعرف مالكة، وكذا بساتين الغائب.

الركن الثاني: مورد العمل:

ومورد العمل في عقد المساقاة هو الشجر^(١)، فعند الحنفية، والمالكية، والحنابلة، يجوز المساقاة في الأصول، والشجر، وكذا القديم عند الشافعية.

^(١) الحاوي الكبير ٩/١٦٣، ١٦٤.

وما اختاره الثوري هو القول بجواز المساقاة في كل ما كان شجرًا مثمرًا.

ووجهه: أنه قد اجتمع في الأشجار معنى النخل من حيث بقاء أصلها ومنع إجارتها؛ ولذا كانت في حكمها في جواز المساقاة عليها.

والقول الجديد عند الشافعية: فيما يتعلق بمورد العمل هو الشجر ، كما أنهم يشترطون فيه ما يأتي:

١- أن يكون مغروسًا، معينًا، مرئيًا. فإذا ساقاه على ودي (صغار النخل) ليغرسه ويكون الشجر بينهما، أو ليغرسه ويتعهد هو الثمرة بينهما، فهو فاسد على الصحيح عند الشافعية. كما يشترط أن تكون الأشجار مرئية على المذهب، وإلا كان العقد باطلاً، وقيل فيه قولاً كبيع الغائب.

كما يشترط أن تكون الأشجار معينة، معلومة، فلو ساقاه على أحد الحائطين، لم يصح؛ لأن النخل أصل في العقد، فبطل بالجهالة. وكذا لو ساقاه على نخل غائب بشرط خيار الرؤية، فإن الأصح عند الشافعية هو فساد العقد.

٢- أن يكون نخلاً أو عنباً . فالنخل والعنب لا يختلف مذهب الشافعية في جواز المساقاة عليهما. أما النخل فهو ما ترد عليه صيغة عقد المساقاة أصالة؛ للخبر السابق. وأما العنب فقد اختلف الأصحاب في أصل دليل جواز المساقاة عليه، هل قال به الشافعي -٣- نصاً، أو قياساً؟

فقد قال بعضهم: إن مستند الشافعي في جواز المساقاة على العنب هو النص؛ لما روي "أن رسول الله -p- ساقى في النخل، والكرم".

(١) تراجع رسالتنا في الماجستير " الأحكام الفقهية لقيام السوق الإسلامية المشتركة " ص

والأرجح ما قاله بعض الأصحاب من أن سند الشافعي في ذلك، هو القياس على النخل من وجهين:

أ - اشتراك النخل والعنب في وجوب الزكاة فيهما^(١).

ب- بروز ثمرهما، وإمكان خرصهما.

الركن الثالث: الثمار:

والثمر هنا هو المقصود من المساقاة، ومن ثم يخرج بالثمر سواقط النخل، كالسعف، والليف، فهو لرب النخل؛ لأنه ليس من مألوف النماء، ولا مقصود النخل. ويشترط في الثمار ما يأتي:

١- أن تختص بالمتعاقدين، فلا يجوز شرط بعضه لغيرهما.

٢- أن تكون الثمار مشتركة بينهما، فلا يجوز شرط كل الثمر لأحدهما، فإن شرط كل الثمر للمالك، فسدت المساقاة.

٣- أن يكون نصيب العامل من الثمرة معلومًا، بجزء شائع فيها من نصف أو ربع أو عشر، قل ذلك الجزء أو أكثر، فإن جهل نصيبه كقوله: لك ما يكفيك، لم يجز للجهل به^(٢).

الركن الرابع: العمل:

ويشترط فيه ما يأتي:

^(١)الحاوي الكبير ١٦٩/٩.

^(٢)روضة الطالبين ٢٢٨/٤.

- ١ - أن لا يشترط عليه عمل ليس من أعمال المساقاة.
- ٢ - أن ينفرد العامل بالعمل، فلو اشترط المالك أن يعمل مع العامل، فسد العقد؛ لأن من شروط المساقاة التخلية بين العامل وبين الحديقة.
- ٣ - أن ينفرد العامل باليد في الحديقة؛ ليتمكن من العمل متى شاء، فلو شرط كونه في يد المالك، أو مشاركته في يده، لم يصح.
- ٤ - معرفة العمل جملة، لا تفصيلاً. ويكون ذلك بتقدير المدة كسنة أو أكثر، إلى مدة تبقى فيها العين غالباً للاستغلال، فلا تصح المساقاة مطلقة ولا مؤبدة، لأنها عقد لازم، فأشبهت الإجارة.

الركن الخامس: الصيغة:

- فلا تصح المساقاة بدون الصيغة على الصحيح، وأشهر الصيغ في هذا الشأن: ساقيتك على هذه النخيل بكذا. وتنعقد المساقاة بكل لفظ يؤدي معناها، وإذا تم العقد بلفظ المساقاة، فالصحيح أن لا يحتاج إلى تفصل الأعمال، بل يحمل في كل ناحية على عرفها الغالب. ويشترط في الصيغة ما يأتي:
- ١ - القبول لفظاً من الناطق، لأن المساقاة عقد لازم، وتصح بإشارة الأخرس المفهمة.
 - ٢ - أن يكون العقد مؤقتاً. فإن تم التوقيت بالشهور أو السنين العربية، صح. وإذا أطلق لفظ السنة أو الشهر، انصرف إلى العربية.

المبحث الثالث

أحكام المساقاة

المسألة الأولى

المساقاة عقد لازم

يرى جمهور الفقهاء - عدا الحنابلة - أن المساقاة عقد لازم من الجانبين، لا يملك أحدهما الامتناع والفسخ من غير رضا صاحبه، قياساً على الإجارة، بجامع أن العمل فيهما في أعيان تبقى بحالها، ومن هنا تخالف المساقاة عقد القراض، حيث لا تبقى أعيانه بعد العمل، فأشبهه بالوكالة.

ووجه لزوم عقد المساقاة: وهو مراعاة مصلحة كل من العاقلين؛ إذ لو تمكن العامل من فسخ العقد قبل تمام العمل، لأدى ذلك إلى تضرر المالك بفوات الثمرة، أو بعضها بعدم العمل، لكون المالك لا يحسنه، أو لا يتفرغ له، ولو تمكن المالك من فسخه؛ لأدى إلى إلحاق الضرر بالعامل بفوات نصيبه من الثمرة؛ لأن الغالب كونه أكثر من أجرة المثل^(١).

اعتراض جواب .

فإن قيل: القول بلزومهما مشكل؛ لأن ورودها على الزمة، يجعلها شبيهة ببيع الدين بالدين، باعتبار أن العمل دين على العامل، والثمرة وإن لم تكن ديناً، إلا أنها معدومة، فأصبحت في معنى الدين، ومن المعلوم أن بيع الدين بالدين مجمع على بطلانه.

(١) نهاية المحتاج ج ٥/٢٥٥.

ويجاب عن ذلك: بأن بيع الدين بالدين، قد جُوز للحاجة كما في الحوالة، وصورة المساواة أولى لشدة الحاجة إليها^(١).

المسألة الثانية

واجبات العامل والمالك

إن عقد المساواة يرتب تبعات وواجبات على كل من العامل والمالك فيما يتعلق بالمساواة، نعرض لها بإيجاز كما يلي :

أولاً : واجبات العامل :

وضابط هذه الواجبات هو : "أن كل عمل تحتاج إليه الثمار لزيادتها، أو صلاح، ويتكرر كل سنة، فهو على العامل"، وإنما شرط الشافعية ضرورة التكرار في العمل الواجب على العامل؛ لأن ما لا يتكرر من الأعمال يبقى أثره بعد انتهاء عقد المساواة، فيمثل استفادة للمالك، وإجحافاً بالعامل. ومن أمثلة ما يجب على العامل ما يأتي:

- ١ - السقي، وذلك إن لم يشرب الشجر بعروقه، ويدخل في السقي جميع توابعه، ولوازمه، مثل: إصلاح طرق الماء، وفتح رأس الساقية، وسدها عند انتهاء السقي.
- ٢ - تنقية الآبار والأنهار، أي مجرى الماء من العوائق، مثل: الطين وما شابه ذلك من إصلاح الأجاجين، وهي الحفر التي حول الشجر والتي يجتمع فيها الماء لشربه.

- ٣ - تلقيح النخل . وهو وضع شيء من طلع الذكور في طلع الإناث، ويكلف العامل بالعمل فقط، أما الطلع وقيمه فهي على المالك؛ لأنه عين مال يكلف به

^(١) أروضة الطالبين، ٢/٤٢٣٦؛ مغني المحتاج، ٢/٣٢٩ وما بعدها؛ المعونة على مذهب عالم المدينة ٢/١١٣٤؛ الكافي في فقه الإمام أحمد، لابن قدامة المقدسي، ٢/١٦٣.

المالك.

٤ - تنقية الحشائش والكلأ المضر بالشجر، وتنحية قضبان مضرّة بالشجر، وقطع ما يضر من الجريد والسعف، وصرفها عن وجوه العناقيد لتراها الشمس، ويتيسر قطفها عند الجذاذ.

٥ - تعريش شجر العنب ووضع ما يستر العناقيد؛ صوتاً لها من الشمس والطيور، وحفظ الثمر من السراق واللصوص.

٦ - جذاذ الثمر: بمعنى قطعه وحفظه، ثم تجفيفه في الأصح؛ لأن التجفيف من مصالح الثمر.

ثانياً : واجبات المالك :

أما واجبات المالك فضابطها هو " أن كل ما لا يتكرر كل عام، وقصد به حفظ الأصل، أي الشجر، فهو على المالك"، ومن أمثلة ذلك:

١ - حفر الآبار والأنهار الجديدة، أو التي انهارت، وبناء الحيطان، ووضع الأبواب عليها، ووضع الشوك على رأس الجدار، وفق ما يقضي به العرف.

٢- الآلات التي يتوافر بها العمل، كالفأس ونحو ذلك، فالصحيح أنها على المالك، وقيل: هي على من شرطت عليه.

٣- خراج الأرض الخراجية على المالك قطعاً.

٤- كل عين تتلف في العمل، فعلى المالك قطعاً^(١).

(١) روضة الطالبين، ٤/٢٣٥؛ مغني المحتاج، ٢/٣٣٠.

المسألة الثالثة

زراعة البياض دون إذن

يرى الشافعي - رحمه الله تعالى - أنه ليس للمساقي في النخل أن يزرع البياض (وهي الأرض الفضاء بين الشجر) دون إذن صاحب الأرض والشجر. فإن خالف العامل وزرع البياض بغير إذن صاحبه، فهو كمن زرع أرض غيره غصباً، فيكون لصاحب الأرض أن يقع الزرع، ولا يجبر على تركه؛ لقوله p: "ليس لعرق ظالم حق". كما أنه ليس للمالك أن يجبر الزارع على أخذ قيمة زرعه، سواء كان قلع الزرع مضراً بأرضه، أم لا؛ لقوله p: "لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه"^(١).

المسألة الرابعة

هروب العامل

لما كان عقد المساقاة من العقود اللازمة، فإنه يترتب على هذا أنه إذا هرب العامل قبل تمام العمل المطلوب للنخل والثمرة، وجب على الحاكم البحث عنه، عند استعداد رب المال، فإن لم يجده، فإننا نفرق بين عدة حالات كما يلي :

الحالة الأولى : غياب العامل مع وجود ماله . وفي هذه الحالة يستأجر الحاكم من مال العامل من يقوم مقامه في الباقي من عمله.

الحالة الثانية : ألا يجد الحاكم للعامل مالاً، وفي هذه الحالة :

أ - يستدين الحاكم على العامل قرضاً من رب المال، أو غيره، أو من بيت المال، ثم يقضيه من حصته من الثمرة عند حصولها.

^(١) الحاوي الكبير، ١٧٥/٩.

ب - فإن تعذر على الحاكم الاستدانة، وكانت الثمرة بادية الصلاح، باع الحاكم منها بقدر أجور الأجراء. وأما إن كانت غير بادية الصلاح، وتعذرت الاستدانة، ففي ذلك وجهان:

أحدهما: يروى عن أبي علي بن أبي هريرة: أن الحاكم يدخل رجلاً آخر بسهم مشاع في الثمرة، يحصله من حصة العامل، ويحفظ له الباقي.
الثاني: وهو اختيار الماوردي الذي يرى أن تعذر استيفاء ما بقي من العمل، يعد عيباً يوجب الخيار، ويعطي للمالك الحق في الفسخ، ثم بعد ذلك يقدر للعامل ما يقابل عمله السابق في الثمرة.

المسألة الخامسة

التقصير في الحفظ والأمانة

يجب على العامل تجاه الثمرة حقين: وهما حفظها، وأداء الأمانة فيها. فإن ظهر منه تقصير في الحفظ، استأجر رب المال من يحفظها، ويكون ذلك من مال العامل. كذلك الأمر إن ظهر منه خيانة، أو سرقة، وقامت على هذا الأدلة بالإقرار أو البينة، أو يمين المدعي عند نكوله، ففي هذه الحالة، يمنع من الثمرة، وترفع يده عنها، ويحق للمالك أن يستأجر غيره؛ ليعمل في الثمرة، ويكون ذلك على نفقة العامل.

المسألة السادسة

انتهاء المساقاة

ينتهي عقد المساقاة عند الشافعية بأمور، أهمها ما يأتي:

١ - انقضاء المدة .

فعند الشافعية تنقضي المساقاة بانتهاء المدة المتفق عليها. ولذا قالوا: إنه إذا ساقاه عشر سنوات، ثم كان طلع ثمر السنة العاشرة بعد انقضاء المدة، لم يكن للعامل في ثمرة تلك السنة حق؛ لانقضاء مدته، وزوال عقده. أما لو طلع الثمر قبل انقضاء السنة الأخيرة، ثم انقضت السنة قبل بدو الصلاح، كان للعامل الحق فيها؛ لأنها حدثت في مدته^(١).

٢ - موت العامل .

يفرق الشافعية بين ما إذا كانت المساقاة على عين العامل، أو على ذمته. فإن كانت المساقاة على عين العامل، فإن المساقاة تنفسخ بموته كالأجير المعين. أما إذا كانت المساقاة على الذمة، ومات المساقى قبل تمام العمل، فوجهان: أحدهما: أن المساقاة تنفسخ؛ لأن المالك لا يرضى بيد غير العامل.

والثاني: وهو الصحيح، لا تنفسخ الإجارة، بل ينظر في الأمر، فإن خلف تركة، فإن على وارثه إتمام العمل، فإن لم يخلف تركة، لم يقتض عليه، بخلاف الحي الهارب.

أما إذا مات المالك للشجر، فإن المساقاة لا تنفسخ، بل يستمر العامل، ويأخذ نصيبه^(٢).

^(١) الحاوي الكبير، ١٧١/٩.

^(٢) روضة الطالبين، ٢٣٨/٤؛ مغني المحتاج، ٣٢١/٢.

الفصل الثالث

كتاب المزارعة (١)

المبحث الأول

حقيقة ومشروعية المزارعة

حقيقة المزارعة .

المزارعة لغة: مأخوذة من قولهم زرع الحب بزعه زرعاً وزراعة بمعنى: بذرة، والاسم: الزرع، وجمعه زروع. وقيل الزرع نبات كل شيء يحترث، وقيل الزرع: طرح البذور، والزرع هو الانبات، فيقال زرع الله أي أنبته^(٢)، وفي التنزيل: (أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ * أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ)^(٣).

وشرعا: عرفها الشافعية بأنها: المعاملة على الأرض ببعض ما يخرج منها والبذر من المالك^(٤).

ويرى الماوردي أن المخابرة هي المزارعة، وهي استكراء الأرض ببعض ما يخرج منها وأن الخلاف في تسميتها بالمخابرة يرجع إلى قولين ذكرهما ابن قتيبة:

الأول: أنها مأخوذة من معاملة خبير حين أقرهم رسول الله ﷺ فقال: "خابروهم"، أي عاملوهم على خبير.

(١) كتبه: أ. د. محمد عامر .

(٢) لسان العرب: ج ٣ ص ١٨٢٦.

(٣) سورة الواقعة: آية رقم ٦٣، ٦٤ .

(٤) روضة الطالبين ج ٤ ص ٢٤٢ .

الثاني : أنها مأخوذة من الخبرة ، وهي النصيب ، قال عروة بن الورد:

إذا ما جعلت الشاة للقوم خبرة فشأنك أني ذاهب لشئون

والخبرة أن يشتري الشاة جماعة فيقتسمونها^(١).

ويرى الإمام النووي أن المزارعة والمخابرة عقدان مختلفان فالمخابرة هي المعاملة على الأرض ببعض ما يخرج منها والبذر من العامل ، أما المزارعة فهي: المعاملة على الأرض ببعض ما يخرج منها والبذر من المالك^(٢).

حكم المزارعة ودليل مشروعيتها

اتفق الفقهاء على فساد ضرب من ضروب المزارعة ، وهو أن تكون حصة كل واحد منهما من زرع الأرض مفردة عما يخص صاحبه ، وصورة هذا أن يقول: قد زارعتك على هذه الأرض على أن ما نبت على الماذيانات كان لي ، وما نبت على السواقي والجداول كان لك ، أو أن ما سقي بالسماء فهو لي ، وما سقي بالرشاء فهو لك ، فهذه مزارعة باطلة بدليل رواية سعيد بن المسيب عن سعد قال: "كنا نكرى الأرض بما على السواقي وما سقي بالماء منها ، فنهانا رسول الله ﷺ عن ذلك وأمرنا أن نكرىها بذهب أو ورق"^(٣).

بيد أن الفقهاء اختلفوا في صورة أن يزارعه على الأرض ليكون العمل على الأجير والأرض لمالكها والبذر منهما أو من أحدهما ، وعلى أن ما يخرج من زرع كان

(١) الحاوي ج ٩ ص ٢٨٦.

(٢) روضة الطالبين ج ٤ ص ٢٤٢.

(٣) أبو داود ، كتاب البيوع رقم ٣٣٩١.

بينهما على سهم معلوم من نصف أو ثلث أو ربع ، ليأخذ الزارع سهمه بعمله ،
ويأخذ رب الأرض سهمه بأرضه.

ويرجع سبب الخلاف الى تعارض الروايات الواردة في هذا الشأن كما سنرى، وإلى
الاختلاف في فهم الروايات. ويمكن حصر أراء الفقهاء في رأيين:

الرأي الأول : بطلان المزارعة .

فمذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه أنها باطلة سواء شرط البذر على الزارع
أو على المالك ،وهذا الرأي قال به من الصحابة عبدالله بن عمر وجابر بن
عبدالله، ورافع بن خديج ومن التابعين سعيد بن جبير وعكرمة ^(١).

ويلاحظ أن الشافعية القائلين بمنع المزارعة أجازوها في صور على سبيل
الاستثناء ، ، ومن أمثلة هذه الصور التي يتوصل بها الى صحة الزراعة عند
المانعين ما يلي :

الصورة الأولى : أن تكون المزارعة تابعة للمساقاة ، فمع منع الشافعية للمزارعة
إلا أنهم أجازوها تبعا للمساقاة ، وذلك بأن يدفع المالك الأرض المغروسة نخلا أو
كرم عنب للعامل على أن يقوم العامل بسقيها والمحافظة عليها في نظير جزء من
ثمنها وهذا هو عقد المساقاة. فإن كان فراغ بين الأشجار يصلح زراعته حبوباً فإنه
يصح المزارعة فيه بالشروط التالية ^(٢):

١ - أن يكون عقد المساقاة والمزارعة واحداً.

٢ - ألا يفصل بين المزارعة والمساقاة فاصل.

(١) الحاوي: ج ٩، ص ٢٨٦.

(٢) شرح منهاج الطالبين: ج ٣، ص ٦١، ٦٢؛ وحاشية الشرقاوي: ج ٢، ص ٨٢؛ مختصر

المزني: ج ٣، ص ٩٢.

٣ - أن تتقدم المساقاة في العقد لأنها الأصل.

٤ - أن يكون عامل المساقاة هو بعينه عامل المزارعة.

الصورة الثانية: أن يشتركا في منفعة الأرض (بملك رقبتهما - أو إيجارتهما - أو استعارتهما - أو تكون لأحدهما فيؤجر صاحبه أو غيره نصفها مشاعاً) ، ففي هذه الصور تصبح منفعة الأرض لهما معاً ، ثم يشتركان بعد ذلك في البذر والعمل فيصير الزرع بينهما.

الصورة الثالثة: أن يقول المالك للعامل: قد أجرتك نصف أرضي مشاعاً سنة بدينار ، واستأجرت نصف عملك ونصف عمل ما شاهدته من بقرك وآلتك سنة بدينار ، ثم يقع بينهما القصاص والإبراء ، ويخرجان البذر بينهما فيصيران شريكين في الزرع .

الصورة الرابعة : أن يؤجر المالك للعامل نصف أرضه مشاعاً مقابل نصف عمل العامل ونصف عمل ما شاهدته المالك من آلة وبقرة ، فيصبح كل واحد مستأجراً لنصف ما لصاحبه سنة بنصف ما للأخر سنة ، ثم يخرجان البذر بينهما فيصيران شريكين في الأرض والبذر والعمل ، ومن ثم يصبح الزرع بينهما^(١).

أدلة المانع للمزارعة^(٢):

لقد استدلل المانعون بعدد من الروايات عن الرسول p ورد فيها النهي عن المزارعة . وقد جاءت تلك الروايات بواسطة ستة نفر رضوان الله عليهم أجمعين

(١) شرح منهاج الطالبين ج ٣ ص ٦١، ٦٢ ، حاشية الشرقاوي ج ٢ ص ٨٢ ، مختصر

المزني ج ٣ ص ٢٩.

(٢) لمزيد تفصيل : تراجع رسالتنا للماجستير: الأحكام الفقهية لقيام السوق الإسلامية المشتركة .

وهم : (رافع بن خديج - جابر بن عبد الله - أبو هريرة - أبو سعيد الخدري - ثابت بن الضحاك - زيد بن ثابت) ، وأهم هذه الروايات ما يلي :

١ - قال رافع بن خديج (كنا نحافل الأرض على عهد رسول الله ﷺ ، فنكريها بالثلث والربع والطعام المسمى ، فجاءنا ذات يوم رجل من عمومتي ، فقال " نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا فيه نفع ، وطواعية الله ورسوله أنفع لنا ، نهانا أن نحافل بالأرض فنكريها بالثلث والربع والطعام المسمى ، وأمر رب الأرض أن يزرعها أو يزرعها أخاه ، وكره كراءها وما سوى ذلك " (١) .

٢ - عن ابن النعيم قال حدثنا رافع بن خديج أنه زرع أرضاً فمر به الرسول ﷺ وهو يسقيها فسأله " لمن الزرع ولمن الأرض ؟ " ، فقال : زرعي ببذري وعملي ولي الشطر ولبني فلان الشطر . فقال عليه السلام " أربيتما ، فرد الأرض على أهلها ، وخذ نفقتك " (٢) .

٣ - عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال " نهى رسول الله ﷺ عن المخابرة " ، وروي عنه أيضاً " نهى رسول الله ﷺ عن بيع الأرض البيضاء سنتين أو ثلاثاً " ، وفي رواية " عن بيع السنين " (٣) .

الرأي الثاني : جواز المزارعة .

ذهب بعض الشافعية إلى جواز المزارعة ، منهم ابن سريج ، والماوردي ، والنووي ، وابن خزيمة ، وابن المنذر ، والخطابي . وقد صنف ابن خزيمة في ذلك كلاماً بيّن فيه علل الأحاديث الواردة بالنهي وجمع بين أحاديث الباب . وقال

(١) مسلم ، باب كراء الأرض بالطعام ج ١٠ ، ٢٠٤ .

(٢) أبو داود ، باب المزارعة ج ٣ ص ٢٥٩ ، رقم ٣٤٠٢ .

(٣) مسلم ، باب كراء الأرض بالطعام ج ١٠ ، ٢٠٠ .

الخطابي "فالمزارعة جائزة وهي عمل المسلمين في جميع الأمصار ، لا يبطل العمل بها أحد" (١).

أدلة القائلين بالجواز:

١ - ما روي عن بن عمر أن رسول الله ﷺ عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج من ثمر أو زرع . وهذه الحادثة من أهم حوادث النبوة والخلافة الراشدة ولا مجال للشك في صحتها ، وهي تدل دلالة واضحة على أن الرسول ﷺ قد بايع اليهود على أرض خيبر ... وعلى ذلك ظل الأمر جارياً إلى أخريات أيامه وفي عهد الصديق وأول عهد الفاروق عمر رضي الله عنهما ، فهل يبقى بعد ذلك أي مجال للظن في النهي عنها (٢)؟

٢ - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال :قالت الأنصار للنبي ﷺ " أقسم بيننا وبين إخواننا النخيل قال: لا ، فقالوا : تكفوا لنا المؤنة ونشركم في الثمرة ، قالوا: سمعنا وأطعنا" (٣) .

٣ - عن قيس بن أسلم أن أبا جعفر قال: ما بالمدينة أهل بيت هجرة إلا يزرعون على الثلث والربع، وزارع بن مسعود وعمر بن عبدالعزيز والقاسم وعروة وآل أبي بكر وآل عمر قال: وعامل عمر الناس على إن جاء عمر بالبذور من عنده فله الشطر، وإن جاءوا بالبذر فلهم كذا (٤).

٤ - عن حنظلة بن قيس الأنصاري قال: سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض بالذهب والفضة ، فقال لا بأس بها ، إنما كان الناس يؤجرون على عهد

(١) الحاوي ج ٩ ص ٢٩٠ ، وروضة الطالبين ج ٤ ص ٢٤٤.

(٢) مسلم: باب كراء الأرض بالطعام، ج ١٠، ص ٢٠٨.

(٣) البخاري: باب المزارعة، ج ٢، ص ٤٦.

(٤) البخاري: باب المزارعة، ج ٢، ص ٤٨، ٤٩.

رسول الله على الماذيانات وأقبال الجداول وأشياء من الزرع ، فيهلك هذا ويسلم هذا ويهلك هذا فلم يكن للناس كراء إلا هذا ^(١).

الرد على المانعين :

١ - يرى الشوكاني : أنه لا سبيل إلى جعل أحاديث النهي ناسخة لما فعله الرسول ﷺ في خيبر وهو مستمر على ذلك وتقريره لجماعة من الصحابة عليه ، ولا سبيل إلى جعل هذه الأحاديث المشتبهة على النهي منسوخة بفعله عليه السلام وتقريره ، وذلك بسبب ورود النهي عنه في أثناء مدة معاملته مع أهل خيبر ، ورجوع جماعة من الصحابة إلى رواية من روى النهي، والجمع ما أمكن هو الواجب ، وقد أمكن الجمع هنا بحمل النهي على معناه المجازي وهو الكراهة ^(٢)

٢ - أن أحاديث النهي يجاب عنها من وجوه :

أ - أن رافع فسر النهي في حديثه بما لا يختلف في فسادته حيث قال : كنا أكثر الأنصار حقلاً ، فكنا نكري الأرض على أن لنا هذه ولهم هذه ، فربما أخرجت هذه الأرض ولم تخرج هذه فنهاننا عن ذلك ، فأما الورق فلم ينهنا ^(٣).

ب - عندما سئل عروة بن الزبير زيد بن ثابت عن حقيقة الأمر قال : يغفر الله لرافع بن خديج ، أنا والله أعلم بالحديث منه ، إنما أتى رجلان إلى النبي ﷺ وقد اقتتلا فقال ﷺ " إن كان هذا شأنكم فلا تكروا المزارع " ، فسمع رافع بن خديج قوله " فلا تكروا المزارع " ^(٤) .

ج - لو قدر صحة خبر رافع وامتنع تأويله وتعذر الجمع لوجب حمله على أنه منسوخ ؛ لأنه لا بد من نسخ أحد الخبرين ويستحيل القول بنسخ حديث خيبر لكونه

(١) مسلم ، باب كراء الأرض بالطعام ج ١٠ ص ٢٠٦.

(٢) نيل الأوطار ج ٥ ص ٢٧٧.

(٣) نيل الأوطار ج ٥، ص ٢٧٥ .

(٤) أبو داود ، باب المزارعة ج ٣ ص ٢٥٥ .

معمولاً به من جهة النبي P إلى حين موته ثم من بعده إلى عصر التابعين ، فمتى كان نسخه ؟ (١).

د - أن هذه الأحاديث تحمل على ما فيه مفسدة أو يؤدي إلى الغرر والجهالة كأن يعين صاحب الأرض لنفسه مكاناً أو ناحية معينة يختص بها كما ورد في أحاديث رافع . ولذا عنون الشوكاني بقوله (باب فساد العقد إذا شرط أحدهما لنفسه التبن أو بقعة بعينها) (٢).

الترجيح:

والذي نراه راجحاً هو الرأي القائل بجواز المزارعة ، لعمل النبي P والصحابة بذلك ، كما أن العقل لا يتفق مع القائلين بمنع المزارعة؛ لأنها هامة لأبد وأن يكون للرسول فيها هدي ظاهر معروف ، ولا يعقل أن ينهي الرسول عن المزارعة دون أن يسمع بذلك أحد من الصحابة عدا هؤلاء الأصحاب الستة منذ عهد النبي P إلى وسط عهد معاوية - أي خمسين سنة تقريباً - .

ومتى تقرر صحة المزارعة فإنها تتفق في غالب أحكامها مع المساقاة ، غير أن المزارعة عقد جائز غير لازم ، ومن ثم يجوز لأحدهما فسخ العقد دون توقف ذلك على رضا أو قبول الطرف الآخر . والآن لنعرض أهم أحكامها عند القائلين بها من الشافعية وغيرهم كالأحناف إتماماً للفائدة .

المبحث الثالث

أركان وشروط المزارعة

(١) المغني، ج٥، ص ٢١٧.

(٢) نيل الأوطار: ج٥، ص ٢٧٦.

أركان المزارعة .

ثمة أركان للمزارعة هي : الأرض ، البذر ، العمل ، الآلة. بيد أن الركن الأهم في عقد المزارعة هو الإيجاب والقبول ،فعليه إذا قال صاحب الأرض للعامل المزارع : أعطيتك هذه الأرض مزارعة على أن تأخذ من الحاصلات كذا حصة ، وقال الزارع: رضيت أو قال قولاً يدل على الرضاء: أو قال لصاحب الأرض: أعطني أرضك على وجه المزارعة لأعمل فيها، ورضي الآخر ، تنعقد المزارعة ، وهذا ما نصت عليه المادة (١٤٣٢) من مجلة الأحكام العدلية .

شروط صحة المزارعة .

١ - أهلية العاقلين .

ويقصد بها أن يكون العاقدان في عقد المزارعة عاقلين ، فلو كان أحد العاقلين أو كلاهما مجنوناً أو صبيّاً غير مميز ،فيبطل عقد المزارعة. ويلاحظ أنه لا يشترط في عقد المزارعة أن يكون العاقدان بالغين ، ومن ثم فإن الصبي المأذون له يمكنه أن يعقد المزارعة. وهذا الشرط يمثل شرط الانعقاد في المزارعة ، بمعنى أن تخلفه يترتب عليه البطلان.

٢ - أن يكون المزروع معلوماً .

ومقتضى هذا الشرط ضرورة تعيين الزرع ،والعلة في ذلك أن الأجرة في المزارعة هي بعض الزرع الخارج، ولما كان بيان الأجرة من شروط صحة العقد ، فإن ذلك يقتضي تعيين الزرع وبيانته حتى يتحقق بيان الأجرة. كما أن بعض الزرع يضر الأرض ضرراً بالغاً ، فيحتاج صاحب الأرض لمعرفة ما يزرع في أرضه .

٣ - أن تكون حصة الزارع من الحاصلات جزءاً شائعاً .

فيشترط أن تكون حصة الزارع من الحاصلات جزءاً شائعاً كالنصف والثلث ،وهذا الشرط يشير إلى ما يلي :

- أ - أن يكون نصيب الزارع من الحاصلات الخارجة من الأرض دون غيره ، فلا يجوز أن يعطى من حاصلات أرض أخرى غير التي يزرعها .
- ب - ألا تشترط الحاصلات لأحدهما فقط ، ولعل هذه الإشارة مستفادة من قولهم في الشرط (جزءاً).

ج - أن تكون حصة الزارع شائعة ، فلا يجوز القطع له بمقدار محدد كعشر أردب ، أو بالزرع الخارج من محل معين من الأرض ، أو أن يكون التبن لأحدهما والحب للآخر ، فإن حدث ذلك فقد فسدت المزارعة ، بدليل ما رواه سعيد تبن المسيب عن سعد قال: " كنا نكري الأرض بما على السواقي وما سقى بالماء منها، فنهانا رسول الله ﷺ عن ذلك وأمرنا أن نكريها بذهب أو ورق "(١). ولما روي عن حنظلة بن قيس الأنصاري: سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض بالذهب والفضة ، فقال : لا بأس بها ، إنما كان الناس يؤجرون على عهد رسول الله ﷺ على الماذينات وأقبال الجداول وأشياء من الزرع فيهلك هذا ويسلم هذا ويهلك هذا فلم يكن للناس كراء إلا هذا (٢).

٤ - أن تكون الأرض صالحة للزراعة .

وذلك لأن الغاية من المزارعة تحقق الربح الناتج من الأرض ، وهذا يتطلب صلاحية الأرض للزراعة ، فإذا كانت الأرض سبخة أو مستنقعا لا تنبت زرعاً ، فلا تصح المزارعة. ويلاحظ أن تحري شرط صلاحية الأرض للزراعة إنما يطلب في مدة الزراعة فقط، فلو كانت الأرض غير ممكنة الزراعة الآن لعارض قريب

(١) أبو داود ، كتاب البيوع رقم ٣٣٩١ .

(٢) مسلم ج ١٠ ص ٢٠٦ .

الزوال كانقطاع المياه، بيد أنه يمكن زراعتها في مدة الزراعة المعقود عليها العقد بعودة المياه، فإن المزارعة تصح .

٥ - أن يكون الزرع قابلاً لعمل الزراعة .

ومعنى هذا الشرط أن يؤثر العمل في المزروع بالزيادة وفقاً لمجرى العادة، ومن ثم فإذا دفع أرضاً فيها زرع قد طلب الحصاد، فإن العقد لا يجوز، لأن الزرع الناضج الذي طلب الحصاد لا يؤثر فيه عمل الزارع بالزيادة، فلا يكون قابلاً لعمل الزراعة .

٦ - تسليم الأرض إلى العامل .

وهذا التسليم يقتضي أن يوجد من صاحب الأرض التخلية بين الأرض وبين العامل، وهذا الشرط يشبه ما جاء في المضاربة من ضرورة التخلية بين المضارب وبين المال، حتى أنه لو شرط رب المال على المضارب أن يعمل معه لا تصح المضاربة، لأن شرط التخلية من شروط الصحة.

المبحث الثالث

أحكام المزارعة

المسألة الأولى

أثر المزارعة

يترتب على عقد المزارعة عدة آثار أهمها :

١ - تبادل ملك المنفعة .

وهذا الحكم يعد حكماً حلالاً يترتب بمجرد العقد ، بمقتضاه يملك المزارع منفعة الأرض ، ويملك صاحب الأرض منفعة العامل .

٢ - الشركة في الخارج على الوجه الشروط .

وهذا الحكم يظهر في المآل ، ومعناه أن يتقاسم المزارع وصاحب الأرض الحاصلات الناتجة من الأرض بالقدر المتفق عليه بينهما ، وعلى ذلك فإن الأرض لو أجديت ولم تخرج زرعاً ، أو أنها أخرجت زرعاً ثم تلف قبل الإدراك بآفة من الآفات ، فلا يجوز لأحدهما أن يرجع على الآخر بشيء ، فلا يرجع العامل طالباً لأخذ أجره عمله ، كما لا يرجع صاحب الأرض طالباً أخذ أجره أرضه ، لأنهما شركاء في الخارج فقط ، والفرض أنه لم يخرج شيء ، أو أنه خرج وتلف .

المسألة الثانية

حكم المزارعة الفاسدة

إذا فسدت المزارعة لسبب من الأسباب ، فإن الحاصلات الناتجة من المزارعة الفاسدة تكون لصاحب البذر بصرف النظر عن كون صاحب البذر هو الزارع أو صاحب الأرض ، لأن الحاصلات الناتجة من الأرض هي نماء يملكه صاحب البذر ، وفي هذه الحالة فإن صاحب الأرض يعوص ، فإذا كان الطرف الآخر صاحب الأرض فيأخذ أخرة أرضه ، وإذا كان الطرف الآخر هو الزارع فيأخذ مثل أجره عمله ، لأنه بذل عمله وآلته في مقابلة عوض فوته عليه فساد العقد ، فيرجع بقيمته .

ونظير ما سبق ، يرى الشافعي رضي الله عنه أنه لو اشترك أربعة في زراعة الأرض بحيث كانت الأرض لأحدهم ، والبذر للآخر ، والآلة للآخر ، ومن الرابع

العمل ، وانتفقوا على أن يكون الزرع بينهم أرباعاً ، فإن الزرع يكون لصاحب البذر وعليه أجره المثل لشركائه ، لما روي عن مجاهد قال: اشترك أربعة رهط على عهد رسول الله ﷺ في زرع فقال أحدهم : قبلي الأرض ، وقال الآخر: قبلي البذر ، وقال الآخر قبلي العمل ، وقال الآخر قبلي الفدان ، فلما استحصد الزرع صاروا إلى رسول الله ﷺ ، فجعل الزرع لصاحب البذر ، وألقى صاحب الأرض ، وجعل لصاحب الفدان شيئاً معلوماً ، وجعل لصاحب العمل رهماً كل يوم^(١).

المسألة الثالثة

تضمين المزارع

إن من قالوا بجواز المزارعة ذهبوا إلى أن المزارع يجب عليه الضمان في كل موضع ترك ليد الحفظ مع القدرة عليه، ومن أمثلة ذلك ما لو ترك سقي الأرض مع القدرة عليه حتى يبس الزرع، فإنه في هذه الحالة يضمن قيمته ثابتاً في الوقت الذي تأثر الزرع فيه بعدم السقي، وكذلك يضمن الزارع لو أخر السقي تأخيراً غير معتاد لدى الناس ، أو أنه ترك حفظ الزرع حتى أصابته آفة من أكل الدواب ونحوه ، أو أنه لم يطرد الطيور والجراد مع القدرة على ذلك^(٢).

المسألة الرابعة

انقضاء المزارعة

تنقضي المزارعة بأسباب متعددة منها :

١ - موت أحد العاقدين .

(١) الحاوي ج ٩ ص ٢٨٩، ٢٩٠ .

(٢) الفتاوى الهندية ج ٥ ص ٢٦٧ .

وذلك لأن المزارعة تتضمن معنى الإجارة ، والإجارة تبطل بالموت . ويمكن أن نفرق بين ما إذا كانت الوفاة قبل الزرع أو بعده ، فإذا توفى صاحب الأرض أو العامل قبل الزرع ، تبطل المزارعة . أما إذا كانت الوفاة بعد الزرع وتوفى صاحب الأرض أثناء ما يكون نابئاً وأخضر ، فيبقى عقد المزارعة مستمراً حتى إدراك الزرع ويستمر الزارع في عمله ، ثم يقسم الحاصلات بينه وبين ورثة صاحب الأرض ، وكذا الشأن إن مات الزارع يقوم ورثته مقامه.

٢ - الفسخ .

فإذا فسخ صاحب البذر المزارعة فتنفسخ ولو كان بلا عذر . كما تنفسخ من قبل صاحب الأرض للعذر ، كما لو ظهر عليه دين أحوجه إلى بيع الأرض المذكورة . كما تنفسخ المزارعة إذا مرض المزارع أو أراد السفر ، أو كان المزارع خائئاً وخيف من سرقة الحاصلات فللطرف الآخر فسخها . كما تنفسخ المزارعة بانقضاء المدة.

الفصل الرابع

كراء الأرض للزرع والغرس^(١)

المبحث الأول

حقيقة ومشروعية كراء الأرض

حقيقة كراء الأرض . ومعنى كراء الأرض: إيجارها،

مشروعية كراء الأرض .

وقد ذهب الشافعية^(٢) إلى جواز إجارة الأرض بكل ما هو معلوم من ذهب أو ورق أو ما يقوم مقامهما من فلوس ونحوه، كما تجوز الإجارة بالعرض، أو بما ينبت من الأرض من بر أو شعير أو غيره....ويتفق هذا مع ما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة وجماعة من الفقهاء.

أوجه الاختلاف بين كراء الأرض والمزارعة:

تتعدد أوجه الاختلاف بين المزارعة وبين كراء الأرض عند الشافعية،

وأهمها^(٣).

^(١)كتبه: أ. د/ محمد عامر.

(٢) الأم ج ٣ ص ٢٤٠، ٢٤١، الإقناع مع حاشية البيجري ج ٣ ص ٢٨٨.

(٣) الأم ج ٣ ص ٢٤٠.

١- إن مشروعية كراء الأرض محل اتفاق عند الشافعية، أما المزارعة فحمل اختلاف، فقد منعها الإمام الشافعي وبعض الشافعية، بينما أجازها الإمام النووي ومن معه كما سبق بيانه.

٢- أن الأجرة في كراء الأرض تكون بقدر معلوم من الذهب والفضة ونحوهما، وقد تكون بعرض أو بما ينبت من الأرض، مع ملاحظة أن جواز كون الأجرة مما ينبت من الأرض، لا يعنى ضرورة أن يكون نابثاً من الأرض المؤجرة ذاتها، وإنما يكون منها أو من غيرها؛ لأن الطعام أو النبات الموصوف يصير ديناً في ذمة المستأجر، فلا بأس من أين أعطاه. وهذا بخلاف المزارعة، والتي هي كراء الأرض بجزء شائع مما يخرج منها ذاتها كالثالث والرابع، ومن ثم فهو غير معلوم.

٣- يمكن قبض الأجرة في كراء الأرض قبل أن يتفرقا، وقد يجعل له أجلاً معلوماً إن لم يتقابضا، وهذا بخلاف المزارعة، فإن صاحب الأرض لا يستطيع الحصول على حصته في المزارعة إلا بعد إدراك الزرع وحصاده.

أدلة المشروعية

استدل الشافعية على مشروعية كراء الأرض وإجارتها بالذهب والفضة والعرض وبما ينبت من الأرض بما يلي^(١).

١- ما رواه الأوزاعي عن حنظلة بن قيس الأنصاري قال سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض بالذهب والورق؟ فقال لا بأس به إنما كان الناس يؤجرون على عهد النبي على الماذينات وأقبال الجداول وأشياء من الزرع

(١) صحيح مسلم كتاب البيوع ، باب كراء الأرض بالذهب والورق رقم: ١٥٤٧.

فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا فلم يكن الناس كراء إلا هذا
فلذلك زجر عنه فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به ^(١). فكان هذا
القول على عمومته دون تفرقة بين الذهب وغيره وبين ما ينبت من
الأرض.

٢- إن ما صح أن تؤجر به الدور والعقار، صح أن تؤجر به الأرضون، ولما
كان يصح تأجير الدور والعقار بالذهب والفضة والورق والعرض وبما
ينبت من الأرض، صح أن تؤجر الأرض بذلك أيضًا.

دفع الشافعية دعوى المخالفين:

١- دفع دعوى الحسن البصري وطاووس:

ذهب الحسن البصري وطاووس إلى أن إجارة الأرض باطلة لا تجوز بحال، وذلك
استدلالاً بما رواه سالم بن عبدالله: أن عبدالله بن عمر كان يكري أرضه حتى بلغه
أن رافع بن خديج الأنصاري كان ينهى عن كراء الأرض فلقيه عبدالله فقال يا ابن
خديج ماذا تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في كراء الأرض؟ قال
رافع بن خديج لعبدالله سمعت عمي - وكان قد شهد بدرا - يحدث أن أهل الدار أن
رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الأرض قال عبدالله لقد كنت أعلم
في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأرض تكرى ثم خشى عبدالله أن
يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدث في ذلك شيئاً لم يكن علمه فترك
كراء الأرض ^(٢).

(١) البخاري كتاب الحرث والمزارعة رقم: ٣٢٤٥، صحيح مسلم كتاب البيوع، باب كراء الأرض

رقم: ١٥٤٧.

(٢) الحاوي الكبير ج ٩ ص ٢٩٣.

وقد أجاب الشافعية عن ذلك بالحديث الذي استدلوا به على مشروعية كراء الأرض، وقالوا: إن الروايات عن رافع بن خديج مختلفة، ومن ثم فإن النهي الوارد في أحاديث النهي، والتي استدلت به الحسن البصري ومن وافقه، إنما يحمل على الكراء والإجارة بما على الماذيانات وإقبال الجداول وغير ذلك من صور النهي، والتي يتم فيها تعيين مقابل معين مما تنتجه الأرض محل الكراء.

كما أنه يمكن حمل أحاديث النهي على كراهية التنزيه، والإرشاد إلى أفضلية إعارتها^(١).

٢- دفع دعوى المالكية:

ذهب الإمام مالك إلى أن إجارة الأرض وكرائها جائز بالذهب والورق فقط، ولا يجوز بما ينبت من الأرض، وقد استدلت على ذلك بحديث سليمان بن يسار عن رافع بن خديج عن بعض عمومته: أن النبي صلى الله عليه وسلم - قال: من كانت له أرض فليزرعها أخاه، ولا يكارها بثلاث ولا ربع ولا بطعام مسمى^(٢).

وقد أجاب الشافعية^(٣) عن ذلك بعموم الأحاديث الواردة في مشروعية كراء الأرض، كما قالوا إن النهي الوارد في حديث رافع عن الكراء والإجارة بطعام مسمى، إنما يقصد به الطعام المسمى والمعين من الأرض المؤجرة ذاتها، أما الطعام المسمى من غيرها فيجوز، بدليل العموم الوارد في الأحاديث الدالة على المشروعية، حيث يقول رافع: "فأما شيء مضمون فلا بأس به".

شروط صحة إجارة الأرض

(١) شرح النووي على مسلم ج ١٠ ص ١٩٨، وبعدها، فتح الباري ج ٥ ص ٢٩٤.

(٢) مسلم في البيوع باب الكراء، أبو داود في البيع رقم: ٣٣٩٥.

(٣) الحاوي الكبير ج ٩ ص ٢٩٣.

الشرط الأول: أن تكون مدة الإجارة معلومة:

فيشترط في مدة الإجارة أن تكون معلومة، ومن ثم تجوز على سنة؛ لأن الغرر يسير في السنة، والضرورة داعية إلى ذلك، وأما إذا زادت الإجارة على السنة، فلإمام الشافعي قولان ^(١).

القول الأول: عدم جواز الإجارة أكثر من سنة، ووجهة هذا القول: أن الإجارة تتضمن قدرًا من الغرر؛ لأنها عقد على منافع قد تسلم وقد لا تسلم، فإذا قل الزمان قل الغرر، فجازت الإجارة وإذا زاد الزمن كثر الغرر، فتبطل الإجارة، كما أن السنة هي المدة التي تتكامل فيها منافع الزراعة في الأرض، فتجوز الإجارة في مدتها.

القول الثاني: وهو الأصح، أن الإجارة تجوز أكثر من سنة، وذلك استدلالًا بما يلي:

١- ما جاء في قوله تعالى: {قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُكِّحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِي حَجَّ} القصص ٢٧، فدل ذلك على جواز الإجارة سنتين.

٢- ما روى أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه تكارى أرضًا، ولم تزل بيده حتى مات، فقال أحد أقاربه: ما كنت أراها إلا له من طول ما مكثت بيده، حتى ذكرها عند موته، وأمرنا بقضاء شيء بقي عليه من كرائها من ذهب أو ورق ^(٢).

٣- إن الضرورة والحاجة قد تدعو في الإجارة إلى أكثر من سنة، ومن ثم إذا اقتضت الإجارة على سنة فكيف يستوفى صاحب الغرس منافعه؟.

(١) الحاوي الكبير ج ٩ ص ٢٩٣.

(٢) البيهقي ٦ / ١١٩.

ويجدر بنا ونحن بصدد الحديث عن المدة أن نشير إلى الفروع والملاحظات الآتية:

الملاحظة الأولى:

أن تحديد المقصود من السنة وصحته يتوقف على ما يلي:

- ١- أن يشترط سنة هلالية، فيصح، ويكون العقد على اثني عشر شهرًا بالأهلة، ويكون قدر السن الهلالية ثلاثمائة وأربعة وخمسين يومًا، وهذا أخص الآجال بالشرع قال تعالى: (يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهْلِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ) البقرة جزء من الآية رقم: (١٨٩).
- ٢- أن يشترط سنة عددية، فيصح ويكون العقد على ثلاثمائة وستين يومًا كاملة؛ لأن عدد الشهر مستوف بكماله.
- ٣- أن يشترط سنة شمسية، وهي ثلاثمائة وخمسة وستون يومًا وربع يوم، فهذا التحديد بالسنة الشمسية محل خلاف عند الأصحاب من الشافعية؛ إذ يجيزه البعض اعتمادًا على أن المدة معلومة وواضحة، بينما يرى البعض الآخر أن هذا التحديد باطل؛ لأن السنة هنا محددة بحسابات تتسأ فيها الأيام.
- ٤- أنه يتم ذكر السنة مطلقة عن التقييد بكونها هلالية أو عددية أو شمسية، ففي هذه الحالة تصح الإجارة، وتعتبر السنة الهلالية؛ لأنها المعتبرة في الآجال الشرعية ^(١).

الملاحظة الثانية:

(١) الحاوي الكبير ج ٩ ص ٢٩٣.

إذا استأجر الرجل أرضًا مدة معلومة ليزرعها زرعًا موصوفًا، ثم انقضت هذه المدة قبل استحصاد الزرع، فإن الشافعية يفرقون بما يلي:

١- إن كان يُعلم بجاري العادة أن مثل هذا الزرع لا يستحصد ولا ينضح في مثل هذه المدة، كأن يستأجرها ثلاثة أشهر لزرع يحتاج ستة أشهر، فإن الزارع يتحمل المسؤولية في هذه الحالة، ويؤخذ بقلع زرعه وقطعه إن قلنا بصحة الكراء، ويرى الإمام الشافعي فساد الإجارة في هذه الحالة حيث يقول: "وإن تكارها مدة هي أقل من سنة، وشرط أن يزرعها شيئًا بعينة وتركه حتى يستحصد، وكان يعلم أنه لا يمكنه أن يستحصد في مثل هذه المدة التي تكارها إليها، فالكراء فاسد^(١)."

٢- إذا كان يعلم بجري العادة أن مثل ذلك الزرع يستحصد في مثل تلك المدة، ثم انقضت المدة قبل الحصاد، وكان تأخر الحصاد راجعًا إلى المستأجر كأن عدل إلى نوع آخر من الزرع أو تأخر في البذر، فإنه يعد مفرطًا ومتعديًا يؤخذ بقلع زرعه، ما لم يبذل أجرة مثل المدة الزائدة ويرضى المؤجر بقبولها.

الملاحظة الثالثة:

إذا استأجر أرضًا ليغرس فيها أو يبني فانقضى الأجل، فليس له بعد انقضاء الأجل أن يحدث غرسًا جديدًا، فإن فعل كان متعديًا، وأخذ بقلع ما أحدثه بعد الأجل.

وأما الغرس القائم في الأرض قبل انقضاء الأجل، فإن حكمه يختلف وفق شرطهما، على النحو التالي:

(١) الأم ج ٣ ص ٢٤٢.

- ١- أن يشترطاً قلعه عند انقضاء المدة، فيؤخذ المستأجر بقلع غرسه.
- ٢- أن يشترطاً تركه بعد انقضاء المدة، فيقر ولا يفسد العقد بهذا الشرط،
ويصير بعد انقضاء المدة مستعيراً عند الإمام الشافعي، وعليه أجرة المثل
عند المزني ما لم يصرح له بالعارية.
- ٣- أن يكون العقد مطلقاً دون شرط قلعه أو تركه، ففي هذه الحالة يؤخذ
المستأجر بقلعه إن كانت قيمته مقلوعاً كقيمه قائماً، وأما إن كانت قيمته
مقلوعاً أقل من قيمته قائماً، فيخير رب الأرض المستأجر بين أن يعطيه
قيمه قائماً ويحتفظ به رب الأرض، وبين أن يعطيه الغرس مقلوعاً مع
فرق النقص بين قيمته قائماً ومقلوعاً، فإن امتنع رب الأرض أن يفعل هذا،
ننظر إلى المستأجر، فإن امتنع هو ايضاً من بذل أجرة المثل بعد انقضاء
المدة، أخذ بقلعه، وأما إن بذل أجرة المثل ففيه خلاف:

- أ- ذهب الشافعي ^(١) وجمهور الأصحاب إلى أن الغرس والبناء مقر لا يؤخذ
المستأجر بقلعها استدلالاً بقوله صلى الله عليه وسلم "ليس لعرق ظالم
حق" ^(٢) والعرق الظالم هو أن يغرس الرجل في أرض غيره بغير حق، فقد
اقتضى الحديث فرقاً بين الظالم والمحق، فلم يجر أن نسوي بينهما
في الأخذ بالقلع، كما أن إن رب الأرض لغيره بالغرس في أرضه محمولاً
على العرف المعهود في مثله، والمعهود في الغرس تركه حتى الاستيفاء.
- ب- ذهب أبو حنيفة المزني من الشافعية إلى أن المستأجر يؤخذ بقلعها، ولا
يجبر رب الأرض على تركه بعد انقضاء المدة، وقد استدل المزني على
ذلك بقوله تعالى: (إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ) [سورة النساء: ٢٩]،
ولا يوجد رضى من رب الأرض فلا يجبر على شيء، وهذا الرأي

(١) الأم ج ٣ ص ٢٤٤.

(٢) أبو داود كتاب إحياء الموات رقم ٣٠٧٣.

هو ما رجحه الماوردي وقال عنه: " وهذا المذهب أظهر حجاجا وأصح اجتهداً"^(١).

الشرط الثاني: بيان غرض الاستئجار:

تتعدد الأغراض المقصودة من وراء استئجار الأرض، فقد تكون الإجارة بهدف زرع المحاصيل التقليدية كالقمح والشعير ونحوه، وقد يكون الهدف زرع المحاصيل البستانية كأشجار الفواكه والنخيل ونحو ذلك، وهو ما يعبر عنه الفقهاء "بالغرس"، وقد يكون المقصود من الإجارة البناء على الأرض، وفي جميع الأحوال، فإن من شروط صحة الإجارة ضرورة بيان الغرض منها، فيقول المستأجر: استأجرت لأزرع، أو يقول: استأجرت لأغرس كذا....، فإذا أغفل المستأجر له بطات الإجارة؛ لأن التأثير العائد على الأرض من جراء الانتفاع يختلف باختلاف ما يستأجرها له، وترتبط بهذا الشرط عدة فروع أهمها:

أ- إذا استأجر أرضاً ليزرعها زرعاً معيناً كالقمح، فيحق له أن يزرعها قمحاً أو زرعاً آخر غير القمح المتفق عليه، بشرط أن يكون ضرره على الأرض مثل ضرر القمح المتفق عليه أو أقل، ومن ثم فليس من سلطة الزارع المستأجر أن يزرعها نوعاً يكون ضرره على الأرض أكثر من ضرر الزرع المتفق عليه.

ويستدل الشافعية على أن من سلطة المستأجر أن يجنح إلى زرع نوع آخر غير المتفق عليه بشرط ألا يكون أزيد في ضرره على الأرض من الزرع المتفق عليه بما يلي:

(١) مختصر المزني وشارحه، والحاوي ج ٩ ص ٣٠٩، ٣١٠.

أن ذكر نوع الزرع (القمح مثلاً) في إجارة الأرض إنما هو لتقدير المنفعة به، دون أن يقصد به تعيين استيفائه، بدليل أنه لو تسلم الأرض ولم يزرعها لزمته الأجرة.

فإن ثبت أن ذكر نوع الزرع هو لتقدير المنفعة، فيحق للمستأجر أن يستوفي المنفعة بما قدرت به في العقد وبغيره.

ب- إذا وسع المؤجر من سلطة المستأجر في الزرع، فقال له: ازرعها ما شئت، أو قال المستأجر في صيغة العقد: ازرعها ما أشاء، صح الكراء، وجاز له أن يزرعها جميع الأصناف يستوي أن يكون الضرر قليلاً أو كثيراً.

الشرط الثالث: امكان استيفاء المنفعة:

إن من أهم الالتزامات التي تقع على عاتق المؤجر للأرض الزراعية أنه يُمكن المستأجر من استيفاء المنفعة، ومن ثم فإن استئجار الأرض للزراعة مدة سنة يتطلب أن يكون لها وقت العقد ماء قائم يسقى به الزرع من عين أو نهر أو نيل ونحو ذلك،.... فأما إذا تعذر استيفاء المنفعة، فإن الحكم يختلف وفقاً للصور والفروع التالية:

أ- إذا استأجر أرضاً للزرع ولها ماء قائم، فزرعها إحدى الغلتين، ثم نضب الماء أو نقص أو ملح، ومن ثم لم يتمكن المستأجر من زرع الغلة الثانية، ففي هذه الحالة لو استطاع مالك الأرض أن يعيد الماء الصالح للزراعة، فالإجارة باقية بحالها، وإلا يكون المستأجر بالخيار بين المقام أو فسخ العقد ورد الأرض ويكون عليه من الأجرة والكراء بحصة ما زرع.

ولقد بلور الإمام الشافعي هذه الصورة وبين حكمها بقوله: "إذا تكأرى الرجل الأرض ذات الماء من العين، أو النهر نيل، أو غير نيل، أو الغيل، أو الآبار على أن يزرعها غلة الشتاء والصيف فزرعها إحدى الغلتين والماء قائم ثم نضب الماء فذهب قبل الغلة الثانية فأراد رد الأرض بذهاب الماء فذلك له ويكون عليه من الكراء بحصة ما زرع إن كانت حصة الزرع الذي حصد الثلث، أو النصف، أو الثلثين أو أقل، أو أكثر أدى إلى ذلك وسقطت عنه حصة الزرع الثاني الذي انقطع الماء قبل أن يكون"^(١).

ب- إذا استأجر أرضًا بيضاء لا ماء لها دائم، وإنما تسقى بالري الموسمي بالمطر أو السيل، الأصل أنه لا تصح إجارتها للزراعة، لتعذر استيفاء المنفعة، ويستثنى من هذا ما لو قال: أجرتكها على أنها أرض بيضاء لا ماء، لتصنع بها ما شئت على أن لا تبني ولا تغرس، ففي هذه الحالة يصح الكراء، والمعنى في هذا الشرط هو ألا يتوهم المستأجر أن المؤجر ملتزم بتوصيل الماء إلى الأرض، لما عليه من الالتزام.

ج- إن علا الماء على الأرض فأغرقها وأقام فيها، فالأصل أنه لا تجوز إجارتها، لتعذر استيفاء المنفعة، ويستثنى من هذا الأصل، ما لو استأجرها لما يمكن زرعه مع بقاء الماء الأرز، أو يعلم بجارى العادة أن الماء ينحسر عنها يقينًا قبل حلول وقت الزراعة، كأن يكون لها مغيض يفتح فينزل فيه الماء، فهنا تجوز الإجارة في الأحوال التالية:

١- أن يكون الماء صافيًا أو قليلًا لا يمنع من مشاهدة الأرض.

(١) الأم ج ٣ ص ٢٤٢.

٢- أن تتقدم رؤية الأرض قبل علو الماء عليها في حالة تعذر مشاهدتها؛
لكثرة الماء أو وجود كدرة فيه ^(١).

الفصل السابع

الفصل الخامس

الإقطاع الشرعي ^(٢)

المبحث الأول

حقيقة ومشروعية الإقطاع الشرعي

حقيقة الإقطاع الشرعي .

الإقطاع لغة: مأخوذة من القطع وهو: إبانة بعض أجزاء الجرم من بعض فصلاً إلى
أن نقول: قطعه يقطعه قطعاً ^(١).

(١) الحاوي ج ٩ ص ٢٩٩، ٣٠١.

(٢) كتبه: أ. د/ محمد عامر.

وشرعاً: ذكر ابن حجر تعريفاً عن القاضي عياض يعرف الإقطاع بأنه: "تسويغ الإمام من مال الله شيئاً لمن يراه أهلاً لذلك وأكثر ما يستعمل في الأرض وهو أن يخرج منها لمن يراه ما يحوزه إما بأن يملكه إياه فيعمره وإما بأن يجعل له غلته مدة" (٢).

ويلاحظ أن هذا التعريف قد اشتمل على عدد من المرجحات مما يجعله أكثر قبولاً من التعريفات الأخرى (٣)، وأهم ما اشتمل عليه:

١- أنه جعل الإقطاع من حق الإمام، وهذا من الشروط الجوهرية في الإقطاع، حتى يستطيع تقدير المصلحة، ويتمكن من قطع التشاحن بين الناس.

٢- إن قوله: "من مال الله" أعم مما جاء في بعض التعريفات التي عبرت "بالأرض"، وذلك أن قوله: "من مال الله" يشمل كل أنواع الإقطاع: كإقطاع التملك، وإقطاع العامر، وإقطاع الاستغلال.

٣- إن قوله: "لمن يراه أهلاً لذلك" يدل على أن الإقطاع من قبل الإمام منوط بالمصلحة العامة للدولة الإسلامية، وهذا من الشروط المعتبرة في الإقطاع كما نرى.

(١) لسان العرب: ابن منظور، ج٥، ص ٣٦٧٤.

(٢) فتح الباري شرح صحيح البخاري، لابن حجر العسقلاني، ج٥، ص ٣٦، دار المعرفة - بيروت.

(٣) د/ عبد الوهاب حواس، الإقطاع وأثره في التنمية، دار النهضة العربية ١٩٩٤، ص ١٨، ١٩.

أدلة مشروعية الإقطاع:

لقد ثبتت مشروعية الإقطاع بالسنة النبوية المطهرة، كما دل على هذه المشروعية فعل الخلفاء الراشدين بعد النبي -ﷺ-، ومن أهم هذه الأدلة:

١- عن أسماء بنت أبي بكر -رضي الله عنهما-، أن رسول الله -ﷺ- أقطع الزبير أرضًا بخيبر فيها شجر ونخل، وأن النبي -ﷺ- أقطع الزبير أرضًا من أموال بني النضير. وروى أبو داود: أن النبي -ﷺ- أقطع الزبير حضر فرسه^(١)، فأجرى فرسه حتى قام، ثم رمى بسوطه، فقال -ﷺ-: «أَعْطُوهُ مِنْ حَيْثُ بَلَغَ السَّوْطُ»^(٢).

٢- وعن أبي رافع قال: أعطاهم النبي -ﷺ- أرضًا، فعجزوا عن عمارتها، فباعوها في زمن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- بثمانية آلاف دينار، فوضعوا أموالهم عند علي بن أبي طالب -رضي الله عنه-، فلما أخذوها وجدوها تنقص، فقالوا هذا ناقص، قال: احسبوا زكاته، قال: فحسبوه فوجدوه كافيًا، فقال: أحسبتم أني أمسك ما لا أزيكه؟

٣- وأقطع النبي -ﷺ- إلى بلال بن الحارث المزني، وكتب له النبي -ﷺ- كتابًا "بسم الله الرحمن الرحيم"، هذا ما أعطى محمد رسول الله -ﷺ- بلال بن الحارث المزني، أعطاه معادن القبلية، جلسها وغوريها^(٣).

(١) الحضر بضم الحاء ارتفاع الفرس بالعدو، والمراد قدر ما يعدو الفرس عدوة واحدة دون توقف.

(٢) الأموال لأبي عبيد: رقم ٦٧٨، أبو داود، رقم ٣٠٧٢.

(٣) سنن أبي داود: القبلية: ناحية قرب المدينة، وجلسها هو المرتفع من الأرض، وغوريها المراد به المواضع المرتفعة والمنخفضة من معادن القبلية.

ويلاحظ أن الإقطاع كما ثبت بالسنة، وقد عمل به الخلفاء الراشدون، يدل على ذلك صنيعهم في الإقطاع لأحاديث الأمة، ولم ينكر عليهم أحد ذلك فكان إجماعاً.

ثالثاً: شروط الإقطاع^(١):

الشرط الأول أن يكون الإقطاع من الإمام:

فقد ذهب الشافعية إلى أن الذي يملك الحق في الإقطاع هو الإمام وحده أو من يقوم مقامه، ذلك لأن تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة وفقاً للقاعدة الفقهية، ففي خطاب أبي يوسف إلى أمير المؤمنين: "ولك أن تقطع ذلك من أحببت ورأيت وتؤاجره، وتعمل فيه بما ترى أنه صلاح، وكل من أحيا أرضاً مواتاً فهي له".

وقد كان أبو حنيفة رحمه الله يقول: من أحيا أرضاً مواتاً فهي له إذا أجازها الإمام، ومن أحيا أرضاً مواتاً بغير إذن الإمام فليست له، ولالإمام أن يخرجها من يده ويصنع فيها ما رأى من الإجارة والإقطاع وغير ذلك^(٢).

الشرط الثاني: ضرورة تحري منفعة المسلمين:

يشترط الشرع في عقود الإقطاع الشرعي ضرورة تحري منفعة المسلمين العامة، ويشهد لذلك ما رواه أبو عبيد وغيره من أن رجلاً بالبصرة يقال له نافع أبو عبد وكان أول من افتلى الفلا^(٣) بالبصرة، أتى عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-، فقال: إن بالبصرة أرضاً ليست بأرض الخراج ولا تضر بأحد من المسلمين، وكتب

(١) لمزيد من التفصيل يراجع الإقطاع في الفقه الإسلامي وأثره في التنمية، مرجع سابق، ص ٢٥-٣٥.

(٢) الخراج: لأبي يوسف، ص ٦٤.

(٣) قيل الصحراء الواسعة، لسان العرب: ج٥، ص ٣٤٧٠.

أبو موسى الأشعري إلى عمر مؤيداً ما ذكره الرجل -فكتب عمر بن الخطاب - رضي الله عنه- إلى أبي موسى الأشعري: إن كانت لا تضر بأحد من المسلمين، وليست من أرض الخراج فأقطعها إياه^(١).

الشرط الثالث: قدرة المقطع على حسن الاستغلال:

إن الإقطاع الشرعي يهدف إلى تمكين الدولة الإسلامية من استغلال مواردها الطبيعية عن طريق جهود القادرين، ومن ثم يجب أن يكون الإقطاع الشرعي لمن تتأكد قدرته على حسن الاستغلال لهذه الموارد، وأن تكون مساحة الإقطاع في حدود قدرته الاستغلالية. فإذا عجز عن ذلك كان من حق الدولة الإسلامية استرداد إقطاعها كله أو جز منه. يقول الشافعي: "ولا ينبغي أن يقطع من المعادن إلا قدر ما يحتمل"^(٢).

ويدل على ذلك: ما روي أن بلال بن الحارث المزني جاء إلى رسول الله -ﷺ- فاستقطعه أرضاً، فقطعها له طويلة عريضة، فلما ولي عمر رضي الله عنه - قال له: " يا بلال، إنك استقطعت رسول الله -ﷺ- أرضاً طويلة عريضة قطعها لك، وإن رسول الله -ﷺ- لم يكن ليمنع شيئاً يسأله، وإنك لا تطيق ما في يديك " فقال بلال: أجل، فقال عمر: "فانظر ما قويت عليه منها فأمسكه، وما لم تطق، وما لم تقو عليه فادفعه إلينا نقسمه بين المسلمين" فقال بلال: لا أفعل والله، شيء أقطعنيه رسول الله -ﷺ-، فقال عمر: "والله لتفعلن" فأخذ منه ما عجز عن

(١) الأموال: ص ٢٩٠، رقم ٦٨٩.

(٢) الحاوي الكبير: للماوردي، ج ٧، ص ٤٩٨.

عمارته فقسمه بين المسلمين.^(١)، وهذا يدل على أن مساحة الإقطاع يجب أن تكون في متناول القدرة الاستغلالية للمقطع.

كما يمنع الإسلام الأفراد أن تحتفظ عن طريق الاقتطاع أكثر من طاقتها على الاستغلال، كما لا يعطي الإسلام للأفراد الذين يبدأون عملية إحياء الأرض الحق في تجميد نشاطهم وتعطيل تلك المصادر، ولم يسمح لهم في حالة توقفهم عن مواصلة العمل أن يحتفظوا بها، لما لذلك من أثر سلبي يتمثل في حرمان الإنتاج من طاقات تلك المصادر، لما روي أن رسول الله - ﷺ - قال: «عادي الأرض لله وللرسول ثم لكم من بعد؛ فمن أحيا أرضاً ميتة فهي له، وليس لمحتجر حق بعد ثلاث سنين»^(٢)، وعن سالم بن عبد الله أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال وهو على المنبر: «من أحيا أرضاً ميتة فهي له، وليس لمحتجر حق بعد ثلاث سنين»^(٣).

وذهب الماوردي من الشافعية إلى أن المقتطع يستبقى ما في يده إن كان له عذر واضح وظاهر حتى يزول هذا العذر، أما إذا لم يكن له عذر ومضى زمن يسمح العرف بالإحياء فيه، فالإمام أن يخيره بين إحيائها أو أن يرفع يده عنها^(٤).

كما أنه لا يجوز لولي الأمر أن يقطع فرداً من مصادر الطبيعة شيئاً إلا بالقدر الذي يتمكن الفرد من استثماره والعمل فيه؛ لأن إقطاعه ما يزيد على قدرته الاستثمارية يبدد الثروات، ولذا يقول ابن قدامي: "ولا ينبغي أن يقطع الإمام أحداً

(١) الخراج: ص ٦٧، الأموال: ص ٣٠٢، حاشية الشرقاوي على التحرير: ج ٢، ص ١٨٢.

(٢) الخراج: ص ٧٠.

(٣) الخراج: ص ٧١، الأموال: ص ٣٠٣.

(٤) الأحكام السلطانية للماوردي: ص ٢٤٠.

من الموات إلا ما يمكنه إحياءه؛ لأن في إقطاعه أكثر من ذلك تضيقاً على الناس في حق مشترك بينهم بما لا فائدة فيهم" (١).

الشرط الرابع: ألا يكون المقطع مملوكاً لأحد:

ومفاد هذا الشرط أنه لا يجوز للإمام أن يقطع ما لا مملوكاً لأحد الناس، ذلك أن محل الإقطاع مقصور على ما جاز للإمام التصرف فيه وإلا كان غاصباً لأموال الناس. وقد أورد الإمام الشافعي في الأم ما يفيد ضرورة إظهار هذا الشرط في الكتاب الذي يكتبه الإمام للمقطع، فيقول الشافعي: "فللسلطان أن يقطع من طلب موأناً، فإذا أقطع كتب في كتابه، ولم أقطعه حق مسلم، ولا ضرراً عليه" (٢).

كما يؤكد الماوردي من الشافعية هذا الشرط بقوله: "واقطع الإمام مختص بما جاز فيه تصرفه ونفذت فيه أوامره، ولا يصح فيما تعين مالكه وتميز مستحقه" (٣)، فأما إن أخذ الوالي من يد واحد أرضاً وأقطعها آخر، فهذا بمنزلة الغاصب غصب واحداً وأعطى آخر (٤).

ويدل على ما سبق: ما رواه يحيى بن آدم أن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- ، كتب إلى سعد، ليقطع سعيد بن زيد أرضاً، فأقطعه أرضاً لبني الرفيل، فأتى ابن الرفيل عمر فقال: يا أمير المؤمنين: علام صالحتمونا؟ قال: على أن تؤدوا إلينا

(١) المغني: ج٦، ص١٦٦، كشف القناع: ج٤، ص١٩٥.

(٢) الأم: ٣/٣٦٩.

(٣) الأحكام السلطانية: ص١٩٠.

(٤) الخراج: ص٦٠.

الجزية ولكم أرضكم وأموالكم وأولادكم، قال: يا أمير المؤمنين أقطعت أرضي لسعيد بن زيد، قال: فكتب إلى سعد: ترد عليه أرضه^(١).

ووجه الدلالة على ما سبق ظاهر، حيث رجع عمر -رضي الله عنه- في إقطاعه عندما تبين له أن الأرض المقطعة قد تعلق بها حق الغير، ومن ثم فقد خرجت عن محل تصرفه وقدرته على الإقطاع.

الشرط الخامس: عدم التعارض مع المصلحة العامة:

إن الإسلام يعمل على التوازن بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة، فلا تطغى واحدة على الأخرى. وعلى ذلك فلا يجوز للإمام أن يقطع شيئاً يترتب عليه أضرار للمصلحة العامة، حتى أنه إذا غرر بالإمام فأقطع نتيجة تدليس وقع عليه، ثم ظهر أن ضرراً سيحقيق بالصالح العام، فإن من حق الإمام أن يهدر هذا الإقطاع ويعتبره كأن لم يكن.

ويدل على ذلك ما يلي:

١- ما رواه أبو داود بسنده عن قيلة بنت مخرمة، قالت قدمنا على رسول الله - ﷺ - فتقدم حريث بن حسان وافد بكر بن وائل، فبايعه على الإسلام عليه وعلى قومه، ثم قال: يا رسول الله، اكتبْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ بَنِي تَمِيمٍ بِالْذَّهْنَاءِ، أَنْ لَا يُجَاوِزَهَا إِلَيْنَا مِنْهُمْ أَحَدٌ، إِلَّا مُسَافِرٌ أَوْ مُجَاوِرٌ، فَقَالَ: «اكتبْ لَهُ يَا غُلَامُ بِالْذَّهْنَاءِ» فَلَمَّا رَأَيْنَاهُ قَدْ أَمَرَ لَهُ بِهَا، شَخِصَ بِي وَهِيَ وَطَنِي وَدَارِي، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهُ لَمْ يَسْأَلْكَ السَّوِيَّةَ مِنَ الْأَرْضِ إِذْ سَأَلَكَ، إِنَّمَا هِيَ هَذِهِ الذَّهْنَاءُ عِنْدَكَ مُقَيَّدُ الْجَمَلِ، وَمَرَعَى

(١) يحيى بن آدم: الخراج ص ٦٠.

الْعَنَمِ، وَنِسَاءُ بَنِي تَمِيمٍ وَأَبْنَاؤُهَا وَرَاءَ ذَلِكَ، فَقَالَ: «أَمْسِكْ يَا غُلَامُ، صَدَقَتْ الْمُسْكِينَةُ، الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ يَسْعُهُمَا الْمَاءُ، وَالشَّجَرُ، وَيَتَعَاوَنَانِ عَلَى الْفَتَانِ»^(١).

٢- ما رواه أبو دود بسنده عن أبيض بن حمال، أنه وفد إلى النبي -ﷺ- فاستقطعه الملح الذي بمأرب، فقطعه له، فلما ولى قال رجل من المجلس: ما أقطعت له، إنما أقطعت له الماء العد، قال فانترع منه وقال: وسأله عما يحمى من الأراك؟ قال: «ما لم تنله أخفاف الإبل»^(٢).

وجه الدلالة من الحديثين السابقين على اشتراط عدم تعارض الإقطاع مع الصالح العام ظاهرة، حيث أمسك النبي -ﷺ- عن إقطاع حريث بن حسان عندما علم بتعارض هذا الإقطاع مع الصالح العام. كما انتزع ما أقطعه أبيض بن حمال عندما علم أن ما أقطعه مورد عام يحتاجه الناس جميعاً، ولذا يقول بن قدامى بعد أن ذكر حديث أبيض بن حمال: "ولأن هذا تتعلق به مصالح المسلمين العامة، فلم يجز إحيائه، ولا إقطاعه، كمشارع الماء، وطرقات المسلمين"^(٣).

(١) رواه أبو داود: ج٣، ص١٧٤، والفتان هو الشيطان الذي يفتن الناس عن دينهم.

(٢) رواه أبو داود: ج٣، ص١٧٤.

(٣) المغني: ج٦، ص١٥٧.

المبحث الثالث

أقسام الإقطاع الشرعي

ثمة أقسام متعددة للإقطاع الشرعي يحسن تتبعها ومعرفة أحكامها . ويمكن القول أن الفقهاء قد قسموا الإقطاع الشرعي إلى ثلاثة أقسام وهي:

القسم الأول: إقطاع التملك.

القسم الثاني: إقطاع الاستغلال.

القسم الثالث: إقطاع الارتفاق^(١).

القسم الأول

إقطاع التملك

ومفاد إقطاع التملك هو: تخصيص الإمام قطعة من الأرض أو ما شابه ذلك، رغبة ومنفعة أو منفعة فقط لمن تتوافر فيه القدرة من الأشخاص على الاستفادة منها. ويدور إقطاع التملك في غالبه حول صور ثلاث، وهي إقطاع الموات، وإقطاع العامر، وإقطاع المعادن. وسنلقي الضوء على كل منها.

الصورة الأولى: إقطاع الموات

والموات أو الموتان -بفتح الميم والواو- هو من كل شيء غير روح، ومن الأرض ما لم تزرع ولم تعمر ولا جرى عليها ملك أحد من البشر^(١). وقد وردت الأرض

(١) د/ عبد الوهاب حواس: الإقطاع في الفقه الإسلامي، دار النهضة العربية، سنة ١٩٩٤،

الموات في القرآن الكريم بمعنى الجذبة القحطاء التي انقطع عنها المطر فيبيست وأصبحت غير ذي ذرع، فقال تعالى: ﴿وَاللَّهُ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ﴾^(١).

أما الأرض الموات اصطلاحاً: فقد عرفها الماوردي من الشافعية بأنها: " كل ما لم يكن عامراً ولا حريماً لعامر فهو موات، وإن كان متصلاً بعامر"^(٢).

وقد قسم الماوردي الموات إلى قسمين:

الأول: ما لم يزل مواتاً على قديم الدهر، ولم تجر فيه عمارة، ولم يكن لأحد ملك عليه، فهذا يجوز للسلطان إقطاعه لمن يقدر على عمارته.

والثاني: ما كان عامراً فخرّب، ثم صار مواتاً عاطلاً، وهذا القسم يتنوع إلى:

١- عادي: كأرض عاد وشمود، فحكمه كالموات الذي لم تثبت فيه عمارة، ومن ثم يجوز إقطاعه.

٢- ما يثبت عليه ملك المسلمين، ثم خرب حتى صار مواتاً عاطلاً. وهذا الضرب قد وقع فيه الخلاف بين الفقهاء، فالإمام الشافعي يرى أنه لا يملك بالإحياء سواء عرف أربابه أو لم يعرفوا. بينما فصل الإمام أبو حنيفة، فقال: إن عرف أربابه لم يملك بالإحياء، وإن لم يعرفوا ملك بالإحياء. وقد قال الحنابلة مثل قول الشافعية^(٤).

(١) لسان العرب: ج٢، ص٩٣.

(٢) سورة النحل: آية ٦٥.

(٣) الأحكام السلطانية: ص٢٣١.

(٤) الأحكام السلطانية: ص٢٣١، ٢٤٩، الأم: ج٣، ص٢٦٤.

أدلة مشروعية إحياء الموات:

لقد ثبتت مشروعية الإحياء بالسنة والإجماع، أما السنة فأحاديث كثيرة منها:

١- ما أخرجه أبو داود، والترمذي عن سعيد بن زيد، وجابر بن عبد الله رضي الله عنهما - أن النبي - ﷺ - قال: «مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً، فَهِيَ لَهُ»^(١)، وزاد سعيد بن زيد: «وَلَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ».

٢- ما أخرجه البخاري عن عروة بن الزبير، عن عائشة - رضي الله عنها -، عن النبي - ﷺ - قال: «مَنْ أَعْمَرَ أَرْضًا لَيْسَتْ لِأَحَدٍ فَهُوَ أَحَقُّ»، قَالَ عُرْوَةُ بْنُ الزَّبِيرِ: «قَضَى بِهِ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي خِلَافَتِهِ»^(٢).

٣- عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - ﷺ -: «مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَلَهُ فِيهَا أَجْرٌ، وَمَا أَكَلَتِ الْعَافِيَةُ مِنْهَا، فَلَهُ فِيهَا صَدَقَةٌ»^(٣).

فهذه الأحاديث تدل على مشروعية الإحياء في الإسلام، وأن من أحيا أرضاً ميتة فهي له، مما يدل على أنه يستحق هذه الأرض ويثبت له الملك، حتى ولم يتلفظ بذلك.

(١) أبو داود: رقم ٣٠٧١.

(٢) أخرجه البخاري رقم ٢٣٣٥.

(٣) سنن الدارمي: رقم ٢٦٤٩.

شروط إحياء الأرض الموات .

الشرط الأول: انتفاء ملك الغير .

فلا يجوز إحياء أرض تقرر عليها حق لآخر، ويستدل على هذا الشرط من أحاديث النبي -ﷺ-، فقد أخرج البخاري عن عائشة رضي الله عنها - عن النبي -ﷺ- قال: «مَنْ أَعْمَرَ أَرْضًا لَيْسَتْ لِأَحَدٍ فَهُوَ أَحَقُّ».

فقوله: -ﷺ- «لَيْسَتْ لِأَحَدٍ» يدل على ضرورة انتفاء ملك الغير عن الأرض المحيية.

الشرط الثاني: ألا يكون الموات حريمًا لعامر .

والحريم هو ما تمس الحاجة إليه لتمام الانتفاع بالمعمور . وقد ذهب الشافعية ووافقهم باقي المذاهب في المنع من إحياء حريم العامرة، فيقول الرملي: "ولا يملك بالإحياء حريم معمور؛ لأنه ملك لمالك المعمور" ^(١)؛ ولأن الحريم يدخل في حقوق مالك المعمور، وقد قال -ﷺ- «مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فِي غَيْرِ حَقِّ مُسْلِمٍ فَهِيَ لَهُ»

ويلاحظ أن حريم كل شيء يختلف باختلاف الحاجة إلى هذا الشيء، فحريم القرية -كما صورته النووي في المنهاج- يشمل النادي، ومرتكض الخيل، ومناخ الإبل، ومراح الغنم، وملعب الصبيان والشباب....الخ.

(١) نهاية المحتاج للرملي: ج٥، ص ٣٣٤.

صفة الإحياء:

إن ماهية الإحياء تعني الاستغلال الأمثل للأرض، ولقد وضع الفقهاء تصوراتهم الكيفية التي يتم بها إحياء الموات، ويجمع بين تلك التصورات النتيجة والغاية المقصودة من الإحياء وهي الاستغلال الأمثل للأرض.

وعند الشافعية يعتبر الإحياء بالعرف فيما يراد له الإحياء، ودليلهم أن الرسول - ﷺ - أطلق ذكره إحالة على العرف المعهود فيه. والضابط في الإحياء عند الشافعية هو أن يهياً كل شيء لما قصد منه غالباً. وعلى ذلك فإن صفة الإحياء عند الشافعية يرجع فيها إلى العرف، وهذا يختلف من شيء لآخر، ومن أمثلة ذلك:

لو قال: أريد إحياء هذه الأرض للزراعة، فلا بد لها من ثلاثة شروط:

- ١- أن يجمع لها تراباً يحيط بها ويميزها عن غيرها.
- ٢- أن يسوق الماء إليها إن كنت يابسة من نهر أو بئر، وإن كانت بطائح حبس الماء عنها؛ لأن إحياء البطائح يكون بحبس الماء عنها وتجفيفها.
- ٣- أن يحرثها ليتمكن من زرعها، والحرث بجمع وبمسح ما استعلى، وتعلية ما انخفض، وذلك كله حتى يتمكن من تهيئتها للزراعة^(١).

(١) الحاوي: ج٩، ص ٣٢٤.

ملكية الأرض المحياه:

إذا تم الإحياء بالكيفية المعتبرة، فإنه يترتب على ذلك ثبوت الملك لمن قام بالإحياء، ولا يحتاج في ذلك إلى صيغة أو تلفظ. أما كون الإحياء يفيد التملك لمن قام بالإحياء فقد ذهب إليه جمهور الفقهاء ومنهم الشافعية للأدلة التالية:

١- قوله -ﷺ-: «من أحيا أرضاً ميتة فهي له»، حيث جعل الرسول -ﷺ- الملك للمحيي بالإضافة بلام التملك، وهذا واضح من قوله: «فهي له».

٢- ذكر يحيى بن آدم القرشي في كتابه الخراج عن هشام بن عروة عن أبيه قال: قال رسول الله -ﷺ-: «من أحيا أرضاً ميتة فله رقبته، وليس لعرق ظالم حق»، وأخرج أيضاً عن طاووس قول رسول الله -ﷺ-: «عادي الأرض لله وللرسول ثم لكم من بعد، فمن أحيا شيئاً من موتان الأرض فله رقبته».

وجه الدلالة من الحديثين ظاهر، ذلك أن الرسول -ﷺ- أثبت للمحيي أهم عناصر الملكية، وهي أن يملك المحيي حق الرقبة، ومن ثم يجوز التصرف فيما ملكه.

الصورة الثانية : إقطاع العامر

والعامر لغة: ضد الخراب. يقال عمرتُ الخراب أعمره عمارة فهو عامر، وينقسم العامر إلى قسمين: أحدهما: ما تعين مالكة، والثاني: ما لم يتعين مالكة^(١).

وقد ذهب الشافعية إلى عدم جواز إقطاع هذا القسم من العامر التابع لبيت المال إقطاع تملك، وحجتهم في ذلك أنه صار ملكاً لجميع المسلمين، فجرى على رقبته حكم الوقوف المؤبدة، وتمليك الوقف لا يجوز.

الصورة الثالثة : إقطاع المعادن

المعدن في اللغة: مأخوذ من المعدن، وهو الإقامة، ومنه جنات عدن أي: جنات إقامة، وفي مختار الصحاح "عدنت بالبلد: توطنته"، وفي لسان العرب "...ومعدن الذهب والفضة سمي معدناً لإنبات الله في جوهريهما، وإنباته إياه في الأرض حتى عدن: أي ثبت فيها.....والمعادن: المواضع التي يستخرج منها جواهر الأرض"^(٢).

واصطلاحاً: فيطلق الفقهاء المعدن ويقصدون به أحد أمرين:

الأول: الأمكنة التي خلق الله فيها الجواهر من ذهب وفضة ونحوهما... وقد ذهب إلى ذلك الماوردي، والخطيب الشربيني من الشافعية، والخرشي من المالكية. فيقول الماوردي: "هي البقاع التي أودعها الله تعالى جواهر الأرض"، ويقول الشربيني: "إن المعدن هو: اسم للمكان الذي خلق الله تعالى فيه الجواهر من الذهب والفضة....".

(١) الأحكام السلطانية: ص ٣٣٩، وبعدها.

(٢) لسان العرب: ج ٤، ص ٢٨٤٣-٢٨٤٤.

الثاني: الخارج من الأرض من الجواهر ذاتها، مثل: الذهب والنفط، ومن أصحاب هذا الاتجاه الكاساني من الأحناف وابن جزري من المالكية، وابن قدامة من الحنابلة، فيقول الكاساني: "إنه المال الذي خلقه الله تعالى في الأرض يوم خلقها".

وهذا الاتجاه الثاني هو الراجح، ذلك أن المتبادر إلى الذهن عند سماع لفظ المعدن ينصرف إلى المستخرج من الأرض، ولا ينصرف إلى مكانه.

حكم إقطاع المعادن .

فرق الفقهاء بين نوعين من المعادن هما: المعادن الظاهرة، والمعادن الباطنة، ثم تحدثوا عن الحكم الشرعي لإقطاع كل نوع منها. وعلى ذلك يجب بيان المقصود بالمعدن الظاهر، والمعدن الباطن، ثم بيان حكم إقطاعهما، مع ملاحظة أن المقصود بكون المعدن ظاهراً أو باطناً عند غالب الفقهاء ليس قربه من ظاهر الأرض أو كونها في أعماقها، وما يترتب على ذلك من احتياجه إلى حفر، ومؤنة في الوصول إليه، وإنما المراد من ظهور المعدن أو بطونه عند غالب الفقهاء الحالة التي يخرج عليها، وما إذا كانت خواص المعدن بارزة فيها، دون الحاجة إلى جهد لتحويله، وتطوير المادة المستخرجة لتصل إلى المعدن المراد.

أولاً : إقطاع المعدن الظاهر .

المعدن الظاهر هو: الذي لا يحتاج إلى عمل وتطوير لكي يبدو على حقيقته ويتجلى جوهره مثل الملح والنفط، فهذه المعادن عند استخراجها تكون محتفظة بخواصها. فيقول عنها الإمام النووي: "المعدن الظاهر هو: ما خرج بلا علاج

كنفط وقار " ويعرفها الماوردي: بأنها "كل ما كان ظاهرًا في معدنه يؤخذ عفواً على أكمل أحواله، كالملح والنفط والقار...." (١).

وذهب الشافعية إلى أنه لا يجوز إقطاع المعادن الظاهرة، لا تملكاً ولا انتفاعاً فيقول الماوردي: "فأما المعادن الظاهرة كالماء العد لا يجوز إقطاعه، والناس فيه سواء يأخذه من ورد إليه" (٢).

وقال الإمام الشافعي في الأم: "وأصل المعادن صنفان، ما كان ظاهرًا كالملح الذي يكون في الجبال ينتابه الناس فهذا لا يصلح لأحد أن يقطعه أحدًا بحال، والناس فيه شرع" (٣). وقد استدل أنصار هذا الرأي بما يلي:

١- ما رواه ثابت بن سعيد عن أبيه عن جده، أن الأبيض بن جمال استقطع رسول الله - ﷺ - ملح مأرب فأقطعه، فقال الأقرع بن حابس التميمي: يا رسول الله إني وردت هذا الملح في الجاهلية، وهو بأرض ليس فيها غيره، ومن ورده أخذه، وهو مثل الماء العد بالأرض، فاستقال الأبيض في قطيعة الملح، فقال: قد أقلتك على أن تجعله مني صدقه، فقال النبي - ﷺ -: هو منك صدقة، وهو مثل الماء العد من ورده أخذه" (٤) فقد استرجع النبي - ﷺ - الملح من الرجل؛ لأنه معدن ظاهر لا يحتاج إلى جهد ومؤنة.

(١) شرح منهاج الطالبين: ج٣، ص ٩٤، ٩٥.

(٢) الأحكام السلطانية: ص ٢٤٧.

(٣) الأم: ج٣، ص ٢٦٥، ٢٦٦.

(٤) أبو داود: رقم ٣٠٦٤.

٢- أن المعدن الظاهر الناس فيه شرع لا يملكه أحد قياساً على الماء والنبات، فالمسلمون شركاء في ذلك؛ لقوله في "الناس شركاء في ثلاثة: الماء والكلأ والنار" كما أن في إقطاعه تضيقاً على المسلمين وهذا يضر بهم^(١).

ثانياً : إقطاع المعدن الباطن .

المعدن الباطن هو: الذي يحتاج علاج وتطوير كالذهب والحديد.... الخ، وقد عبر عنها الماوردي بقوله: "وأما المعادن الباطنة، فهي ما كان جوهرها مستكناً فيها لا يوصل إليه إلا بالعمل كمعادن الذهب والفضة..."^(٢)، وفي حكم إقطاعه ثلاثة اتجاهات:

الأول: ذهب بعض الشافعية إلى أنه لا يجوز إقطاع المعادن الباطنة، وذلك بالقياس على المعادن الظاهرة، فالناس كلهم فيها شرع^(٣).

الثاني: ذهب الشافعية في قول إلى أنه يجوز للإمام أن يقطع المعادن الباطنة تملياً وانتفاعاً، وقد قال بذلك صاحب مغني المحتاج من الشافعية. واستدلوا على ذلك بما روي أن رسول الله -ﷺ- أقطع بلال بن الحارث المزني معادن القبلية، وقد كانت باطنة، ومن ثم يجوز إقطاع المعادن الباطنة.

الثالث: ذهب بعض الشافعية إلى أنه يجوز للإمام إقطاع المعادن الباطنة إقطاع انتفاع، دون إقطاع التمليك. وقد استدلت المالكية على ذلك بأن المعادن التي هي في جوف الأرض أقدم من ملك المالكية لها، فلم يجعل ذلك ملكها لهم بملك

(١) الأم: ج٣، ص٢٦٥، ٢٦٦، المغني لأبن قدامه: ج٥، ص٢٩٨ طبعة النور.

(٢) الأحكام السلطانية: ص٢٤٨.

(٣) المذهب للشيرازي، الأحكام السلطانية: ص٢٤٨.

الأرض إذ هو ظاهر قوله تعالى: ﴿إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ﴾^(١)، ولم يقل الأرض لله يورثها وما فيها من يشاء من عباده، فوجب بنحو هذا الظاهر أن يكون ما في جوف الأرض من المعادن فيئاً لجميع المسلمين، كما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب.

ومن ثم يجب على الإمام أن يعمل فيه بنفسه، أو يقطعه أفراد الناس لاستغلاله وفق ما اشترط عليهم لفترة محدودة وبمقابل يتفق عليه، فالأمر هنا إقطاع انتفاع، لا تملك، ومن ثم لا يورثه لمن بعده^(٢).

القسم الثاني

إقطاع الاستغلال

الاستغلال في اللغة هو: أخذ الغلة ، وجمعها غلات^(٣).

ويعرف بأنه: إقطاع منفعة الأرض لمن يستغلها، إن شاء أن يزرعها، وإن شاء أن يؤجرها، وإن شاء أن يزارع عليها^(٤).

حكم إقطاع الاستغلال .

وأما حكمه فهو الجواز، فقد فعله صحابة الرسول - ﷺ -، فقد أقطع عمر رضي الله عنه - بعض أزواج الرسول - ﷺ -، وفق ما يروي البخاري بسنده عن نافع، أن

(١) سورة الأعراف: آية ١٢٨.

(٢) حاشية الدسوقي: ج١، ص٤٨٧، د. محمد عامر، البديل الشرعي لمصادر التمويل الدولي المعاصرة في العالم الإسلامي: ص٣٥١، د. عبد الوهاب حواس، مرجع سابق، ص٩١.

(٣) القاموس الفقهي لغة واصطلاحاً: ص٢٧٦.

(٤) الفتاوى لابن تيمية: ج٣٠، ص١٣٨.

عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أخبره: «أَنَّ النَّبِيَّ -ﷺ- عَامِلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ تَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ، فَكَانَ يُعْطِي أَزْوَاجَهُ مِائَةَ وَسْقٍ، تَمَانُونَ وَسْقٍ تَمَرٍ، وَعِشْرُونَ وَسْقٍ شَعِيرٍ»، فَقَسَمَ عُمَرُ خَيْبَرَ «فَخَيْرَ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ -ﷺ-»، أَنْ يُقْطَعَ لَهُنَّ مِنَ الْمَاءِ وَالْأَرْضِ، أَوْ يُمَضِّيَ لَهُنَّ»، فَمِنْهُنَّ مَنْ اخْتَارَ الْأَرْضَ، وَمِنْهُنَّ مَنْ اخْتَارَ الْوَسْقَ، وَكَانَتْ عَائِشَةُ اخْتَارَتْ الْأَرْضَ^(١).

أنواع إقطاع الاستغلال .

وقسم الماوردي إقطاع الاستغلال إلى نوعين:

الأول: إقطاع العشر وهو غير جائز؛ لأنه زكاة لأصناف حددها القرآن في آية المصارف، واشترط الشارع أوصافاً محددة في هذه الأصناف الثمانية عند دفع الزكاة إليهم، وقد يتخلف هذا الوصف عند دفع العشر، ومن ثم لا يجوز إقطاع العشر.

الثاني: إقطاع الخراج والخراج هو: "ما وضع على رقاب الأرض من حقوق تؤدي عنها" وقد يكون الخراج أجرة، فهو مستقر على التأييد، ومن ثم يجوز إقطاعه أكثر من سنة. وهذا النوع من الإقطاع يكون كأجرة في مقابل خدمة يؤديها الأشخاص كالقضاة والجنود، ولا مانع فيه شرعاً عند الشافعية، كما نقل صاحب مغني المحتاج عن الإمام الأذرعي: "ولا أحسب في جواز الإقطاع للاستغلال خلافاً إذا وقع في محله لمن هو من أهل النجدة قدرًا يليق بالحال من غير مجازفة"^(٢).

(١) رواه البخاري، وأبو يوسف في الخراج.

(٢) مغني المحتاج: ج ٢، ص ٣٦٨.

شروط صحة إقطاع الاستغلال .

وقد اشترط الشافعية لجواز هذا الإقطاع ما يلي:

١- أن يكون لمن له أجر مقدر في بيت المال مقابل عمل دائم كالجنود والقضاة.

٢- أن يكون رزق المقطع معلومًا عند باذل الإقطاع.

٣- أن يكون قدر الخراج معلومًا.

٤- أن يكون لمدة معينة ومحددة.

٥- مراعاة حال المقطع في مدة الإقطاع.

٦- ألا يكون الإقطاع وراثيًا^(١).

ويلاحظ أنه يجوز للحاكم استرجاع ما أقطعه إلى المقطع، وذلك بعد السنة التي هو فيها، ويعود رزقه إلى ديوان العطايا.

القسم الثالث

إقطاع الإرفاق

والإرفاق لغة: مأخوذة من رفق، يقال أرفقته أي نفقته^(٢).

(١) الماوردي: ص ٣٥٤، وبعدها، د. عبد الوهاب حواس: ص ١٠١، وبعدها.

(٢) شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم: ج ٤، ص ٢٥٨٣.

وعرفه **الماوردي** بأنه: "ارتفاق الناس بمقاعد الأسواق، وأفنية الشوارع، وحريم الأمصار، ومنازل الأسفار" (١).

حكم إقطاع المرافق .

أجاز الفقهاء للإمام أن يقطع المرافق العامة لمن يرتفق بها إذا رأى في ذلك مصلحة، وبشرط ألا يترتب على ذلك ضرر بأحد الناس. كما قال الفقهاء بأن هذا الإقطاع لا يفيد تملكاً، وإنما يعطي المقطع أولوية، وتقدماً على غيره في الانتفاع بالمرفق (٢).

يقول أبو يوسف في الخراج: "ولا ينبغي لأحد أن يحدث شيئاً في طريق المسلمين مما يضرهم، ولا يجوز للإمام أن يقطع شيئاً من طريق المسلمين مما فيه الضرر عليهم، ولا يسعه ذلك" (٣).

ومن أمثلة إقطاع المرافق ما يختص بأفنية الشوارع والطرق، وهذا موقوف على نظر السلطان في الصحيح من مذهب الشافعية. ومما يروى في هذا الصدد أن علياً بن أبي طالب -كرم الله وجهه- خرج إلى السوق فرأى أهله قد حازوا أمكنتهم، فقال: ليس لهم ذلك إن سوق المسلمين كمصلاهم، من سبق إلى موضع فهو له يومه حتى يدعه (٤).

(١) الأحكام السلطانية: ص ٢٣٥.

(٢) مغني المحتاج: ج ٢، ص ٣٦٩.

(٣) الخراج: ص ١٠١.

(٤) فتوح البلدان: ص ٣٦٦.

الفصل السادس

الهبة^(١)

تعريف الهبة

الهبة لغة: التفضل على الغير بما ينفعه ولو غير مال، كقوله تعالى يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاءً وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ، كما تعم تملك الأعيان والمنافع.

والهبة: مأخوذة من هَبَّ بمعنى مرَّ؛ لمرورها من يد إلى أخرى، أو بمعنى استيقظ؛ لأن فاعلها استيقظ للإحسان بعد أن كان غافلاً عنه^(٢). وأصل الهبة من الوهب بتسكين الهاء وتحريكها، وهذا شأن كل معتل الفاء، كالوعظ والعظة، فهو من المصادر التي يحذف أولها ويعوض عن آخرها بالتاء.

وشرعاً: تملك العين من غير عوض، أو كما قال الشافعية هي: تملك منجز مطلق في عين حال الحياة بلا عوض ولو من الأعلى. أو نقول: هي تملك تطوع في الحياة. وهذا أولى وأخصر.

شرح التعريف: خرج "بالتملك" العارية والوقف والضيافة؛ لأن الملك يترتب عليها بالوضع في الفم، ومن ثم يختلف كل ذلك عن الهبة.

^(١) كُتِبَ: أ. د/ محمد عامر.

^(٢) حاشية الشرقاوي، ج ٢، ص ١١٥.

وخرج "بالتطوع" غيره، كالبيع والزكاة والنذر والكفارة والواجب من الأضحية والهدى والعقيقة، بخلاف المندوب منها فهو من الهدية؛ لوجود التملك فيه، وإن امتنع التصرف فيه بنحو بيع.

وخرج بقوله: "في حياة" الوصية؛ لأن التملك فيها إنما يتم بالقبول، وهو بعد الموت^(١).

حكم الهبة ودليل مشروعيتها

وهي مشروعة ومندوبة بالكتاب والسنة والإجماع:

أ- أدلة الكتاب:

١- قوله تعالى: [فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا]^(٢)، وقوله تعالى: [وَأَتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ]^(٣)، فالآيتان محتملتان للهبة والصدقة والهدية.

٢- قوله تعالى: [وتعاونوا على البر والتقوى]^(٤)، والهبة نوع من أنواع البر.

ب- أدلة السنة:

١- ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: «لو دعيت إلى زراع، أو كراع لأجبت، ولو أهدي إلي ذراع، أو كراع لقبلت»^(١). وروي أنه قال:

(١) حاشية قليوبي على شرح منهاج الطالبين، ج ٣، ص ١١٠؛ حاشية الشرقاوي، ج ٢، ص ١١٥.

(٢) سورة النساء: الآية ٤.

(٣) سورة البقرة: الآية ١٧٧.

(٤) سورة المائدة: الآية ٢.

«إننا نقبل الهدية ونكافئ عليها». وقد أخرج البخاري هذا الحديث بلفظ: "كان رسول الله ρ يقبل الهدية وينيب عليها"^(٢).

٢- قوله تهادوا تحابوا، وعن عائشة قالت: قلت يا رسول الله ρ : إن لي جارتين فإلى أيهما أهدي؟ قال: «إلى أقربهما منك باباً»^(٣). ومع كون الهبة مندوب إليها في عمومها إلا أنها للأقارب أفضل، لما روى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: «الراحمون يَرْحَمُهُمُ اللهُ، ارْحَمُوا مَنْ فِي الْأَرْضِ يَرْحَمَكُمُ مَنْ فِي السَّمَاءِ، الرَّحْمُ مُشْتَقَّةٌ مِنَ الرَّحْمَنِ، مَنْ وَصَلَهَا وَصَلَهُ اللهُ، وَمَنْ قَطَعَهَا قَطَعَهُ اللهُ»^(٤). وفي الهبة صلة الرحم^(٥).

ج- الإجماع:

فقد انعقد الإجماع على استحباب الهبة بكل أنواعها؛ لما فيها من المحبة وتأليف القلوب، ولم يعلم مخالف للفقهاء في ذلك فكان إجماعاً. كما أنه من المعلوم أن القلوب مجبولة على حب من أهدى إليها، وإشاعة المحبة هذه غاية من غايات الإسلام.

وثمة ملاحظة: وهي أنه إذا كان أصل الهبة النذب إلا أنه قد يعرض لها من الأسباب ما يخرجها عن النذب إلى غيره، فتحرم في حالات، منها:

(١) صحيح البخاري، كتاب الهبة، رقم ٢٥٦٨.

(٢) صحيح البخاري، كتاب الهبة-باب المكافأة في الهبة، رقم ٢٥٨٥.

(٣) السنن الصغرى ج ٢، ص ٣٣٧ رقم ٢٢٣٠.

(٤) رياض الصالحين.

(٥) المذهب مع شارحه المجموع، ج ١٥، ص ٣٦٧.

١- الهبة لأرباب الولايات والعمال، فإنه يحرم عليهم قبول الهدية من أهل ولايتهم ممن ليست له عادة بذلك قبل الولاية، يدل على ذلك ما رواه أبو حميد الساعدي قال: «استعمل النبي P رجلاً من بني أسد على الصدقة، فلما قدم قال: هذا لكم وهذا أهدي لي، فقام النبي P على المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: "ما بال العامل نبعثه فيأتي يقول: هذا لك وهذا لي، فهلا جلس في بيت أبيه وأمه، فينظر أيهدى له أم لا، والذي نفسي بيده، لا يأتي بشيء إلا جاء به يوم القيامة يحمله على رقبتة، إن كان بعيراً له رغاء، أو بقرة لها خوار، أو شاة تيعر «، ثم رفع يديه حتى رأينا عفرتي إبطيه» ألا هل بلغت " ثلاثاً»^(١).

٢- لو كان المتهم يستعين بذلك على معصية^(٢)، وذلك لأن المعصية حرام، وكل ما كان وسيلة إلى الحرام، فهو حرام.

أركان الهبة

إذا تقرر إباحة الهبة-كما أسلفنا- فإنها تتحقق بأربعة أشياء: بموهوب، وواهب، وموهوب له، وعقد، على النحو التالي:

الركن الأول: الواهب.

ويشترط فيه أن يكون مالاً جائز التصرف له أهلية التبرع، فإن كان الواهب غير مالك مثل الغاصب لم تجز هبته للشيء المغصوب؛ لأن شرط الواهب قدرته على التصرف بجوازه شرعاً، والغاصب ظالم يمنع الشرع من القدرة على التصرف.

(١) صحيح البخاري-باب من استرعي رعية فلم ينصح ج ١ ص ٢٢.

(٢) مغني المحتاج، ج ٢، ص ٣٩٦.

وكذلك الأمر لو كان الواهب مالكا، بيد أنه غير جائز التصرف كالسفيه، فلا تجوز منه الهبة؛ لأن الهبة من العقود الضارة ضرراً محضاً؛ إذ هي دون عوض أو مقابل، ولذا قيل عنها أنها من عقود التبرعات، فلا يملكها السفيه لما يترتب على تصرفه هذا من ضرر به وبغيره.

وبناء على ما سبق، فقد اتفق الفقهاء على أنه لا يجوز للولي أن يهب مال الصغير دون أن يشترط العوض اللازم؛ لأن التبرع بمال الصغير دون عوض يعتبر من قبيل قربان ماله بوجه غير حسن، وهذا منهي عنه في قوله تعالى: [وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ]^(١).

الركن الثاني: الموهوب له.

يشترط فيه أن يكون أهلاً للملك، فمن صح أن يحكم له بالملك، صح أن يكون موهوباً له من صغير وكبير، ومجنون ورشيد، وبالتالي فإن من لا يحكم له بالملك كالحمل والبهيمة، لا يصح أن يكون موهوباً له إذ إنه لا يتمتع بالأهلية، يستوي في ذلك أن تكون أهلية أداء أو وجوب، وإن ثبتت بعض الحقوق للحمل كالميراث فهذا على سبيل الاستثناء.

الركن الثالث: الشيء الموهوب.

وضابطه: "أن كل شيء صح بيعه جازت هبته". وعلى ذلك فإن ما لا يجوز بيعه كالمجهول، وما لا يقدر على تسليمه، وما لم يتم ملكه عليه كالمبيع قبل القبض لا تجوز هبته؛ لأنه عقد يقصد به تملك المال في حال الحياة، فلم

(١) سورة الأنعام، الآية ١٥٢.

يجز فيما ذكرناه كالبيع^(١). وعلى ذلك اشترط الشافعية في الشيء الموهوب ما يلي:

١- أن يكون مملوكًا، فإن كان غير مملوك كالشيء الموقوف أو المباع، لم يجز أن يكون محلاً لعقد الهبة، لانتهاء الملكية لدى الواهب.

٢- أن يكون معلومًا، فإن كان مجهولاً لم يجز.

٣- أن يكون حاضرًا، فإن كان غائبًا لم يجز^(٢).

٤- أن يكون مالا متقومًا، فلا يجوز هبة غير الأموال المتقومة، كالخمر والميتة والخنزير؛ لأن هذه الأشياء لا تعد مالا في نظر الشرع.

الركن الرابع: الصيغة.

فعقد الهبة بذل من الواهب وقبول من الموهوب له أو من يقوم مقامه كالوكيل والولي، وصورة العقد أن يقول الواهب: قد وهبتك، فيقول الموهوب له على الفور: قد قبلت. فإن لم يقبل لا يتم العقد؛ لأن الشافعية يعتبرون القبول في عقد الهبة، وإن كانوا يستثنون من اشتراط القبول بعض المسائل أوردها صاحب مغني المحتاج، ومن أهمها:

١- هبة المرأة نوبتها لضررتها، فلا يشترط قبول الضررة لتلك النوبة على

الصحيح.

(١) المذهب مع شارحه المجموع، ج ١٥، ص ٣٧٣.

(٢) الحاوي، ج ٩، ص ٣٩٩.

٢- إذا خلع السلطان شيئاً على الأمراء والقضاة وغيرهم فلا يشترط فيه القبول كما بحثه بعض المتأخرين لجريان العادة بذلك.

٣- وإذا اشترى الوالد لابنه الصغير وزينه به، فإنه يكون تمليكا له بخلاف ما لو اشترى حلياً لزوجته، فإنه لا يصير ملكاً لها كما قاله القفال، والفرق بينهما أن له ولاية على الصغير بخلاف الزوجة وبهذا قال السبكي وتبعه ابن الملقن، ويرد هذا قول الشيخين وغيرهما، فإن وهب للصغير ونحوه ولي غير الأب والجد قبل له الحاكم، وإن كان أباً أو جداً تولى طرفي العقد، وهذا معناه أنه لا بد من الإيجاب والقبول.

ويتفرع على هذا أنه إذا وهب للصغير ونحوه ممن ليس أهلاً للقبول، فإن على الولي أن يقبل عنه الهبة، فإن لم يقبل انعزل الوصي أو القيم وأثم لتركه الأحظ، فإن كان أباً أو جداً فلا ينعزل لكمال شفقتهم، وإن كان سفيهاً فيقبلها لنفسه؛ لأن السفيه صحيح العقل. أما الأخرس فيكفيه الإشارة المفهمة^(١).

ويستدل الشافعية على اعتبار القبول في عقد الهبة بما يروى "أن النبي ρ أهدى إلى النجاشي مسكاً، فمات النجاشي قبل وصول المسك إليه، فعاد المسك إلى النبي ρ فقسمه بين نسائه". ووجه الدلالة من هذا الحديث: أن المسك لو صار ملكاً للنجاشي دون توقف ذلك على القبول منه، لما استحل النبي ρ أن يأخذه عند عودته، ولأوصله إلى ورثة النجاشي.

(١) مغني المحتاج، ج ٢، ص ٣٩٧، د. عبد العزيز عزام، نظام المعاملات في الفقه الإسلامي، دار البيان للنشر والتوزيع، سنة ١٩٩٩، ص ٣٧٧، ٣٧٨.

أهم المسائل المتعلقة بالهبة

المسألة الأولى: هبة المشاع

لا فرق عند جمهور الفقهاء، ومنهم الشافعية من أن يكون الشيء الموهوب محوزاً أو مشاعاً، يستوي أن يكون هذه المشاع مما يقسم أو لا يقسم، ويستدلون على ما ذهبوا إليه بالكتاب والسنة كما يلي:

أما الكتاب: فبعموم قوله تعالى: [فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا] ^(١)، كما يستدلون بقوله تعالى: [وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ] ^(٢). فالمعلوم وجوب نصف المفروض من المهر للزوجة في حالة الطلاق قبل الدخول إلا أن يوجد حظ من الزوجة عن النصف، ولآية أشارت إلى ذلك دون فصل بين العين والدين والمشاع والمقسوم.

وأما السنة: فما رواه الإمام البخاري ومسلم من حديث قتادة قال: قال: كنت يوماً جالساً مع رجال من أصحاب النبي ﷺ في منزل، في طريق مكة،

(١) سورة النساء: الآية ٤.

(٢) سورة البقرة: الآية ٢٣٧.

ورسول الل هـم نازل أماننا والقوم محرمون، وأنا غير محرم عام الحديبية، فأبصروا حمارًا وحشيًا، وأنا مشغول أخصف^(١) نعلي، فلم يؤذنونني، وأحبوا لو أنني أبصرته، فالتفت، فأبصرته فقامت إلى الفرس، فأسرجته، ثم ركبت، ونسيت السوط والرمح، فقلت لهم: ناولوني السوط والرمح، فقالوا: لا والله، لا نعينك عليه بشيء، فغضبت، فنزلت، فأخذتهما، ثم ركبت فشددت على الحمار فعقرته، ثم جئت به وقد مات، فوقعوا فيه يأكلونه، ثم إنهم شكوا في أكلهم إياه وهم حرم، فرحنا وخبأت العضد معي، فأدركنا رسول الله هـم، فسألناه عن ذلك، فقال: «معكم منه شيء؟»، فقلت: نعم، فناولته العضد، فأكلها حتى نفدها وهو محرم^(٢).

وفي رواية لمسلم: أنه هـم قال لهم: هل أشار إليه إنسان أو أمره بشيء؟ فقالوا: لا. قال فكلوا.

وهذا الخبر صريح في صحة هبة المشاع، وبه قال مالك والشافعي وأحمد، سواء في ذلك ما أمكن قسمته أو لم يمكن؛ لأن الصحابي أهدى صيده مشاعًا بين من أكلوه^(٣).

المسألة الثانية: القبض في الهبة

مذهب الشافعية ومن وافقهم: أن القبض من تمام الهبة، لا تملك إلا به، وهذا قول أهل العراق من الشافعية، ويستدلون على ذلك بما يلي:

١- ما رواه الحاكم وخرجه صاحب التلخيص الحبير من أن النبي أهدى إلى لنجاشي ثلاثين أوقية مسكًا، وقال لأم سلمة رضي الله عنها: إن النجاشي قد

(١) اخصاف النعل بمعنى اصلاحه.

(٢) صحيح البخاري، كتاب الهبة، رقم ٢٥٧٠.

(٣) تراجع هذه المسألة في الحاوي، ج ٩، ص ٤٠٠، وكذلك المذهب للشيرازي.

مات، وسيرد علي فأعطيك، فلما رد عليه أعطى كل واحدة من نساءه أوقية، ودفع باقية إلى أم سلمة. ووجه الدلالة من الحديث على أن القبض من تمام الهبة واضح، حيث تصرف الرسول في المال، لأن الموهوب له لم يملكه لعدم القبض.

٢- ما رواه مالك في الموطأ بسنده عن عائشة، أن أباها نحلها جذاذ عشرين وسقاً من ماله، فلما حضرته الوفاة جلس فتشهد وحمد الله تعالى وأثنى عليه وقال: أما بعد يا بنية فإن أحب الناس إلي غني بعدي لأنت، وإن أعز الناس علي فقراً بعدي أنت، وإني كنت نحلتك جذاذ عشرين وسقاً من مالي ووددت أنك كنت حزتيه، وإنما هو اليوم مال الوارث". فدل ذلك على أن الهبة لا تتم ولا تملك إلا بالقبض.

وذهب الإمام مالك وداود الظاهري، ومن وافقهم: إلى أن الهبة تتم بالعقد دون توقف على القبض، وأن من حق الموهوب له أن يأخذ الشيء الموهوب بالعقد، وقد استدلوا على ما ذهبوا إليه بقوله تعالى: [يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ]^(١). وقوله: "العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه"، ولفظ البخاري^(٢): "العائد في هبته كالعائد في قيئه".

وقد أجاب الشافعية على هذه الأدلة: بأن الوفاء بالعقود يراد به العقود اللازمة، والهبة لا تلزم إلا بالقبض، أما قبل القبض فهي من العقود الجائزة التي يجوز الرجوع فيها بالفسخ، كما أن الحديث الوارد عن الرسول محمول على ما بعد القبض^(٣).

(١) سورة المائدة، الآية ١.

(٢) صحيح البخاري، كتاب الهبة، رقم ٢٦٢١.

(٣) الحاوي، ج ٩، ص ٤٠٢، ٤٠١.

المسألة الثالثة : هبة الثواب

إن هبة الثواب تعد أحد نوعي هبة الأعيان، فالهبة إما هبة عين، وإما هبة دين، وإما هبة منافع، وهبة العين إما مقيدة بنفي الثواب، وإما مقيدة بالثواب، وإما مطلقة، والثواب هو العوض، وأصله من ثاب إذا رجع، فكأن المتيب يرد إلى المثاب مثل ما دفع. فالثواب هو المجازاة، وكان الرسول μ يقبل الهدية ويثيب عليها؛ أي يعطي المهدي بدلها. فهبة الثواب هي الهبة على أن يكافئه الموهوب له، وقد ترجم البخاري لها بقوله: "باب المكافأة في الهبة". والمكافأة مفاعلة بمعنى المقابلة. والمكافأة هي: إعطاء العوض في الهبة، وكل شيء ساوئ شيئاً حتى يكون مثله فهو مكافئ له.

وقد أجاز الفقهاء الهبة المطلقة عن نفي الثواب وإثباته، وأما الهبة المقيدة بالثواب؛ أي التي اشترط لها الثواب، فقد اختلف فيها الفقهاء.

وسبب الخلاف: اختلفهم في: هل هبة الثواب بيع مجهول الثمن؟ أو ليس بيعاً مجهول الثمن؟ فمن رآه بيعاً مجهول الثمن قال: هو من بيوع الغرر التي لا تجوز، ومن لم ير أنها بيع مجهول قال: يجوز، وكأن مالكاً جعل العرف فيها بمنزلة الشرط، وهو ثواب مثلها. وعلى ذلك يمكن القول أن الفقهاء قد انقسموا في حكم الهبة المشترط فيها الثواب والنفع إلى فريقين:

الفريق الأول: يذهب جمهور من فقهاء السلف، كابن عباس، وقتادة، وطاووس والحسن وعكرمة ومجاهد والنخعي والسدي وسعيد بن جبير وأبي ثور وداود الظاهري، إلى القول ببطلان الهبة المقترنة بشرط الثواب، وإن البطلان قول عند الحنفية فيما لو كان الثواب مجهولاً، وإن كان الحنفية وابن عابدين قالوا: إن

الذي يبطل هو الشرط، أما الهبة فلا تبطل، والأظهر عند الشافعية بطلان العقد في الثواب المجهول، وهو قول عندهم وعند الحنابلة في الثواب المعلوم

الفريق الثاني: ذهب المالكية والإباضية إلى القول بصحة العقد وشرط الثواب في الثواب المعلوم والمجهول، ووافقهم الحنفية والشافعية والحنابلة في الثواب المعلوم، أما المجهول فهو قول عند الحنفية والشافعية، وهو ظاهر كلام أحمد في رواية محمد بن الحكم^(١).

أدلة الفريق الأول:

١- إن عقد الهبة لا يقتضي العوض نظرًا إلى دلالة اللفظ، بل إن دلالة اللفظ التبرع، الذي ينافيه اشتراط الثواب والعوض، فيبطل الشرط. كما أن الهبة المقترنة بشرط الثواب المجهول يتعذر اعتبار العقد فيها بيعًا لجهالة العوض، كما يتعذر تصحيح العقد هبة لذكر الثواب الذي ينافي مقتضاها؛ إذ هي تبرع، فالثواب هنا عوض مجهول في معاوضة، فلم تصلح قياسًا على البيع؛ لأن العوض يلحقها بالبيع، وهو لا يصح فيه مجهولًا فكذلك الهبة^(٢).

٢- احتج ابن حزم على بطلان الهبة المقترنة بشرط أصلاً، بقوله p: "كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل"، ولا تجوز هبة يشترط فيها الثواب أصلاً وهي فاسدة مردودة؛ لأن هذا الشرط ليس في كتاب الله عز وجل فهو باطل، بل في

(١) تكملة ابن عابدين ج ٨ ص ٤٧٢، ٤٧٣؛ بدائع الصنائع ج ٦ ص ١١٨، الفتاوى الهندية ج ٤ ص ٣٩٣، الحاوي ج ٩ ص ٤١٩، تكملة المجموع ج ١٥ ص ٣٨٦.

(٢) الحاوي ج ٩ ص ٤١٩، مغني المحتاج ج ٢ ص ٤٠٤، ٤٠٥، نهاية المحتاج ج ٥، ص ٤٢٠، ٤٢١؛ تكملة المجموع ج ١٥ ص ٣٨٧ وما بعدها.

القرآن المنع منه بعينه، قال الله عز وجل: [ولا تمنن تستكثر]^(١)، وهو قول جمهور من السلف، فقد روينا عن قتادة عن ابن عباس في قوله تعالى: [وما آتيتكم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله]، قال: هو هدية الرجل أو هبة الرجل يريد أن يثاب أفضل منه، فذلك الذي لا يربو عند الله ولا يؤجر عليه صاحبه، ولا إثم عليه، قال علي: هذا إذا أراد بقلبه، وأما إذا اشترطه فعين الباطل والإثم....

وعن قتادة في قوله تعالى: [ولا تمنن تستكثر]. قال: لا تعط شيئاً لتثاب أفضل منه، وهو قول طاووس أيضاً، والحسن، وعكرمة، ومجاهد، وإبراهيم النخعي، وعن سعيد ابن جبير في معنى الآية قال: يعطي العطية ليثيبه عليها، وعن السدي عن أبي مالك قال: لا تعط الأغنياء لتصيب أفضل منه^(٢).

ونوقش هذا الدليل: بأن الآثار الواردة عن ذكرهم ابن حزم في معنى الآية الكريمة، قد خالفهم غيرهم من السلف، منهم: عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وأبو الدرداء، وفضالة بن عبيد، وعمر بن عبد العزيز، وعطاء، وشريح، ويحيى بن سعيد الأنصاري، كما أن غاية ما يدل عليه ظاهر الآيات والآثار هو الإعطاء رجاء عوض أكثر، وليس المراد المنع المطلق من الثواب، بل أكثر من ذلك ذهب بعض الفقهاء إلى منع الهبة أو الهدية المقترنة بشرط الحصول على ثواب أكثر في حق النبي ﷺ خاصة، لقوله تعالى: [ولا تمنن تستكثر. ولربك فاصبر]. فهو ﷺ مأمور بأشرف الأخلاق وأجلها^(٣).

(١) سورة المدثر: الآية ٦.

(٢) المحلى ج ٩ ص ١١٨ دار التراث؛ القرطبي ج ١٠ ص ٦٨٥٩.

(٣) المغني ج ٦ ص ٢٩٩، كشف القناع، دار الفكر سنة ١٩٨٢ ج ٤ ص ٢٩٩؛ مفاتيح الغيب

وبجانب ما سبق، فإن الاستدلال بحديث: "كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل"، مردود؛ لأن عمومات الكتاب والسنة على وجوب الوفاء بالعقود والشروط ما لم يرد نهي خاص عن شرط بعينه، ولأن ابن حزم يتفق مع الجمهور على صحة الشرط الذي دلت على جوازه السنة أو الإجماع.

أدلة الفريق الثاني:

١- قال الكاساني^(١): روي عن رسول الله أنه قال: "الواهب أحق بهبته ما لم يثب منها"^(٢). أي ما لم يعوض، فالحديث ظاهر في جواز الهبة المشروطة بعوض، وهو في ذات الوقت مانع من الرجوع فيها إذا قبض. كما أن صحة الهبة بشرط الثواب هو قول عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وأبي الدرداء، وعمر بن عبد العزيز، وشريح، وربيعه، والقاسم بن محمد.

ونوقش هذا الدليل: بأن روايات رفع هذا الحديث إلى الرسول كلها ضعيفة، والصحيح أنه من قول عمر بن الخطاب، القائل: "من وهب هبة أراد بها الثواب فهو على هبته يرجع فيها إذا لم يرض منها"، قاله ابن قدامة وابن حزم. أما قول الصحابة والتابعين بصحة الهبة المقترنة بشرط، فقد خالفهم غيرهم، وليس قول أحدهم أولى من الآخر^(٣).

(١) بدائع الصنائع، ج ٦ ص ١٢٩، ١٣٠.

(٢) السنن الصغرى ج ٢ ص ٣٤٤؛ سبل السلام ج ٣ ص ٩٤٥؛ نصب الراية للزيلعي، دار الحديث ج ٤ ص ١٢٥، وذكره من حديث أبي هريرة، وابن عباس، وابن عمر.

(٣) المغني ج ٦ ص ٣٠٠، ٣٠١؛ المحلى ج ٩ ص ١١٩، دار التراث.

٢- عن عبد الرحمن بن علقمة قال: قال رسول الله ﷺ: "إن الصدقة يبتغى بها وجه الله عز وجل، وإن الهدية يبتغى بها وجه رسول الله ﷺ، وقضاء الحاجة". قالوا: فعلى هذا له ما ابتغى، إذ لكل امرئ ما نوى^(١).

ونوقش هذا الدليل: من قبل ابن حزم، بأنه خبر لا خير فيه، حيث في سنده أبو بكر بن عياش، وعبد الملك محمد بن بشير، وكلاهما ضعيف، ولا يعرف لعبد الملك سماع من عبد الرحمن بن علقمة، وفيه أيضًا أبو حذيفة، فإذا كان المقصود به اسحاق بن بشير البخاري فهو هالك، وإن لم يكنه فهو مجهول، فسقط الخبر جملة ولم يحل الاحتجاج به ثم لو صح لم يكن لهم فيه حجة أصلاً؛ لأنه ليس فيه ذكر لهبة الثواب أصلاً.

الراجع :

والراجع هو اعتبار أن هبة الثواب من عقود المعاوضة، ولا يرد على ذلك قول بعض الحنفية بعدم جريان الربا بين العوض والهبة ولو من جنسها ويسيرا، محتجين لذلك بأن هبة الثواب ليست بمعاوضة محضة حتى يتحقق فيها الربا، وإنما العوض يقصد به قطع الرجوع على الواهب، وليس العوض ببديل حقيقة، وذلك لأن هذه الدعوى مقصورة ومقيدة عند الحنفية أنفسهم على العوض المتأخر عن العقد، دون العوض المقارن في العقد، ففي مجمع الأنهر: "العوض المتأخر ليس ببديل حقيقة، بدليل أنه يجوز أن يعوضه أقل من جنسه في المقدرات، ولو كان معاوضة لما جاز للربا، وإنما أعطاه ليسقط حقه في الرجوع"^(٢).

(١) المحلى ج٩ ص١١٩.

(٢) مجمع الأنهر، دار احياء التراث العربي ج ٢ ص ٣٦٣، البدائع ج ٦ ص ١٣١، تكملة ابن عابدين، الحلبي، الطبعة الثانية، ج ٨ ص ٤٧٣.

وفي قول عند الشافعية أنه: "لو وهبه حليًا بشرط الثواب.... فإن أثابه قبل التفرق بجنسه، اعتبرت المماثلة، وإن أثابه بعد التفرق بعرض، صح، وبالنقد لا يصح؛ لأنه صرف، وهذا تفريع على أنه بيع^(١).

ويرى الإمام مالك أنه لا ثواب في هبة الدنانير والدراهم، وإن وهبها فقير لغني، أما عند اشتراط الثواب فأجاز ابن القاسم من المالكية أن يثاب عرضًا أو طعامًا، وأجاز الإمام مالك هبة الحلي المصوغ للثواب، والعوض عليه يعاض عروضًا^(٢)، وعلى ذلك فإن جريان الربا إنما يكون في الثواب المقارن للعقد. أي المشترب فيه وفقًا لما ذهب إليه الأحناف والمالكية والشافعية.

(١) نهاية المحتاج ج ٥ ص ٤٢٣، روضة الطالبين ج ٥ ص ٣٨٦، ٣٨٥، المدونة ج ٤ ص ٣٣٨، دار الفكر.

(٢) منح الجليل ج ٨ ص ٢١٦، ٢١٧.

المسألة الخامسة: تفضيل بعض الأولاد في الهبة

اتفق الفقهاء على أن التسوية بين الأولاد في العطايا أمر مستحب، بيد أنهم اختلفوا في حكم التفضيل بين الأولاد في هذه العطايا على رأيين.

الرأي الأول:

ذهب الشافعية إلى أن التفضيل مكروه وأن التسوية مستحبة، لكن إن حدث تفضيل فإنه ينفذ مع الكراهة، ومحل الكراهة في التفضيل عند الشافعية هو حالة الإستواء في الحاجة أو عدمها، وإلا فإن اختلفوا في الحاجه فلا كراهة في التفضيل^(١).

الرأي الثاني:

ذهب الحنابلة والظاهرية ومن وافقهم إلى أن التفضيل حرام، وأن الواجب هو التسوية في العطايا بين الأولاد.

وسبب الخلاف بين الفقهاء يرجع إلى اختلاف الروايات الواردة في حديث النعمان بن بشير، فقد روي البخاري بسنده عن النعمان بن بشير " أن أباه أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال: إني نحت ابني هذا غلاماً. فقال رسول الله . صلى الله عليه وسلم أكل ولدك نحت مثله ؟ قال النعمان: لا. قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأرجعه^(٢).

(١) مغني المحتاج، ج ٢، ص ٤٠١.

(٢) صحيح البخاري ، باب الهبة للولد، رقم ٢٥٨٦

وفي رواية أخرى للبخاري من حديث عامر قال (سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنه وهو على المنبر يقول: أعطاني أبي عطيه، فقالت عمرة بنت رواحه: لا أرضي حتى تشهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأتي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: أني أعطيت ابني من عمرة بنت رواحه فأمرتني أن أشهدك يا رسول الله، فقال - صلى الله عليه وسلم - أعطيت سائر أولادك مثل هذا ؟ قال: لا فقال صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم" قال فرجع أبي فرد عطيته^(١) . وقد روى مسلم أبو داود من حديث جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " فليس هذا يصلح، وإنني لا أشهد الا على حق" وفي لفظ البيهقي " إن عليك من الحق أن تعدل بين ولدك، كما عليهم من الحق ببيروك".

فإختلاف الروايات ودلاله ألفاظها لدي الفقهاء هو ما أدى بهم إلى الإختلاف^(٢).

أدلة الرأي الأول

استدل أنصار الرأي الأول على ما ذهبوا إليه بالسنة والآثار:

١ - من السنة: ما رواه البخاري بسنده عن النعمان بن بشير " أن أباه الى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إنني نحت ابني هذا غلاماً. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل ولدك نحت مثله ؟، فقال النعمان: لا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرجعه^(٣) وفي لفظ مسلم " فأشهد على هذا غيري" .

(١) صحيح البخاري، باب الإشهاد في الهبة، رقم ٢٥٨٧.

(٢) تراجع هذه المسألة بتفصيل أكثر في " التسوية بين الأبناء في العطية"، د مصباح المتولي، دار الطباعة المحمدية، ط ١ ١٩٩٥.

(٣) صحيح البخاري، باب الهبة للولد، رقم ٢٥٨٦.

ووجه الدلالة: أن قوله صلى الله عليه وسلم " أشهد على هذا غيري " فيه دليل على أن الجواز ؛ لأن ما لا يجوز للرسول صلى الله عليه وسلم أن يشهد عليه لا يجوز لغيره أن يشهد فيه 'فلو لم يصح لبين ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يأمره أن يشهد غيره'(١).

٢ - ومن الآثار: أن أبا بكر الصديق رضى الله عنه فضل عائشة رضى الله عنها على غيرها من أولاده، وفضل عمر رضى الله عنه ابنه عاصم بشيء، وفضل عبد الله بن عمر رضى الله عنهما بعض ولده على بعض(٢)

أدلة الرأي الثاني :

استدل أنصار هذا الرأي على ما ذهبوا إليه بالسنة والمعقول :

١- من السنة: استدلوا بالحديث السابق الإشارة إليه، وهو حديث النعمان بن بشير، وقالوا في وجه الدلالة، أن قوله صلى الله عليه وسلم فأرجعه، وقوله صلى الله عليه وسلم " اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم " يفيد عدم جواز التفضيل، فقد أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بارتجاع العطية ونهي عن التفضيل. فيقول البهوتي من الحنابلة " فأمر بالعدل بينهم، وسمى تخصيص أحدهم دون البقية جوراً، والجور حرام، فدل على أن أمر العدل للوجوب(٣).

(١) المذهب مع شارحه المجموع ج ١٥، ٣١٧.

(٢) مغني المحتاج، ج ٢، ص ٤٠١.

(٣) كشف القناع، دار الفكر، ج ٢، ص ٢٠٩.

٢- من المعقول: أن التفضيل يؤدي إلى إثارة البغضاء والعداوة بين الأبناء، ولا شك أن الإسلام يعارض هذا المسلك الذي يورث به الأبناء للأبناء الضغينة والعداوة بدلاً من المودة والمحبة والرحمة^(١)

جواب الجمهور وتقييمه:

وقد أجاب الجمهور من أصحاب الرأي الأول ومن وافقهم الذين ذهبوا إلى عدم تحريم التفضيل. وأنه فقط مكروه على حديث النعمان بعشرة أجوبه ذكرها ابن حجر في فتح الباري وذكر الردود عليها، ومن أهم هذه الأجوبة وما عليها من ردود ما يلي^(٢):

أولاً: أن الموهوب للنعمان كان جميع مال والده، ولذلك منعه صلى الله عليه وسلم فليس فيه حجه على منع التفضيل، وهذا ما حكاه بن عبد البر عن مالك.

ورد هذا الوجه بتعقب بن عبد البر له: بأن كثير من طرق حديث النعمان صرح فيه بالبعضية. وقال القرطبي: ومن أبعد التأويلات أن النهي إنما يتناول من وهب جميع ماله لبعض ولده كما ذهب إليه سحنون، وكأنه لم يسمع في نفس هذا الحديث أن الموهوب كان غلاماً..... وهذا يعلم منه على القطع أنه كان له مال آخر.

ثانياً: أن العطية المذكورة لم تتجز، وإنما جاء البشير يستبشر النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك فأشار عليه بأن لا يفعل فترك ذلك، وهذا ما حكاه الطحاوي.

(١) فتح الباري، ج٥، ص ٥٣٢.

(٢) فتح الباري، دار الفكر، ج٥، ٥٣١، ٥٣٢.

وقد رد هذا بن حجر بقوله: وفي أكثر طرق حديث الباب ما يناذه.

ثالثاً: أن قوله صلى الله عليه وسلم " ارجعه " دليل على الصحة، ولو لم تصح الهبة لم يصح الرجوع وإنما أمر بالرجوع ؛ لأن للوالد أن يرجع فيما وهبه لولده، وإن كان الأفضل خلاف ذلك، لكن استحباب التسوية رجح على ذلك فلذلك أمر به.

ورد هذا الوجه: بأن الاحتجاج فيه نظر؛ لأن الظاهر معنى قوله صلى الله عليه وسلم " ارجعه " أي لا تمض الهبة المذكورة، ولا يلزم من ذلك تقدم صحة الهبة .

رابعاً: أن قوله صلى الله عليه وسلم " اشهد على هذا غيري ط إذن بالإشهاد على ذلك، وإنما امتنع من ذلك لكونه الإمام، وكأنه صلى الله عليه وسلم قال: لا اشهد ؛ لأن الإمام ليس من شأنه أن يشهد، وإنما من شأنه أن يحكم.

ورد هذا الوجه: بأن امتناع الإمام من أن يشهد لا يلزم منه منعه من تحمل الشهادة ولا من أدائها إذا تعينت عليه، كما أن قوله صلى الله عليه وسلم " اشهد " ليس للآذن، بل هو للتوبيخ، كما يدل عليه باقي ألفاظ الحديث.

خامساً: أن عمل الخليفين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما بعد النبي صلى الله عليه وسلم على عدم التسوية قرينة ظاهرة في أن الأمر للنائب ، فأما أبو بكر فروى في الموطأ بإسناد صحيح عن عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر رضي الله عنه قال لها في مرض موته: إني كنت نحلتك نحلاً، فلو كنت احتزته لكان لك، وإنما هو اليوم للوارث. وأما عمر فقد نحل ابنه عاصم دون سائر ولده .

وأجيب عن هذا الوجه بأن الأمر في قصه عائشة رضي الله عنها كان برضاء من اخواتها، وكذا الأمر في قصه عمر رضي الله عنه.

الترجيح:

والذي أراه راجحاً هو عدم التفضيل بين الأبناء في العطايا وذلك أخذاً بالنهي الوارد في الحديث وحملأ على ظاهره، ما لم تكن هناك ضرورة داعية إلى هذا التفضيل كان يكون أحدهما مريضاً في حاجه إلى عون خاص أو ما شابه ذلك كل ذلك حتى لا يورث الأباء البغضاء والعداوة بين أولادهم.

المسألة السادسة: الرجوع في الهبة

الأصل عند الشافعية أنه لا يجوز للواهب أن يرجع في هبته، بيد أنه إذا كان الأصل هو حرمة الرجوع في الهبة عند الشافعية إلا أنهم يستثنون من هذا الأصل حق الوالد أو الأصل في أن يرجع في هبته لولده . فيقول الماوردي "وليس لواهب اقبض ما وهب أن يرجع فيه، إلا أن يكون والدأ فيجوز له الجوع، فأما من سواه فلا رجوع له سواء كان أجنبياً أو ذا رحم^(١) . يلاحظ أن لفظ " الوالد " عند الشافعية يعني أصول الشخص كالأب والجد والأم والجدة.

والحكمة في اختصاص الأصل بجواز الرجوع في الهبة هو انتفاء التهمة لدى الأصل، إذ أن ما طبع عليه الأصل من إيثار لولده على نفسه يقضى بأنه إذا رجع يكون الرجوع لحاجة أو مصلحة. ويكره له الرجوع من غير عذر فإن كان عذر كعقوق للوالدين أو الصرف في المعاصي من المال محل الهبة ، فلا يكره الرجوع^(٢).

(١) الحاوي، ج ٩، ص ٤١٤.

(٢) حاشية الشرقاوي، ج ٢، ص ١١٥.

أدلة جواز الرجوع عند الشافعية:

ويستدل الشافعية على جواز الرجوع في الهبة من الوالد إلى ولده بما يلي:

١- حديث البشير السابق الإشارة إليه في هبته للنعمان، حيث قال له صلى الله عليه وسلم " ارجعه " من ولده ن فلولا أن رجوعه جائز لما أمره به صلى الله عليه وسلم.

٢ - روي عمرو بن شعيب عن طاووس عن بن عمر وابن عباس قال: قال إلا الوالد فيما يعطي ولده، ومثل الذي يعطي العطية ويرجع فيها كمثل الكلب يأكل فإذا شبع قاء ثم عاد من قيئه " والحديث أخرجه البيهقي ومعناه في صحيح البخاري، فقد دل الحديث أيضا على أن القاعدة الأصلية عدم جواز الرجوع في الهبة لما في ذلك من التنفير والتشبيه المذموم الوارد في الحديث، غير أن الحديث استثني القاعدة العامة هبة الوالد لولده فيجوز له الرجوع.

شروط الرجوع في الهبة :

ويشترط الشافعية عدة شروط تعطي للوالد أو الأصل عند توافرها حق الرجوع في هبته لولده، وتمنعه عند انتفاء وجود هذه الشروط من الرجوع في هبته، وأهم هذه الشروط ما يلي:

١- كون الشيء الموهوب عينا، فلو كان دينا وأبرأه الوالد من هذا الدين امتنع عليه الرجوع جزماً، سواء قلنا الإبراء إسقاط أم أن الإبراء تملك، إذ لا بقاء للدين، فأشبهه ما لو وهبه شيء فتلّف، ذلك أن الهلاك مانع من الرجوع في الهبة .

٢- بقاء الشيء الموهوب في سلطنه الفرع، فإن استهلك الشيء الموهوب سقط حق الوالد بالكلية. وكذلك يمتنع على الأصل الرجوع إذا خرج الشيء الموهوب من ملك

الموهوب له " الولد " كان يكون باعه حتى وإن عاد إليه ببيع آخر ونحوه^(١) ، وفقاً للقاعدة الفقهية التي تقول " إن الزائل العائد كالذي لم يعد".

وإذا كانت القاعدة أن للوالد أو الأصل حق الرجوع في الهبة حاله بقاء الشيء الموهوب في سلطنه الفرع فإن ثمة صور ثلاثة ذكرها الشافعية لا يجوز فيها للأصل الرجوع في هبته حتى مع بقاء الشيء الموهوب في سلطنة الفرع وهذه الصور هي:

أ - إذا جُن الأب، فإنه لا يصح رجوعه حال جنونه ولا رجوع لولية ؛ فإن فاق فله حق الرجوع مرة أخرى.

ب - لو أحرم الأصل، وكان الشيء الموهوب صيداً ن فإن الأصل لا يحق الرجوع في هذه الحالة ؛ لأنه لا يجوز إثبات يده على الصيد في حال الإحرام، فغن حل الإحرام كان له الرجوع.

ج - لو ارتد الوالد - وقلنا بوقف ملكه - فإنه لا يرجع ؛ لأن الرجوع لا يقبل الوقف كما لا يقبل التعليق، فإن عاد إلى الإسلام جاز له الرجوع عند بقاء الشيء الموهوب في سلطنه الفرع^(٢).

(١) شرح منهاج الطالبين، ج ٣، ص ١١٣ - ١١٤، حاشية الشرقاوي ؛ ج ٢، ص ١١٦

(٢) مغني المحتاج، ج ٢، ص ٤٠٢

الفصل السابع

الجعالة^(١)

المبحث الأول : تعريف الجعالة ومشروعيتها

تعريف الجعالة

الجعالة لغة : بفتح الجيم وكسرهما وضمها ، اسم لما يجعل للإنسان علي فعل شيء .

وشرعاً : التزام عوض معلوم على عمل معين أو مجهول عسر عمله^(٢). وعرفها الإمام النووي بالمثل فقال : " من رد عبدي الآبق، أو دابتي الضالة، ونحو ذلك فله كذا"^(٣).

أوجه الاختلاف بين الإجارة والجعالة:

إن غالب فقهاء الشافعية ، منهم الشيرازي كما في التنبيه ، والنووي كما في الروضة، وغيرهم ، قد ذهبوا إلى ذكر الجعالة عقب الإجارة، وذلك لاشتراكهما في غالب الأحكام، وذلك لأن الجعالة لا تخالف الإجارة إلا في عدة أحكام وأهمها:

١- أن الجعالة تصح على عمل مجهول عسر علمه كرد الدابة الضالة، وإن كانت الدابة مجهولة المكان ، أما الإجارة فهي عقد على منفعة معلومة.

^(١)كتبه : أ. د / محمد عامر .

(٢) مغني المحتاج ج٢ ص٥٨٢ ، الاقناع مع حاشية البيجرمي ج٣ ص٢٧٥

(٣) روضة الطالبين ج٤ ص٣٣٥ .

- ٢- أن الجعالة تصح مع عامل غير معين، كأن يقول الجاعل "من رد ضالتي فله كذا" أما الإجارة فلا تصح إلا مع من يتعين العقد عليه.
- ٣- أن الجعالة عقد جائز لكل من العامل والجاعل الحق في الفسخ ، بينما الإجارة عقد لازم ، لا يجوز لاحدهما فسخ العقد دون موافقة الطرف الآخر.
- ٤- لا يستحق العامل في الجعالة الجعل إلا بعد تمام العمل ، ولو شرط تعجله فسد العقد ، أما في الإجارة فإن المنفعة والأجرة تملك بالعقد ، وله أن يشترط تعجيل الأجرة.
- ٥- لا يشترط في الجعالة قبول العمل، أما في الإجارة فلا تصح إلا بالإيجاب والقبول ، حتى يكتمل ركن الصيغة.
- ١- تنفسخ الجعالة بالموت ، أما في الإجارة فلا تنفسخ بالموت ^(١)

حكمها ودليل مشروعيتها

والجعالة مشروعة بالكتاب والسنة والمعقول:

أ- الدليل من الكتاب

قوله تعالى " قَالُوا نَفَقْدُ صَوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ " ^(٢) فقد استدلل الفقهاء ومنهم الشيرازي صاحب المذهب ^(٣) من الشافعية على مشروعيتها وجوازها بهذه الآية ، وإن كان غالب علماء الشافعية يذكرون هذه

(١) حاشية البيجرمي على شرح بن القاسم ج ٢ ص ٤٧ ، روضة الطالبين ج ٤ ص ٣٤٠ ، الحاوي ج ٩ ص ٤٦٤ وبعدها.

(٢) سورة يوسف آية ٧٢.

(٣) المذهب مع تكملة المجموع ج ١٥ ص ١١٥.

الآية على سبيل الاستئناس دون الاستدلال ، لأنهم يرون أن شرع من قبلنا ليس بشرع لنا وأن ورد في شرعنا ما يؤيده (١)

ب- الدليل من السنة

ما رواه البخاري بسنده عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: انطلق نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافروها، حتى نزلوا على حي من أحياء العرب، فاستضافوهم فأبوا أن يضيفوهم، فلدغ سيد ذلك الحي، فسعوا له بكل شيء، لا ينفعه شيء، فقال بعضهم: لو أتيتهم هؤلاء الرهط الذين نزلوا، لعله أن يكون عند بعضهم شيء، فأتوهم، فقالوا: يا أيها الرهط إن سيدنا لدغ، وسعينا له بكل شيء لا ينفعه، فهل عند أحد منكم من شيء؟ فقال بعضهم: نعم، والله إنني لأرقي، ولكن والله لقد استضفناكم فلم تضيفونا، فما أنا براق لكم حتى تجعلوا لنا جعلا، فصالحوهم على قطيع من الغنم، فانطلق يتقل عليه، ويقرأ: الحمد لله رب العالمين فكأنما نشط من عقال، فانطلق يمشي وما به قلبية، قال: فأوفوهم جعلهم الذي صالحوهم عليه، فقال بعضهم: اقسما، فقال الذي رقى: لا تفعلوا حتى نأتي النبي صلى الله عليه وسلم فنذكر له الذي كان، فننظر ما يأمرنا، فقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له، فقال: «وما يدريك أنها رقية»، ثم قال: «قد أصبتم، اقسما، واضربوا لي معكم سهما» فضحك النبي صلى الله عليه وسلم. (٢)

(١) مغني المحتاج ج٢ ص ٥٨٢.

(٢) صحيح البخاري مع شارحه فتح الباري ، كتاب الإجارة ، باب ما يعطى في الرقية على أحياء العرب بفاتحة الكتاب، رقم ٢٢٧٦ ج ٥ ص ٢١٤.

فالحديث يدل على مشروعية الجعالة ، وقد قال الزركشي : يستنبط من هذا الحديث حواز الجعالة على ما ينتفع به المريض من دواء أو رقيه (١)

ج- الدليل من المعقول

إن الحاجة تدعو إلى مشروعية الجعالة ، خاصة فيما يتعلق برد ضالة ، أو القيام بعمل لا يقدر عليه صاحبه ، ولا يجد في ذات الوقت من يتطوع بالقيام به ، فضلا عن ذلك فإن هذا المحتاج لا يستطيع الإجارة على هذا العمل لجهل به مع احتمال إيهام العامل ، ومن هنا كنت الحاجة إلى مشروعية الجعالة (٢)

المبحث الثاني

أركانها وشروط الجعالة (٣)

تتحقق الجعالة بوجود أربعة أركان ، وهي:

الركن الأول: الصيغة

وهي من طرف الجاعل، لا العامل فلا يشترط له صيغة ولا يشترط فيه قبول من العامل وإن عينه الجاعل، أما في غير المعين فلأنه يستحيل طلب قبوله، وأما في المعين فلأن فيه تضيق، والصيغة من أهم أركان عقد الجعالة ، لأن

(١) مغني المحتاج ج ٢ ص ٥٨٢

(٢) تكملة المجموع ج ١٥ ص ١١٦ ، مغني المحتاج ج ٢ ص ٥٨٢ .

(٣) لمزيد من التفصيل يراجع: مغني المحتاج ج ٢ ص ٥٨٢ وبعدها، روضة الطالبين ج ٤ ص ٣٥ وبعدها ، حاشية قليوبيج ج ٣ ص ١٣٠ وبعدها ، بيجرمي على الخطيب ج ٣ ص ٢٧٧ وبعدها، حاشية البيجوري على شرح بن القاسم الغزي ج ٢ ص ٤٨ .

الجعالة من عقود المعاوضات ،فافتقرت إلى صيغة تدل على المطلوب ،
ويلاحظ أن اشارة الاخرس المفهمة تقوم مقام الصيغة، ويشترط في الصيغة ما
يلي:

١- عدم التأقيت قياساً على القراض فإن قال " من رد ضالتي اليوم فله مائة
جنيه" فلا يصح ذلك بسبب احتمال عدم القدرة في الحصول على هذه
الضالة في اليوم المحدد.

٢- عدم التعليق ، لأن القراض لا يصح تعليقه ، فكذا الامر في الجعالة
٣- أن تدل الصيغة على الاذن في العمل ،يستوي أن تكون هذه الدلالة بطلب
كقوله "رد ضالتي ولك كذا" أو أن تكون الدلالة على الاذن بصيغة الشرط
كقوله "إن رددت ضالتي فلك كذا" وعلى ذلك ، فإن من عمل دون إذن فلا
يستحق شيئاً، لأن عمله يعد من قبيل التبرعات ، وكذلك لو أذن في العمل
لشخص معين بذاته ، فعمل غيره فلا شيء له.

الركن الثاني: العاقد

ويقصد بالعاقد في عقد الجعالة : ملتزم العوض (الجاعل)، والعامل ، مع
ملاحظة أنه لا يشترط في الجاعل كونه مالكاً ،بل يكفي كونه مخبراً عن غيره
ما دام اتصف بالثقة والصدق ، كما يلاحظ أن العامل قد يكون معيناً بذاته
،وقد يكون مبهماً وأن جعله من الاركان من باب المسامحة لأنه لا يشترط
القبول منه ، كما لا يشترط حضوره وقت خطاب الجاعل ،

أ - شروط الجاعل . وعموماً فإنه يشترط في ملتزم العوض (الجاعل) ،
والعامل ما يلي:

١- أن يكون مختاراً، ومفاد هذا الشرط أن تصدر الصيغة من الجاعل بإرادته الحرة ، فلا يصح التزام مكره ، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم (إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) (١)

٢- أن يكون مطلق التصرف. فيشترط في الملتزم للجعل مالكا كان أو غيره أن يكون مطلق التصرف أي صحيح التصرف فيما يجعله عوضاً ومن ثم يدخل الولي من خلال هذا الشرط، ويخرج الصبي والمجنون والمحجور عليه بسفه.

ب- شروط العامل

١- علم العامل بالتزام الجاعل . وهذا العلم مشروط في العامل معيناً كان أو مبهماً، فإن قال الجاعل : إن رد سيارتي زيد فله كذا ، فردها زيد وهو غير عالم بما التزمه الجاعل ، فلا شيء له ، وكذلك الأمر لو قال الجاعل : من رد إلي سيارتي فله كذا، فردها شخص لم يعلم بذلك الجعل ، فلا يستحق شيئاً. والمثال الأول للعامل المعين، والمثال الثاني للعامل المبهم.

٢- أهلية العمل في العامل المعين. والمراد بالأهلية القدرة على العمل ، فيصح من العبد ومن المحجور عليه بسفه ، ويخرج كل عاجز عن العمل كالصغير الذي لا يقدر على العمل ، لأن منفعته معدومة ، فأشبهه استئجار الأعمى لحفظ الأشياء فإنه لا يجوز ، لانعدام المنفعة. وأما العامل المبهم غير المعين، فإنه يكفي علمه بالنداء ، فقد قال الماوردي "فلو قال من جاء بعبدي الأبق فله دينار فأبي الناس جاء به استحق الدينار من رجل أو امرأة حر أو عبد مسلم أو كافر صغيراً أو

(١) ابن ماجة كتاب الطلاق ، والحاكم رقم ٢٨٠١.

كبيراً عاقل أو مجنون إن كان قد سمع النداء أو علم به لدخولهم في عموم قوله من جاءني " (١)

الركن الثالث: العمل

قد يكون العمل في الجعالة مجهولاً أو معلوماً ، والمذهب عند الشافعية أن الجعالة تصح على كل عموم عسر علمه كرد الدابة للحاجة ، فإن لم يعسر علمه اشترط ضبطه ، إذ لا حاجة إلى احتمال الجهالة، ففي بناء حائط يجب بيان طوله وعرضه وارتفاعه وموضعه، وفي الخياطة يجب بيان وصف الثوب والخياطة.

وأما إذا كان العمل معلوماً يقابل بأجرة كالخياطة والبناء، فالأصح عند الشافعية هو جواز الجعالة عليه ، لأن الجعالة إذا جازت على العمل المجهول ، فمع العمل المعلوم أولى . ومقابل الأصح عند الشافعية هو عدم جواز الجعالة على العمل المعلوم حيث يمكن الاستغناء عن الجعالة بالإجارة في هذه الحالة . ويشترط في العمل ما يلي:

١- أن يكون العمل فيه كلفه. فلا جعل فيما لا كلفة فيه، كأن يقول الجاعل: من دلني على مالي فله كذا، فدلّه عليه العامل وهو بيد غيره، فلا يستحق شيئاً لأن ما لا كلفة فيه لا يقابل بعوض. إما إن بذل العامل جهداً في البحث والتحري لإخباره، وصدق في هذا الإخبار فإنه يستحق الجعل.

٢- ألا يكون العمل متعيناً على العامل. فلا جعل فيما تعين على العامل القيام به شرعاً كرد مال كان في يده بجهة توجب الرد كالغصب والعارية، فلو قال الجاعل : من رد إلي مالي فله كذا، فردّه من غصبه فلا شيء له ، لأن الرد متعين على الغاصب شرعاً.

(١) الحاوي الكبير ج٩ ص٤٦٥.

ويرى بعض الشافعية ^(١) أن الواجب على الكفاية كالمداواة والرقية وتخليص من حبس ظلماً، لا يعد من الأعمال المتعينة على العامل ، ومن ثم يستحق عليهما الجعل بيد أننا نرى أن الصورة الأخيرة، وهي تخليص من حبس ظلماً مقابل جعل، محل نظر، لأن صاحب الجاه إن استطاع رفع ظلم وقع على إنسان، فإنه يعد عملاً متعيناً عليه ^(٢)

الركن الرابع : الجعل

وهو ما يلتزمه الجاعل للعامل في مقابل عمله. وضابط الجعل الصحيح هو " أن كل ما يصلح أن يكون ثمناً، يصلح أن يكون جعلاً، وما لا يصح أن يكون ثمناً، لا يصح أن يكون جعلاً" ووفقاً لهذا المعيار فإنه يشترط في الجعل ما يشترط في الثمن وأهم هذه الشروط:

- ١- أن يكون الجعل طاهراً، منتفعاً به، مملوكاً، مقدور على تسليمه. فلو كان الجعل خمراً أو خنزيراً أو مغصوباً فسد العقد، فإذا قام العامل بالعمل رغم هذا الفساد، استحق أجرة مثله.
- ٢- أن يكون الجعل معلوماً جنساً وقدرًا وصفة قياساً على الأجرة والثمن، ولأن الجعالة عقد جوز للحاجة، ولا حاجة في اعتبارها مع جهالة العوض. وهذا بخلاف جهالة العمل والعامل فيها فإنه يجوز للحاجة، كما أنه من الصعوبة بمكان أن يرغب أحد في العمل مع جهله بالعوض، فيفوت مقصود العقد. فإذا شرط الجاعل عوضاً مجهولاً، بأن قال مثلاً "من رد سيارتي فله ثوب، أو قال فعلي أن أرضيه، أو أعطيه شيئاً" فقد فسد العقد، ويستحق العامل أجرة المثل عند الرد. ويستثنى من اشتراط العلم بالجعالة صورتان:

(١) الإقناع في حل الفاظ أبي شجاع ج٣ ص٢٨٠، وحاشية قليوبي ج٣ ص١٣١.

(٢) تكملة المجموع ج١٥ ص١٢٠.

الأولى: مسألة العلق، وهو الكافر يجعل له الإمام إن دل على قلعة جعلاً منها كجارية من هذه القلعة، فإنه يجوز مع جهالة العوض.
الثانية: ما إذا قال "حج عني بنقتك" فإنه يجوز مع جهالة النفقة.

المبحث الثالث

أهم أحكام الجعالة

١- الجعالة عقد جائز غير لازم

ومعنى هذا أن لكل من الجاعل والعامل الفسخ قبل تمام العمل، لأن الجعالة من جهة الجاعل تعليق استحقاق بشرط فأشبهت الوصية، وأما من جهة العامل فلأن العمل فيها مجهول فأشبهت القراض. ويلاحظ أن حق الفسخ إنما يكون قبل تمام العمل، أما بعد تمام العمل، فإنه لا أثر للفسخ لأن الجعل يكون قد لازم.

= فإذا فسخت الجعالة فلا يستحق العامل شيئاً في الحالات الآتية:

- ١- إذا فسخ المالك أو العامل قبل الشروع في العمل، لأنه لم يعمل شيئاً.
- ٢- إذا تم الفسخ من جهة العامل بعد الشروع في العمل لأن الغرض المالك لم يحصل.
- ٣- إذا عمل العامل شيئاً، وهو عالم بالفسخ.
- ٤- إذا فسخ العامل والجاعل معاً بعد الشروع في العمل لأن فسخ العامل مانع من الاستحقاق، وأما فسخ الجاعل فهو مقتضى لاستحقاق أجره المثل، والقاعدة أنه إذا اجتمع المانع والمقتضى قدم المانع فلا يستحق العامل شيئاً.

= بينما يستحق العامل أجره المثل في الحالات الآتية:

- ١- إذا زاد الجاعل في العمل، ولم يرض العامل ففسخ، فله أجره المثل، لأن المالك هو الذي ألجأه للفسخ.
- ٢- إذا فسخ المالك بعد الشروع في العمل، فعليه أجره المثل لما عمله العامل في الأصح، لأن القول بأن الجعالة عقد جائز يعطي المالك سلطة الفسخ، لكن عمل العامل وقع محترماً فلا يفوت عليه بل يرجع إلى بدله، وهو أجره المثل، كالإجارة إذا فسخت بعيب. (١)

٢- الزيادة والنقص في الجعل

إن من حق المالك في عقد الجعالة أن يزيد وينقص في الجعل الذي شرطه للعامل أو يغير جنسه، فيقول من رد ضالتي فله عشرة" ثم يقول فله خمسة" أو يقول من ردها فله "دينار" ثم يقول "قله درهم" بيد أن مشروط بكونه قبل فراغ العامل من العمل ، سواء أكان قبل الشروع في العمل أم بعده.

فإذا سمع العامل ذلك قبل الشروع في العمل فالعبرة بالنداء الأخير أما إذا لم يسمعه العامل ،أو سمعه بعد الشروع ، فيجب له أجره المثل، لأن النداء الأخير بمثابة فسخ للأول ، ومن المعلوم أن الفسخ من المالك في أثناء العمل يقتضي الرجوع إلى أجره المثل. (٢)

٣- استحقاق العامل للجعل

إن العامل في عقد الجعالة يقوم بعمل فيه كلفة ومؤنة، وهذا العمل ليس واجباً عينياً عليه حتى يلزم به ، وإنما يقوم بهذا العمل غالباً بغية الحصول

(١) مغني المحتاج ج٢ ص٥٨٨، ٥٨٧.

(٢) الإقناع مع حاشية بيجرمي على الخطيب، المسماة تحفة الحبيب ص٢٨٢.

على الجعل، ويرى فقهاء الشافعية أن استحقاق العامل للجعل يتوقف على وجود أمرين:

الأمر الأول: أن يعمل بإذن الجاعل :

فإذا عمل العامل بإذن المالك أو الجاعل، وكان الإذن في عقد صحيح بعوض معلوم، فإن العامل يستحق هذا العوض، فإن كان العوض مجهولاً، أو العقد فاسداً، استحق العامل أجره المثل . وأما إذا سكت الجاعل عن العوض ، فلم يذكر مع الأمر بالرد عوضاً لا صحيحاً ولا فاسداً، بل قال "رد ضالتي" فقد اختلف الأصحاب: هل يستحق أجره مثله بمجرد الأمر؟ وذلك على أربعة أوجه:

الوجه الأول: ذهب الشافعي: أنه لا أجر له سواء كان معروفاً بأخذ الأجرة على ذلك أو لا، لأن الأمر قد تردد بين احتمال تطوع العامل، وبين احتمال استعجاله.

الوجه الثاني: ذهب المزني أن له أجره المثل، سواء كان معروفاً برد الضوال أو كان غير معروف ، لأن العامل قد استهلك منافعه ، قله أجره مثله.

الوجه الثالث: ذهب ابن سريج أن العامل يأخذ أجره المثل إن عرف برد الضوال والقيام بهذه الأعمال.

الوجه الرابع: ذهب أبو إسحاق المروزي إلى أن المالك أو الجاعل إن ابتدأ العامل بالأمر فعليه أجره المثل.

وأما إذا عمل العامل دون امر من المالك أو الجاعل فرد الضالة مثلاً، فلا أجر له ، حتى وإن كان معروفاً بطلب الضوال، وقد استدل الماوردي على ذلك بما يلي:

١- عموم قوله لى الله عليه وسلم (لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه).

٢- إن منافع نفسه التي استهلكها في رد الضالة أضعف من الأعيان التي استهلكها في رد هذه الضالة من طعام وعلف، ولما كان لا يستحق عوضاً إن استهلك أعياناً في رد الضالة، فلا يستحق إن استهلك منافع نفسه أولى لأنها أضعف، ولأن من تطوع بإصطناع معروف لم يستحق به جعلاً كغير المعروف (١)

والخلاصة: أن القدر المتفق عليه بين الشافعية هو أن عمل العامل بإذن المالك أو الجاعل في عقد صحيح بعوض معلوم يترتب عليه استحقاق العامل للجعل.

الأمر الثاني: الفراغ من العمل مع الرد والتسليم

إن استحقاق العامل للجعل يتوقف على تمام العمل والفراغ منه، وتسليمه إلى الجاعل، فلو سعى العامل في طلب دابة ضالة وحصل عليها، ثم ماتت على باب الجاعل أو الملك أو هربت قبل أن يسلمها إليه فلا شيء للعامل لأنه لم يرد ولم يحصل شيء من مقصود الجاعل وأما إذا تلف ما عمل فيه العامل قبل تمامه فإن الشافعية يفرقون بين ما إذا وقع العمل مسلماً للمالك أو لم يقع مسلماً:

أ- فإن وقع العمل مسلماً، بمعنى إنه كان في حضرة المالك أو في ملكه وظهر أثره على المحل وأمكن الإتمام عليه، كالخياطة والتعليم والبناء استحق العامل القسط.

(١) الحاوي الكبير للماوردي ج ٩ ص ٤٦٢، وبعدها.

ب- والم يقع العمل مسلماً للمالك لعدم حضوره أو لم يظهر أثره كجرة انكسرت أو لم يمكن الإلتزام عيه كثوب أحرق بعد الخياطة ، فلا شيء للعامل. (١)

وثمة ملاحظة تتعلق بالرد كأمر يتوقف عليه استحقاق العامل للجعل ، وهي أنه ليس للعامل حبس المردود لقبض الجعل ، لأن استحقاق الجعل متوقف على التسليم ، ولا حبس قبل الاستحقاق. والخلاصة : أن استحقاق العامل للجعل يتحقق ويثبت في حالة ما إذا كان العمل بإذن الجاعل ، واستطاع العامل أن يتم عمله ويفرغ منه ويسلمه إلى الجاعل ، ففي هذه الحالة يستحق العامل الجعل.

٤- يد العامل في الجعالة

إن العامل في الجعالة قد يعمل بإذن المالك أو يعمل دون إذنه فإن عمل بإذنه ، فإن يد العامل على ما يقع في يده إلى أن يرده يد أمانة لرضا مالكة به، فإن تركه بتقريط ضمن لتقصيره، فلو كانت دابة وخلاها في مضیعة فهو تقصير يوجب الضمان . وكذلك لو تلف الشيء بتعدي من العامل فإنه يضمن.

وأما إن عمل دون إذن مالكة ، فيرى الماوردي أن العامل يكون ضامناً باليد ، وأن الضمان يسقط عنه بالرد وإذا أنفق العامل شيئاً مدة الرجوع، فإنه يعد متبرعاً ، إلا أن يأذن له الحاكم، أو يشهد عند فقده ليرجع (٢)

(١) روضة الطالبين ج٤ ص٣٤١، حاشية قليوبي ج٣ ص١٣٣، بيجرمي على الخطيب ج٣ ص٢٨٤.

(٢) مغني المحتاج ج٢ ص٥٨٩، حاشية قليوبي ج٣ ص١٣٤، الحاوي ج٩ ص٤٦٢.

٥- اختلاف العامل والجاعل

ثمة خلافات ومنازعات قد تنثور بين العامل وبين الجاعل، وربما يدعي مشاركة للعامل وقد يقع الخلاف في شرط الجعل ، أو في سعي العامل في الرد أو في قدر الجعلالخ؟ فإذا ما حدث خلاف فإن المالك أو الجاعل يصدق في الأحوال الآتية:

١- إذا أنكر المالك شرط الجعل للعامل أو الإذن له، بأن اختلفا فيه، فقال العامل: شرطت لي جعلاً. وأنكر المالك فإن القول قول المالك بيمينه، لأن الأصل عدم الشرط.

٢- إذا أنكر المالك سعي العامل في الرد فقال المالك لم ترد الدابة، وإنما رجعت بنفسها أو ردها غيرك فيصدق المالك بيمينه لأن الأصل عدم الرد.

= بينما يصدق العامل في حالة ما إذا اختلف العامل والمالك في بلوغ العامل النداء، فالقول قول العامل بيمينه، كما لو اختلفا في سماع النداء. وأما إذا اختلف العامل والجاعل في قدر الجعل أو جنسه أو صفته بعد الفراغ من العمل

، فيتحالفان، ويفسخ العقد ، ويجب للعامل أجره المثل ، كما لو اختلفا في الإجارة وكذا لو قال المالك : شرطته على رد دابتين، فقال الراد، بل الذي رددته فقط (١)

٦ - انقضاء الجعالة

تنقضي الجعالة بعدة أمور، أهمها:

١- الفراغ من العمل مع رد الشيء المطلوب وتسليمه إلى الجاعل مع قبض الجعل المستحق.

(١) مغني المحتاج ج٢ ص٥٨٩، روضة الطالبين ج٤ ص٣٤٢.

٢- الفسخ، لأن الجعالة من العقود الجائزة ، التي تنقضي بالفسخ كما سبق بيانه.

٣- الموت والجنون، فالجعالة تنقضي بموت أحد المتعاقدين، وفي هذه الحالة فلو مات المالك أو الجاعل بعد الشروع في العمل ، ثم استكمل العامل ورد الشيء المطلوب إلى وارثه، استحق قسط ما عمله في الحياة من المسمى ^(١)

فلو أنجز العامل نصف العمل قبل موت المالك ، استحق نصف الجعل ، وأيضاً إذا مات العامل فرد وارثه استحق قسطه من الجعل أيضاً.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

أ د / محمد عامر

(١) تكملة المجموع ج ١٥ ص ١٢٥.

